

Curso Examen de Grado
Módulo 10: Recursos Procesales Civiles.

Unidad 1: Los Recursos Procesales.

Tema 1: Generalidades.

1.1 Concepto.

Los recursos procesales *“son medios o mecanismos de impugnación de las resoluciones judiciales”*.

El origen etimológico de la palabra recurso es en sentido estricto, tomar nuevamente en curso; en un sentido más lato puede significar rever o revisar, aunque también para algunos, recurso significa remontar una determinada situación.



Tiene algún sentido porque con el recurso se pretende revertir una situación desfavorable para el respectivo recurrente.

1. 2 Análisis del concepto y otros aspectos relacionados.

El recurso procesal se intenta respecto de resoluciones judiciales, siendo su finalidad la revisión de la respectiva resolución para que sea modificada en beneficio del recurrente, o bien su reemplazo.

Lo normal es que el recurso procesal pretenda la modificación, partiendo del supuesto que la resolución atacada por el recurso es válida pero errónea. Ejemplos típicos son los recursos de apelación y reposición.

Lo excepcional es que el recurso pretenda el reemplazo de la resolución, lo que ocurrirá cuando se alegue su nulidad, sea ésta formal o substancial. Ejemplos típicos son los recursos de

- a) Casación en la forma, en el cual se dice de nulidad formal y se pide ya sea que el propio tribunal que conoce del recurso sustituya la resolución o bien esto sea hecho por otro juez a quo distinto del que la dictó y b) casación en el fondo, en que se dice de reemplazo de la resolución por nulidad substancial y se pretende, por esta vía, que el propio tribunal de casación en el fondo, que es la Corte Suprema, al acoger este recurso dicte una nueva sentencia o sentencia de reemplazo, que sustituya la impugnada.
- b) Al decir que los recursos procesales son formas de impugnar las resoluciones judiciales, se está diciendo que ellos sólo pueden referirse a resoluciones judiciales. En consecuencia, los demás actos procesales no pueden ser impugnados por vía de recursos, sino que eventualmente pueden serlo por vía de nulidad procesal u otros motivos de falta de eficacia, como, v.g., la inoponibilidad procesal. Pero la nulidad procesal y la alegación de inoponibilidad procesal no son recursos, sino acciones.
- c) El legislador comete la falta de sistema de llamar “recursos” a ciertas acciones procesales. Es el caso de los llamados recursos de amparo, protección y, para algunos, también el recurso de revisión. El resto

de los recursos no son acciones procesales, sino medios de impugnación de resoluciones judiciales, es decir, recursos propiamente tales.

d) Si bien es cierto los recursos procesales no tienen por objeto impugnar otras actuaciones judiciales, indirectamente pueden traer como consecuencia no tan sólo la modificación o reemplazo de la resolución, sino también dejar sin efecto otros actos procesales. El ejemplo es muy claro en la casación en la forma, donde según sea el vicio del que se trata, podría suceder que no tan sólo quede sin efecto la resolución impugnada, sino además una serie de actos anteriores o posteriores a ella. Por ejemplo, si por esta vía se dice de incompetencia absoluta del tribunal, bien podría ocurrir que como consecuencia de prosperar este recurso, quedaran nulos los actos procesales ocurridos desde la intervención del juez del que se dice absolutamente incompetente.

e) Los recursos procesales son la vía normal y más propia para la revisión de las resoluciones judiciales, pero no la única. Dicho en otras palabras, hay otras vías distintas de los recursos para revisar las resoluciones judiciales. Por ejemplo, a) la consulta, que abre la posibilidad de revisar e incluso reemplazar la resolución judicial. No es un recurso porque no es vía de impugnación que usen las partes y b) la actuación de oficio de los tribunales, que significa que en ciertos casos por propia iniciativa pueden modificar o incluso reemplazar resoluciones judiciales sin recurso procesal alguno.

f) Doctrinariamente se distingue entre recursos procesales y remedios procesales, pero en nuestro ordenamiento no tiene cabida. En doctrina se reserva la expresión “remedios procesales” a la revisión de una resolución por el propio tribunal que la dictó y por razones meramente formales.

1.3 Eficacia condicional de las resoluciones judiciales impugnables.

Si una resolución judicial no es impugnante y pertenece a una cierta categoría (sentencia definitiva, sentencia interlocutoria), adquiere la fuerza de la cosa juzgada o en todo caso, puede ser cumplida incondicionalmente por su carácter de no impugnante.



Pero surge la duda: si la resolución judicial es impugnante, **¿puede tener eficacia condicional? O dicho de otra manera, ¿puede una resolución impugnante cumplirse entre tanto, pese a la posibilidad de recursos procesales?**

La respuesta genérica es sí. Dependiendo de la normativa respectiva, ciertas resoluciones que son impugnables pueden cumplirse y tienen eficacia condicionada a ciertos hechos o circunstancias, que son:

- que se intente o no en su contra los recursos procesales correspondientes.
- la naturaleza del recurso procesal del que se trata.
- cuál es la parte recurrente.
- cómo debe concederse y tramitarse el respectivo recurso.
- el desenlace o término del recurso.

La regla general es que frente a la impugnación de una resolución judicial cuando ella procede, su cumplimiento quede en suspenso. Pero en función de seguridad jurídica, de mayor rapidez en los

procedimientos, de cierta desconfianza o reticencia respecto del recurrente, el legislador señala que determinadas resoluciones tienen una eficacia desde luego, pero condicional.

Esto aparece muy claro cuando se concede la apelación en el solo efecto devolutivo, que permite efectivamente su ejecución no obstante haber recursos pendientes. La condicionalidad, es decir, esta precariedad en cuanto al cumplimiento de la resolución, está sujeta a las circunstancias ya señaladas.

La doctrina dice que frente a estas resoluciones de eficacia condicional, si el recurso prospera la regla general es que la situación se retrotrae a la etapa inmediatamente anterior a su interposición. O sea, todo lo condicionalmente actuado o realizado queda sin efecto.

1.4 Recursos procesales y error judicial.

El error judicial conmueve la fibra misma del cuerpo social, con efectos devastadores. Si el justiciable se convence de que el error judicial es altamente probable, crece en él una desconfianza tanto respecto del sistema jurisdiccional como de toda la sociedad.

El error judicial es particularmente devastador cuando se traduce en una condena injusta.

Los recursos procesales miran precisamente a evitar el error judicial en cuanto sea posible. Al respecto hay dos visiones contrapuestas:

1. Desde el punto de vista de evitar el error judicial, debería ser aceptable una multiplicidad de recursos procesales y no poner cortapisas para que los recursos procesales pudiesen ser interpuestos en cualquier momento.
2. En cambio, desde el punto de vista de la necesidad de que los conflictos sean resueltos de una vez y para siempre, en la perspectiva de la seguridad jurídica, es conveniente que los recursos procesales sean limitados en número y oportunidad.

Estas dos posturas han llevado a que se llegue a extremos en el mundo: revisión perpetua o denegatoria. Recuérdese del Derecho Indiano la multiplicidad de los recursos procesales deducibles y la tremenda latitud respecto de la apelación (Capitanía, Virreinato, Consejo de Indias, Consejo privado del Rey). Diametralmente opuesto es lo que se da con los Consejos de Guerra: procedimientos sumarísimos en que jueces no letrados aplican penas muy drásticas.

El legislador debe buscar el equilibrio entre ambas posturas, dependiendo de la naturaleza del conflicto, de su entidad, valores envueltos, mayores o menores garantías de los procedimientos, mayor o menor jerarquía de los jueces intervinientes, etc., evitando caer tanto en la revisión perpetua como en los juicios sumarísimos.

Por ejemplo, una de las cuestiones más debatidas en la reforma procesal penal fue que el juicio oral termina con una sentencia no apelable, es decir, se dicta en única instancia. Pero se conceden en su contra otros recursos procesales, de un ámbito muy estrecho.

1.5 Vertientes de impugnación de las resoluciones judiciales.

Son dos: **error formal en la resolución misma o en el desarrollo del respectivo procedimiento**; o **error substancial en la decisión**.

1) Cuando impugnamos una resolución judicial por error formal en sí misma o en el procedimiento que le sirvió de antecedente se dice de ERROR IN PROCEDENDO, error en el proceder.

2) En cambio, cuando la razón de impugnar la resolución judicial es la decisión, se dice de ERROR IN IUDICANDO, o error en el decidir.

Este último puede, a su vez, ser en cuanto a dar o no por establecidos los hechos o error de derecho, es decir, en la aplicación de la normativa jurídica correspondiente respecto de hechos ya establecidos.

Sin embargo, hay ciertas “zonas grises”, en que no es tan claro que se esté atacando una resolución judicial en cuanto a los hechos de la causa o del derecho aplicable. Se pueden citar tres ejemplos en que es dudoso si la infracción es de hecho o de derecho. La importancia es que si la infracción es simplemente de hecho, ciertos recursos no proceden. Pero si es infracción de derecho, se abre la posibilidad de la casación en el fondo.

Estos tres ejemplos son:

1. Onus Probandi o peso de la prueba: obviamente influye en la apreciación fáctica del conflicto, pero es un tema de derecho. Recuérdese que el juez aplica subsidiariamente las normas del onus probandi al no ver claro o no tener los elementos de juicio suficientes para decidir. En ese caso, determina si esta carencia se debe a incumplimiento de la parte cargada con la prueba, y por tanto debe determinar previamente quién era el cargado.
2. Valor probatorio de ciertos elementos.
3. Cosa Juzgada. Se dice que hay aspectos que tocan tanto los hechos como el derecho, y aun errores en el proceder.

1.6 El agravio.



Etimológicamente es el mal, daño o perjuicio que sufre determinada persona. Llevado este concepto al proceso, este mal puede ser consecuencia de una resolución judicial o de una actuación judicial.

Cuando es consecuencia de una actuación judicial viciosa o indebida, el agravio puede ser reclamado por vía de nulidad procesal o alegando inoponibilidad procesal.

Pero cuando este mal o daño deriva de una resolución judicial, ella es necesario antecedente del recurso procesal.

En consecuencia, el recurso procesal tiene como indispensable antecedente que la resolución procesal respectiva sea agravante, o sea, produzca daño, mal o perjuicio. Éste podrá ser mayor o menor, según la circunstancia, pero si no lo hay, no es posible el recurso.

Dicho en otros términos, sólo la parte agraviada puede intentar el recurso procesal, ya que sin agravio no hay recurso. Por ejemplo, en una sentencia se acoge la demanda en todas sus partes, pero tiene un conjunto de raciocinios erróneos y aun se extiende a materias ajenas al debate. El demandante no puede reclamar de estos errores por vía de recursos procesales, porque en la medida en que esta sentencia acogió íntegramente su pretensión, no le es agravante.

Otro ejemplo: se acoge la demanda en todas sus partes, pero no se condena en costas al demandado. En este caso el demandante sí puede impugnar la sentencia, porque pese a acoger del todo su pretensión, en la parte en que no condenó en costas al demandado le causa un daño o perjuicio.

Estos casos son muy claros, pero hay otros de más difícil solución. Por ejemplo, la parte que pierde un juicio descubre que un documento presentado por ella no fue acompañado con citación a la contraparte, es decir, no se le dio la posibilidad de impugnarlo, contraviniendo un trámite esencial. **¿Puede el perdicioso, por la circunstancia de que un documento acompañado por él no lo haya sido con citación de la contraparte, impugnar la sentencia desfavorable y que se retrotraiga la causa al acompañamiento del documento con citación de la contraparte?** La respuesta es no, porque la citación era en beneficio de la parte contraria. O sea, que ella no haya tenido la oportunidad de impugnar el documento no causa un perjuicio al perdicioso.



O sea, aun existiendo el vicio, no cabe que la parte interponga un recurso si esta circunstancia no le causó a ella un daño o agravio.

Es claro, entonces, que el recurrente debe invocar a su respecto un daño o perjuicio que legitime el respectivo recurso procesal.

Otra duda: ¿sin agravio, puede haber revisión? La respuesta es sí, porque el agravio es prerequisite del recurso, pero no de otras formas de revisión. Por ejemplo, cuando existe la consulta, el tribunal de alzada puede modificar la resolución. En suma, el agravio es prerequisite del recurso, pero no de la posible revisión cuando ella reviste formas distintas del recurso procesal.

Esto vale también para aquellos casos en que el tribunal puede actuar de oficio, aun sin agravio, sin daño a ninguna de las partes.

Más aún, el tribunal puede actuar de oficio contra el recurrente en los casos de la llamada REFORMATIO IN PEJUS: cuando no obstante el recurrente es el agraviado, el tribunal al conocer de dicho recurso puede modificar la resolución, incluso dejándola más desfavorable de lo que era inicialmente. Ocurría en el antiguo procedimiento penal con la apelación y la casación en la forma.

Además del principio del agravio como antecedente indispensable del recurso procesal, la regla muy general es que el recurso es de libre disponibilidad de las partes. Esto significa dos cosas:

- 1) no hay recurso procesal sin parte que lo interponga, y
- 2) las partes pueden, a su arbitrio, interponer o no el respectivo recurso procesal.

La decisión de interponerlo o no puede revestir la forma de renuncia anticipada de los recursos, lo que es perfectamente posible en materia procesal civil, o bien la circunstancia de dejar pasar las respectivas oportunidades preclusivas sin deducirlo.

Hemos visto que en el juicio arbitral es perfectamente lícita la renuncia antelada de las partes a los recursos procesales, lo que indica su libre disponibilidad.

Sin embargo, por razones de política procesal, hay ciertos recursos -- en rigor llamados recursos sin ser tales -- respecto de los cuales no se produce la preclusión por transcurso del plazo. Se trata del recurso (acción) de amparo y también en materia procesal penal con la revisión de sentencias condenatorias firmes.

Hemos dicho que el recurso procesal se interpone en interés del recurrente y que sólo este interés lo legitime, significa que las consecuencias de este recurso benefician directa e inmediatamente a quien lo interpuso; pero también este recurso puede tener un efecto social indirecto.

Lo vemos claramente en el recurso de casación en el fondo, donde el recurrente debe ser una parte agraviada y además tener interés en las resultas del juicio. Pero, si bien el resultado de este recurso afecta directamente a recurrente y recurrido, indirectamente tiene un efecto social o reflejo, porque por esta vía se logra que el tribunal de casación dé la recta y exacta interpretación de la ley, que tiene tanta trascendencia para la uniformidad y el entendimiento común de la normativa.

1.7 Características generales de los recursos procesales.

1. El recurso procesal se interpone ante el propio tribunal que dictó la resolución, el cual se pronuncia sobre su admisibilidad, es decir, concediendo o denegando el recurso respectivo.
2. El recurso se concede para ante el superior jerárquico inmediato. Por ejemplo, interpuesto ante el juez de letras, lo concede para ser conocido por la respectiva Corte de Apelaciones.
3. Sólo cabe respecto de resoluciones judiciales que no se encuentren firmes o ejecutoriadas. Todas las resoluciones tienen mecanismos preclusivos que llevan en definitiva a que en algún instante estén firmes o ejecutoriadas, salvo contadas excepciones.
4. Deben interponerse dentro de cierto plazo, que normalmente es fatal, es decir, su solo transcurso extingue o precluye la posibilidad de interponer el recurso.
5. No requiere de previa consignación. Hoy esta regla es casi absoluta y modifica substancialmente el sistema que regía anteriormente.-

1.8 Clasificación de los recursos procesales.

Los cuatro criterios de clasificación son los siguientes:

1. Recursos ordinarios y extraordinarios.
2. Recursos de anulación y de reforma.
3. Recursos de retractación y jerárquicos.
4. Recursos que se conceden en ambos efectos y recursos de efecto solo devolutivo.

1. Recursos Ordinarios y Extraordinarios.

Son recursos Ordinarios los que proceden contra la generalidad de las resoluciones judiciales, y también los que son procedentes sin invocar causales específicas. Ejemplo: el Recurso de Apelación.

Son Recursos Extraordinarios aquellos admisibles sólo respecto de algunas resoluciones judiciales, o también los admisibles sólo en función de causales específicos. Ejemplo: los recursos de Casación en la Forma y en el Fondo.

2. Recursos de Anulación y de Reforma.

Son recursos de Anulación aquellos donde se sostiene que la resolución recurrida es nula, ya sea por vicios substanciales o formales. Ejemplo: los recursos de Casación en la forma y en el fondo. En el primero de ellos se dice de nulidad formal; en el segundo, de nulidad substancial.

En tanto, los recursos de Reforma parten del supuesto que la respectiva resolución es válida, pero errónea. Ejemplo: la apelación, en la cual el apelante acepta la validez formal de la resolución que impugna, pero al mismo tiempo sostiene que es errónea.

3. Recursos de Retractación y Jerárquicos

Son recursos de Retractación los que se interponen para que el propio tribunal que dictó la resolución, la modifique o enmiende. Ejemplo típico: la reposición.

El recurso Jerárquico es aquél conocido por el superior jerárquico inmediato, y es a éste al que se le solicita que enmiende, o eventualmente anule, la resolución recurrida. Ejemplos: apelación, casación en la forma y casación en el fondo.

4. Recursos que se conceden en ambos efectos y recursos de efecto solo devolutivo.

El efecto suspensivo de un recurso se produce cuando en virtud de su interposición no se puede cumplir la resolución recurrida.

Esta situación de quedar en suspenso la resolución recurrida se mantiene en tanto subsista el recurso respectivo.

El efecto devolutivo significa que se reconoce competencia para conocer del recurso al tribunal respectivo, que normalmente es el superior jerárquico inmediato.

De la esencia de todo recurso es el efecto devolutivo, es decir, reconocer competencia al tribunal que debe conocer de él.

En tanto, como regla general el efecto suspensivo es sólo de su naturaleza, lo que quiere decir que si bien es cierto se produce en la generalidad de los casos, hay ciertas situaciones donde no concurre, sino que el recurso se concede en el solo efecto devolutivo.

Cuando así sucede (es decir, el recurso se concede en el solo efecto devolutivo) la resolución impugnada puede ser cumplida entre tanto, no obstante los recursos pendientes. Es un cumplimiento sub conditionem, es decir, si prospera el recurso la situación producida en virtud del cumplimiento se deberá retrotraer al estado inmediatamente anterior.

En la apelación se da nítidamente la posibilidad de efecto suspensivo y devolutivo a la vez, o el solo efecto devolutivo, porque como regla general la apelación -- hoy algo modificada -- se concede en ambos efectos, y como regla excepcional en el solo efecto devolutivo. Cuando así ocurre, cabe el cumplimiento entre tanto y sub conditionem.

Tema 2: Recursos de Aclaración o Interpretación y de Rectificación o Enmienda.

2.1 Generalidades.

Se trata de dos recursos distintos, pero el legislador los trata en común porque su tramitación es idéntica, existiendo sólo una diferencia: en determinadas circunstancias el tribunal puede, de oficio, rectificar o enmendar. Pero nunca puede, de oficio, aclarar o interpretar.

En el recurso de aclaración o interpretación se trata de una sentencia oscura. No aparece nítido el mandato contenido en ella. La decisión jurisdiccional aparece equívoca y frente a esta oscuridad se pide al respectivo tribunal que la aclare o interprete.

En tanto, en el recurso de rectificación o enmienda estamos ante una sentencia clara pero que contiene errores manifiestos, sean de copia, de referencia, de cálculo numérico u otros. Se pide al respectivo tribunal que la rectifique o enmiende.

La aclaración o interpretación y la rectificación o enmienda se presentan ante el propio tribunal que dictó la resolución, para que él mismo haga la aclaración o la rectificación solicitada.

El Código de Procedimiento Civil trata la aclaración y la rectificación junto con el principio del desasimiento del tribunal, y en tal sentido, nos remitimos al art. 182 inc 1º.

Recordemos que este principio es una prohibición para que el tribunal modifique, de manera alguna, una sentencia definitiva o interlocutoria a partir del momento en que es notificada a cualquiera de las partes. Esta prohibición es una garantía para el juzgador, que ya no puede ser objeto de presiones de ninguna especie para alterar lo resuelto por él.

Sin embargo, estos recursos son una excepción al principio del desasimiento del tribunal, el que sólo se produce respecto de las sentencias definitivas e interlocutorias.

En consecuencia, el legislador aborda el tema de la aclaración o rectificación y de la rectificación o enmienda precisamente respecto de las sentencias definitiva e interlocutoria, como excepciones al principio del desasimiento.

De la lectura del art. 182, aparece claramente el mandato legal en cuanto a que estos dos recursos están establecidos como excepción al desasimiento respecto de las sentencias definitivas e interlocutorias.

De esta norma aparecería que ambos recursos sólo proceden respecto de sentencias definitivas o interlocutorias, mas no respecto de otras resoluciones. Si nos apegamos rigurosamente a la textualidad de la norma, tal debiera ser nuestra conclusión.

Pero esto no es así: la práctica, jurisprudencia y doctrina han estimado que la posibilidad de aclaración y de rectificación caben respecto de toda clase de resoluciones, y que si el legislador hizo específica mención a las sentencias definitiva e interlocutoria, es sólo un homenaje al principio del desasimiento.

Lo que quiere decir esta norma es que estos dos recursos son posibles incluso cuando juega el principio del desasimiento; con mayor razón si no juega. En consecuencia, estos dos recursos son posibles respecto de toda clase de resoluciones judiciales.

El inc. 2º del art. 182 dice que lo dispuesto en este artículo no obsta a que el rebelde haga uso del derecho que le confiere el art. 80 del CPC, el cual contempla la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento. El emplazamiento es presupuesto procesal de validez; en consecuencia, si no lo hay, se puede pedir la nulidad de todo lo obrado, pese a haberse dictado sentencia.

Hay una regla preclusiva en los incidentes: realizar cualquier gestión que no sea precisamente decir de nulidad, hace precluir la posibilidad de pedirla. El inc. 2º del art. 182 es una excepción a este principio, pues señala que no obstante haber pedido aclaración o rectificación, oportunamente se puede pedir la nulidad de todo lo obrado, por falta de emplazamiento. Tal es el sentido de esta referencia.

2.2 Tramitación.

Partimos del supuesto que es la parte la que intenta estos recursos, sin perjuicio de que, como veremos después, excepcionalmente el tribunal puede rectificar de oficio.

Nos remitimos al art. 183 del CPC, norma que faculta al tribunal para pronunciarse de plano sobre la aclaración o rectificación pedida, o darle tramitación incidental. Además da al tribunal la posibilidad de suspender o no los trámites del juicio o la ejecución de la sentencia, según la naturaleza de la reclamación.

El legislador es muy amplio en este caso en las facultades que da al tribunal, porque no le señala una norma procedimental específica.

Es interesante que, como regla general, estos recursos no tienen plazo para ser interpuestos, por lo que pueden serlo en cualquier momento. Pero hay dos excepciones implícitas: no podrán ser interpuestos si

la resolución de que se trata ya ha sido cumplida, ni tampoco podrán serlo si se ha producido la preclusión del período procesal respectivo.

Además, la aclaración y la rectificación son compatibles con otros recursos procesales en contra de la misma resolución. Es decir, paralelamente es posible pedir estos recursos más la apelación. Así aparece claramente en el art. 185.

Otro punto importante es que la interposición de estos dos recursos no suspenden el plazo para hacer uso de otros recursos. Si se pide aclaración o rectificación de una sentencia, se entiende que sigue corriendo el plazo para apelar.

Por ello, lo razonable es que se intenten conjuntamente, si proceden, es decir, aclaración o rectificación y apelación. Así aparece claramente del inc. 2º del art. 190.

Hay texto expreso en cuanto a que la aclaración o la rectificación no suspenden el plazo para apelar. Interpretando extensivamente esta norma, se ha llegado a la conclusión que esta aclaración o rectificación no suspende el plazo de ningún recurso procesal, no tan sólo de la apelación.

De la segunda parte de este inc. Segundo, surge también claramente que cuando el tribunal acoge la aclaración o la rectificación, la sentencia complementaria respectiva es a su vez recurrible, del mismo modo que lo era la sentencia primitiva, “con tal que la cuantía de la cosa declarada, agregada o rectificada admita el recurso”.

El legislador ha sido bastante críptico en esta norma. Lo que quiere decir es que la sentencia se refiere a distintas materias, una de las cuales se le quedó en el tintero al juez, que la agregó a consecuencia de esta rectificación. Si esta agregación es de una cuantía inferior a aquella que admite la apelación, no será excepcionalmente apelable la sentencia complementaria respectiva.

2.3 Rectificación o enmienda de oficio.

Los tribunales pueden rectificar o enmendar sus propios fallos, según aparece claramente del art. 184. Pero hay que tener presente dos circunstancias: 1) sólo es admisible la rectificación o enmienda de oficio, nunca la aclaración y 2) el tribunal, a diferencia de las partes, tiene un plazo fatal para hacerlo: cinco días, contados desde la primera notificación de la respectiva resolución.

Esta rectificación de oficio cabe tanto respecto de sentencias definitivas e interlocutorias, como respecto de toda clase de resoluciones del tribunal.

De acuerdo a lo explicado, podemos caracterizar al recurso de rectificación como: 1) ordinario; 2) de retractación; 3) de reforma y 4) suspensivo o no, según lo decida el respectivo tribunal.

Tema 3: Recurso de Reposición.

Como regla muy general, en materia civil la reposición sólo cabe respecto de autos y decretos, no respecto de sentencias interlocutorias ni definitivas. En consecuencia, la reposición no es excepción al principio del desasimiento, el que sólo se aplica a las sentencias definitivas e interlocutorias.



Pero excepcionalmente, la reposición cabe en contra de sentencia interlocutoria, para lo cual debe haber norma expresa que así lo consagre. Ejemplo: la reposición en contra del “auto de prueba”, que es una sentencia interlocutoria de segunda clase.

Antes se citaba también como ejemplo de reposición contra sentencia definitiva, respecto de la que declaraba la quiebra, pero hoy se ha modificado.

3.1 Plazo para interponerlo.

De acuerdo con el art. 181, hay que distinguir si se hacen o no se hacen valer nuevos antecedentes. Si se hacen valer, la reposición se puede pedir en cualquier plazo, por lo que el transcurso del tiempo no tiene efecto preclusivo respecto de la reposición.

En cambio, si no se hacen valer nuevos antecedentes, la reposición debe interponerse dentro del plazo fatal de cinco días.

Hay dos cuestiones importantes de aclarar: **qué son nuevos antecedentes y por qué el legislador usa el plural y habla de antecedentes.**

En general, la doctrina y la jurisprudencia han estimado que nuevos antecedentes en función del recurso de reposición son nuevos elementos de carácter fáctico que ameriten la modificación del respectivo auto o decreto. En consecuencia, “nuevos antecedentes” no son nuevos argumentos o raciocinios.

Respecto al uso en plural del término “antecedentes”, en general se opina que esto es sólo un estilo gramatical determinado, pero que en este caso no necesariamente indica pluralidad. O sea, sería aceptable una sola cuestión fáctica nueva con mérito suficiente.

3.2 Tramitación de la reposición.

Cuando se hacen valer nuevos antecedentes, se ha entendido que se le debe dar tramitación incidental, por aplicación del art. 89 del CPC, que es la regla procedimental de la tramitación de los incidentes. Esto, porque se ha dicho que quien plantea reposición está planteando una cuestión incidental o accesorio, que necesita un pronunciamiento particular.

Cuando no se hacen valer nuevos antecedentes, por aplicación del mismo art., al fundarse esta petición en hechos que constan en el proceso, el tribunal está facultado para fallarlos de plano.

Sin embargo, en la práctica judicial los tribunales en general no distinguen, y prácticamente sin excepciones, dan trámite incidental a la solicitud de reposición. O sea, planteada, se da traslado a la contraparte por tres días fatales, si es necesario se recibe a prueba por ocho días y se dicta una resolución fallando este incidente.

3.3 Efectos de la reposición en cuanto al cumplimiento del respectivo auto y decreto.

Del inc. 1º del art. 181, se desprende que los autos y decretos sólo deben cumplirse cuando han adquirido el carácter de firmes, y en consecuencia la solicitud de reposición suspende el cumplimiento del respectivo auto o decreto hasta que la reposición sea resuelta, en definitiva.

3.4 Recursos contra la resolución que falla la reposición (art. 181 inc. 2º)

Hay que hacer la siguiente distinción: si la reposición es desechada, la respectiva resolución es inapelable, sin perjuicio de que pudiese ser apelable la resolución primitiva.

Por ejemplo, frente a la solicitud de practicar una determinada diligencia probatoria, el tribunal dictamina que no ha lugar. De esa resolución se pide reposición, y después de darle la tramitación correspondiente, el tribunal declara que no ha lugar a la reposición. Este “no ha lugar” a la reposición es inapelable, pero el primer “no ha lugar” sería apelable, eventualmente, según las circunstancias.



La apelación se plantea conjuntamente con la reposición y en subsidio de ésta: en lo principal reposición, subsidiariamente apelo (en un mismo escrito).

Frente a esta reposición principal, el tribunal da trámite incidental: traslado, contesta la contraparte y se falla. La resolución será en este caso “no ha lugar a la reposición, concédese la apelación subsidiaria”.

La resolución que deniega la reposición no es apelable, sin perjuicio de que sí lo sea, eventualmente, la resolución primitiva. A contrario sensu, la resolución que acoge la reposición es apelable, conclusión que arranca de interpretar a contrario sensu el inc. 2º del art. 181. La necesidad de plantear la apelación en subsidio de la reposición aparece claramente en la segunda parte del art. 188.

Tema 4: Recurso de Apelación

Es el “rey” de los recursos, el más característico, la regla general, el recurso procesal por antonomasia. Incluso en el lenguaje vulgar, cuando se reclama de cualquier situación, se dice “apelar”.

4.1 Generalidades.

4.1.1 Concepto.

“Es un recurso ordinario que la ley concede al litigante agraviado por una resolución judicial, para ocurrir al tribunal superior jerárquico correspondiente, a fin de que la modifique o revoque, en su beneficio, la resolución impugnada”.

4.1.2 Análisis del concepto.

1) Se trata de un recurso ordinario porque en nuestro sistema procesal civil está contemplado el principio general de la doble instancia. Sólo por excepción las resoluciones son en única instancia. Debe entenderse que la generalidad de las resoluciones judiciales son apelables

2) La ley concede el recurso al litigante agraviado, por una resolución judicial. El agravio es necesario, imprescindible, es decir, que haya un perjuicio o mal derivado de la resolución que se impugna. Sin agravio no hay recurso, y específicamente no hay apelación.

3) El recurso se interpone para ante el superior jerárquico respectivo.

4) El apelante busca que la resolución sea modificada o revocada en su beneficio. Revocar significa que toda la parte resolutive de la resolución sea cambiada por otra, mientras que modificar significa que la parte resolutive sea cambiada en parte, obviamente manteniéndose también en parte. Es posible que una sentencia sea parcialmente favorable y parcialmente desfavorable.

El apelante pide que se modifique o revoque en su beneficio, según sea el caso. Al respecto hay que insistir que en materia procesal civil no existe la llamada “reformatio in pejus”. Es decir, si sólo existe un apelante, la resolución de la apelación en cuanto a expectativas sólo podrá serle favorable. Pero en ningún caso modificará en perjuicio suyo la sentencia de primera instancia, con la salvedad que es posible que la sentencia de segunda instancia lo condene en las costas del recurso, sin perjuicio de lo que se resuelva respecto de las costas de la causa.

Este concepto de carácter general y doctrinario está recogido en forma más concisa en el art. 186 del CPC, que señala que la finalidad del recurso de apelación es obtener del tribunal superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior.

Que la ley hable de enmendar no es erróneo; pero es más preciso señalar que lo que se pretende es la revocación o modificación de la respectiva resolución.

En el lenguaje forense, apelar es sinónimo de “alzarse” en contra de la resolución y en este sentido, el tribunal que conoce del recurso de apelación es llamado “tribunal de alzada”, nombre que recoge la primaria reacción del que se sentía perjudicado: una actitud agresiva, aguerrida y rebelde. Hoy “alzarse” se entiende en el sentido de pedir.

Volviendo al tema del agravio, se debe destacar que para que realmente exista, deben concurrir un elemento objetivo y uno subjetivo.

a) Elemento objetivo: se compara la petición con la resolución. Si la resolución no satisface íntegramente la petición, es agravante.

b) Elemento subjetivo: es la medida del agravio, la cual es determinada por el recurrente. Aun cuando la resolución sea objetivamente agravante, hay una medida de subjetividad en cuanto a interponer o no el recurso según la intensidad del agravio. Es un cálculo del recurrente en cuanto al costo-beneficio de apelar.

Ejemplo: demando indemnización de perjuicios por \$ 108 y el tribunal ordena se me paguen \$ 106 millones. La resolución es objetivamente agravante, porque no obtuve todo lo que perseguía; pero subjetivamente mido la intensidad del agravio, y si en función de un pronto resarcimiento y cumplimiento, prefiero recuperar rápidamente mi dinero, puede no apelar porque subjetivamente no me resulta agravante. En el agravio, por lo tanto, necesariamente debe concurrir una medida objetiva, pero mi subjetividad determina si en cada caso particular existe o no el agravio que sustenta este recurso.

El término “apelar” viene del latín y significa llamar: la apelación es el llamado o clamor del agraviado que busca que se modifique o revoque en su beneficio la resolución que le es perjudicial.

4.1.3 Relación entre apelación y doble instancia.

La instancia es el grado jurisdiccional, cuya característica es que el tribunal puede revisar todas las cuestiones de hecho, en general, y todas las cuestiones de derecho. Esta posibilidad de doble revisión arranca y nace del recurso de apelación, que abre la doble instancia.

Cuando los procesos son de única instancia sus resoluciones no son apelables; cuando hay doble instancia, el fallo de primera instancia es apelable y el tribunal de segunda conoce en virtud del recurso de apelación.

4.1.4. Naturaleza jurídica de la segunda instancia.

Es polémica, pero se ha sostenido que era un verdadero nuevo juicio, en el cual se repetía lo más trascendente del juicio de primera instancia.

Así, hay una serie de términos en materia procesal civil que nos llevan a entender que efectivamente estamos ante un nuevo juicio. Por ejemplo, el emplazamiento para la segunda instancia, que consiste en la notificación de una determinada resolución judicial seguida del transcurso de un plazo para ejercitar un determinado derecho.

Hay un emplazamiento para que apelado y apelante comparezcan al tribunal de alzada. Este llamamiento se hace notificándoles por el estado diario la resolución que concede la apelación y el transcurso de un tiempo para comparecer ante el tribunal de segunda, contado desde el ingreso de los autos a la secretaría del tribunal de alzada.

Además, en la antigua apelación en contra de la sentencia definitiva, salvo norma expresa en contrario había, necesariamente, un período de discusión caracterizado por dos escritos fundamentales: la expresión de agravios por parte del apelante ante la segunda instancia que por esta vía era una real demanda en contra de la sentencia y una contestación a la expresión de agravios de parte del demandado, que por este camino contestaba la demanda. Estos escritos ya no existen.

Para mantener aún más esta idea de la existencia de dos juicios sucesivos, uno en cada instancia, también había en segunda un posible período de prueba, hoy restringido con las reformas de hace 10 años, y una citación para oír sentencia en segunda instancia, trámite complejo que se inicia con el decreto de autos en relación y termina con la vista de la causa.

Por último existía la posibilidad de medidas para mejor resolver en segunda instancia y luego el fallo y su eventual impugnación.

Las modificaciones han simplificado mucho la tramitación en segunda instancia, habiendo desaparecido varias de estas similitudes. Además se ha visto que la segunda instancia es un período de revisión de lo resuelto en primera, pero no constituye un nuevo juicio.

En consecuencia, la segunda instancia es una etapa fundamental, esencial, de la decisión judicial, pero no es claramente un juicio distinto.

4.1.5 Ventajas y desventajas de la doble instancia.

Mucho se ha debatido al respecto. En el fondo dice estrecha relación con la posibilidad de evitar hasta donde sea posible el error judicial, porque en general los tribunales de primera instancia son unipersonales, en tanto que en nuestro sistema los tribunales de segunda son colegiados (normalmente la Corte de Apelaciones, también árbitros y en algunas materias la Corte Suprema).

El hecho de que la revisión esté a cargo de un tribunal con más jueces es una garantía de mejor actividad jurisdiccional. Además tienen mayor jerarquía, más años de trabajo y por ende, más experiencia.

Para algunos, la segunda instancia sólo demora, prolonga indebidamente los juicios. Pero otros autores estiman que esto se evita mediante la concesión de las apelaciones en el solo efecto devolutivo.

4.1.6 Características del recurso de apelación

1. Es un recurso ordinario; o sea, cabe ante la generalidad de las resoluciones judiciales.
2. Es un recurso por vía de reforma, no por vía de retractación, porque se pide al superior jerárquico inmediato que modifique o revoque la resolución. No se pide que lo haga el propio tribunal que la dictó en primera instancia.
3. Abre la segunda instancia, con posibilidades de revisión de las cuestiones de hecho y de derecho, con determinadas limitaciones que después se verán.
4. Su motivación es genérica. Basta señalar que la resolución es agravante y explicar por qué se produce el agravio.
5. En ciertos casos la apelación debe plantearse como subsidiaria del recurso de reposición.

4.1.7 Partes del recurso de apelación.

Al respecto debemos distinguir:

1. Partes del juicio (demandante, demandado, eventuales terceros).
2. Partes del recurso de apelación mismo (apelante, apelado, adherente).

a) Apelante: quien deduce el recurso de apelación. Es posible que ambas o varias partes sean apelantes inicialmente.

b) Apelado: contra quien se deduce el recurso de apelación.

c) Adherente: quien inicialmente sólo era apelado, pero aprovechando la apelación de la parte contraria “se sube” a ella, pidiendo que también se modifique la sentencia en su beneficio.

Por ejemplo: en un juicio de indemnización de perjuicios se acoge la demanda en todas sus partes pero no se condena en costas al demandado. El gran agraviado es el demandado, que en este caso será claramente apelante, y el demandante será el apelado. Frente a esa apelación del demandado-apelante, el demandante-apelado también quiere que se modifique la sentencia, condenando en costas al demandado-apelante. Para ello se “sube” a la apelación del demandado, a fin de que la sentencia sea modificada en primera instancia en su beneficio.

De este ejemplo aparece muy claro que demandante y demandado nada tienen que ver con apelante y apelado, porque según las resultas del juicio en primera instancia, el apelante podrá ser demandante o demandado, y apelado también podrá ser uno u otro.

De la esencia de la apelación es que haya apelante, y sólo de la naturaleza que haya apelado. O sea, lo normal en un recurso de apelación es que haya apelante y apelado, pero es perfectamente posible que haya sólo apelante. Por ejemplo, resolución dictada en cuestión no contenciosa, claramente hay apelante pero no apelado. O frente a una resolución arbitraria o ilegal que restringe la libertad individual, puede haber apelante del recurso de amparo desechado, pero no necesariamente apelado, porque bien podría no haber otra parte en el respectivo juicio.

La adhesión a la apelación es una situación excepcional que nace de haber sido originariamente apelado, y sólo a posteriori convertirse en apelante en virtud de la adhesión.

4.1.8 Distintas situaciones de las partes en la apelación.

1. La situación normal es que haya un apelante y un apelado y que tengan posiciones contradictorias, pudiendo el apelante ser demandante o demandado, y lo mismo el apelado (ser demandante o demandado).
2. La situación anormal inicial se produce el fenómeno de varios apelantes frente a una determinada resolución (demandante, demandado, tercero). Todos los apelantes son recíprocamente apelantes y apelados y sostienen pretensiones contrarias.
3. La situación anómala sobreviniente se da cuando hay un apelante y un apelado que a posteriori se convierte en adherente y también en apelante. En tal evento, nuevamente todos son recíprocamente apelantes y apelados.
4. La situación compleja de los Arts. 16, 22 y 23 del CPC, que se refieren a: a) multiplicidad de partes con un procurador común o b) intervención de terceros coadyuvantes, independientes o excluyentes.

De acuerdo a estos artículos, tanto las partes que actúan por procurador común como los terceros, pueden autónomamente interponer recursos procesales. Y de esta manera, todas estas partes pueden también convertirse en apelantes, con lo cual éstos pueden ser no tan sólo inicialmente demandantes o demandados, sino también terceros.

4.2 Resoluciones apelables.

Son apelables.

1. La sentencia definitiva de primera instancia y la sentencia interlocutoria de primera instancia, salvo que la ley expresamente deniegue el recurso (art. 187 CPC).
2. Los autos y decretos sólo son apelables cuando alteran la substanciación regular del juicio o cuando recaen sobre trámites no expresamente regulados en la ley (art. 188 CPC). O sea, no son apelables cuando no alteran la substanciación o cuando recaen sobre trámites expresamente ordenados. Cuando es apelable, siempre debe serlo en subsidio del recurso de reposición.

Ejemplo: si frente a la demanda en el juicio ordinario el tribunal provee traslado, esta resolución es un decreto, pues no resuelve nada sino que da curso progresivo al juicio. No altera su substanciación regular, por lo que no es apelable.

Pero si el tribunal no da traslado sino que llama a comparendo para el quinto día para contestar la demanda es un decreto, altera la substanciación regular del juicio y se puede apelar en subsidio.

Si el juez dicta una medida precautoria de gravar o enajenar un determinado bien, se trata de un auto: resuelve una cuestión accesoria sin establecer derechos permanentes. Es resolución apelable, porque recae sobre un trámite no expresamente ordenado en la ley. Se intenta en subsidio de la reposición.

4.3 Resoluciones inapelables.

Son de dos tipos: consecuenciales y por expreso mandato de la ley.

A. Consecuenciales: consecuencia de los principios ya revisados.

- 1) Sentencias definitivas, interlocutorias, autos y decretos de cualquier naturaleza dictados en única instancia.
- 2) Sentencias definitivas e interlocutorias dictadas en virtud de la segunda instancia, pues en nuestro sistema existe la doble instancia y no la triple instancia.
- 3) Sentencias interlocutorias, autos y decretos dictados durante la segunda instancia.

Hay una diferencia al decir “en segunda instancia” y “durante la segunda instancia”.

“En segunda instancia” significa pronunciarse sobre una interlocutoria dictada durante la primera instancia y se dicta una sentencia en segunda.

“Durante la segunda instancia”: por ejemplo, se pide un privilegio de pobreza, se le da tramitación incidental en la Corte de Apelaciones, que lo concede. Esta resolución no es en segunda instancia, sino durante la segunda instancia y por lo tanto no es apelable.

La ley sólo ha señalado este efecto respecto de la sentencia interlocutoria, pero por interpretación extensiva tampoco son apelables autos y decretos dictados durante la segunda instancia (interpretación “a fortiori” del art. 210).

Pero los autos y decretos dictados en segunda instancia son susceptibles de aclaración, reposición o rectificación.

4) Son inapelables los autos y decretos que no alteran la substanciación regular del juicio y recaen sobre trámites no expresamente regulados en la ley.

B. Por mandato legal expreso: en este caso son fuentes de inapelabilidad el Código de Procedimiento Civil, aunque la Corte Suprema ha señalado la inapelabilidad de algunas resoluciones.

El CPC usa diferentes términos: “no cabe apelación”; “sin ulterior recurso”; “en única instancia” y son por ejemplo, las siguientes normas:

- 1) Art. 49 inc. 2º
- 2) Art. 60 inc. Final: resolución del tribunal que puede habilitar días u horas.
- 3) Art. 90 inc. final
- 4) Art. 107
- 5) Art. 126
- 6) Art. 159 inc. final
- 7) Art. 181 inc. final
- 8) Art. 188
- 9) Art. 326 inc. final
- 10) Art. 379 inc. 1º
- 11) Art. 381 inc. final
- 12) Art. 394 inc. final
- 13) Art. 432 inc. 2º
- 14) Art. 487 inc. 1º
- 15) Art. 574
- 16) Art. 642
- 17) Art. 649

Por último, por resolución jurisprudencial son inapelables las sentencias de casación que se dicten por un tribunal de alzada y con mayor razón de las dictadas por la Corte Suprema, sin perjuicio de que proceda la casación contra la sentencia de segunda instancia.

4.4 Plazos y formas del recurso de apelación.

La norma que rige este aspecto es el art. 189 del CPC, substancialmente modificado en 1988. Constituye la regla general, pero en determinados procedimientos, incluso de carácter civil, hay reglas especiales o distintas. Un ejemplo de éstas es el plazo para apelar del laudo y ordenata en el juicio de partición de bienes, que es de 15 días.

Hecha esta advertencia debemos hacer las siguientes distinciones:

1. Plazo y forma de apelar respecto de autos y decretos.
2. Plazo y forma de apelar respecto de sentencias interlocutorias.

3. Plazo y forma de apelar respecto de sentencias definitivas.
4. Plazo y forma de apelar en procedimiento oral y se cuenta con asistencia letrada.
5. Plazo y forma de apelar en procedimiento oral y no se cuenta con asistencia letrada.

La norma nos merece una crítica: parece absurdo que en ella, ubicada en las reglas comunes a todo procedimiento, se aluda a la forma de apelar en los procedimientos orales y todavía con esta distinción de si el apelante cuenta o no con asistencia letrada. Lo más razonable habría sido que el legislador hubiese reservado estos dos últimos incs. del art. 189 para las reglas específicas del procedimiento de que se trate y no haberlo incorporado en la normativa general.

1. Autos y decretos: cuando por excepción son apelables, lo que ocurre cuando alteran la substanciación del juicio o recaen sobre trámites no expresamente ordenados.

- a) En este caso, la apelación debe interponerse dentro de quinto día, o dentro del plazo especial que específicamente la norma indique.
- b) Además, la apelación debe interponerse como subsidiaria de la petición de reposición, y en consecuencia, debe entenderse interpuesta si ésta es rechazada.
- c) La apelación misma no requiere fundamentos si la reposición los contiene.
- d) La apelación no requiere de peticiones concretas si la reposición las contiene.

Insistamos que en este caso, la regla general es que la apelación se interpone dentro de 5º día, pero hay muchas situaciones en el CPC en las cuales la apelación debe interponerse en un plazo inferior, como 3º día, que es el caso de la apelación subsidiaria del auto de prueba.

Que en este caso la apelación no requiera estar fundada significa que si en la reposición se indican las razones por las cuales debe dejarse sin efecto, o modificarse el auto o decreto del que se trata, no es necesario reiterarlas en la apelación misma. En este caso tampoco la apelación requiere de peticiones concretas, porque basta que la reposición las contenga. Por ejemplo, si ésta dice, “por tanto, en mérito de lo expuesto, sírvase US., modificar la resolución que repongo en tal o cual sentido. Subsidiariamente apelo”, no requiere que la apelación misma contenga peticiones concretas.

2. Sentencias Interlocutorias.

a) La regla general es que debe apelarse derechamente y dentro de 5º día. Es decir, la apelación no se plantea como subsidiaria de la reposición, toda vez que no cabe reposición respecto de las sentencias interlocutorias. Pero como ya dijimos, ésta es sólo la regla general. Hay ciertas interlocutorias que sí pueden ser repuestas, y puede que el plazo sea distinto. Es, nuevamente, el caso del auto de prueba. Si en tal evento, respecto de la interlocutoria de que se trata es admisible reposición, la apelación debe ser subsidiaria y en el plazo específico que se indique para el caso concreto.

b) Como regla general, esta apelación debe ser fundada. Respecto de algunos recursos, y específicamente de la apelación, en ciertos casos el legislador ha dicho que debe ser “someramente fundada”. Pero tratándose de la apelación de la interlocutoria sólo dice que debe ser “fundada”. En

consecuencia, en el recurso hay que dar las razones de hecho y de derecho que sustentan la apelación. Así, cuando se dice “someramente fundada” basta una simple enunciación genérica. En cambio, cuando la ley pide que sea “fundada”, a secas, es necesario explicitar las razones de hecho y de derecho que sirven de sustento al recurso.

c) La apelación debe contener peticiones concretas. Significa que en la parte petitoria del recurso se plantean las declaraciones que el requirente pretende sean formuladas por el tribunal de alzada, indicándolas exhaustivamente y en forma precisa y determinada.

Por ejemplo, si después de un sesudo escrito de apelación, se termina diciendo “por tanto, sírvase tener por interpuesto recurso de apelación”, será inadmisibile. Lo correcto es decir “sírvase US., tener por interpuesto recurso de apelación a fin de que el tribunal de alzada declare: a) que se revoca la sentencia apelada en todas sus partes y b) que se declare en cambio a, b, c, d...).

La insistencia del legislador en esta materia se debe a que, como sabemos, uno de los límites subjetivos del recurso de apelación es la voluntad del apelante, quien es libre para dividir la resolución contra la cual se alza, aceptándola en una parte e impugnándola en otra. Sólo a través de las peticiones concretas que contiene este recurso el tribunal de alzada puede saber cuál es precisamente la parte aceptada y cuál la impugnada.

3. Sentencia definitiva: debe apelarse derechamente y en el plazo fatal de 10 días. Hubo aquí una modificación substancial. Desde el proceso romano-canónico estaba internalizado en la cultura jurídica de Occidente que el plazo de apelación era de cinco días. Sin embargo, esta reforma de 1988 amplió el plazo de apelación a 10 días, pero sólo respecto de las sentencias definitivas.

La razón de ser de esta modificación es la siguiente: antes de ella, en la segunda instancia y respecto de sentencias definitivas, y salvo norma expresa en contrario, existía un escrito fundamental, la “expresión de agravios”, en el cual se indicaban los fundamentos de la apelación deducida en primera instancia y las peticiones concretas. La reforma eliminó este escrito, y en su reemplazo exigió que se fundamentara el recurso de apelación y se indicaran las peticiones concretas. Como el término para expresar agravios era de 10 días, en homenaje a él, y para no dejar al apelante en una situación particularmente desmedrada, el legislador amplió este plazo de cinco a 10 días fatales.

4. Procedimientos o actuaciones orales, con asistencia letrada: no tiene mayor importancia porque en cada procedimiento oral el legislador ha establecido reglas especiales para interponer el recurso de apelación.

- a) De la norma pareciera deducirse (no es claro) que la apelación debe interponerse derechamente.
- b) Debe interponerse dentro de 5º ó 10º día, según la naturaleza de la resolución recurrida y salvo norma expresa en contrario en el respectivo procedimiento.
- c) Debe ser someramente fundada.
- d) Debe contener peticiones concretas.
- e) De esta apelación así deducida debe dejarse testimonio en el acta respectiva.

5. Procedimientos orales sin asistencia letrada:

- a) Debe apelarse derechamente.
- b) Sin necesidad de fundamentarla.
- c) Sin necesidad de que contenga peticiones concretas.
- d) En el plazo de cinco días, sin distinguir la naturaleza de la resolución, sin perjuicio de normas particulares de procedimiento.

4.4.1 Características del plazo para interponer el recurso de apelación



Observación

1. Es de días fatales, es decir, por su solo transcurso precluye la posibilidad de intentar el recurso.
 2. Es un plazo individual, como se desprende claramente del inc. 1º del art. 189, en relación con el art. 65, que establece la regla general de ser plazos individuales, no comunes (ambos del CPC). En consecuencia, el plazo se cuenta para cada parte desde el momento en que a ella le sea notificada la respectiva resolución. No se interponen todas juntas, sino una a una, según el momento en que se le haya notificado la resolución respectiva. Lo normal es que la notificación sea por el estado diario, y en consecuencia se realice el mismo día para todos. En este caso, el plazo vence para todos el mismo día. Pero si se trata de una sentencia definitiva de primera instancia, que se notifica por cédula, el plazo de diez días para apelar podrá vencer en días distintos, porque se cuenta desde el momento de la respectiva notificación.
 3. Es un plazo legal e improrrogable. La voluntad de las partes no puede modificarlo. En ciertos procedimientos, como el arbitral, puede fijar inicialmente plazos distintos, pero en procedimientos que se rigen por el principio del consecutivo legal, no puede modificar o prorrogar los plazos para apelar.
 4. No admite suspensión de ninguna naturaleza, lo que aparece claramente del art. 190, el cual señala que el plazo para apelar no se suspende por la solicitud de reposición, ni tampoco por la solicitud de aclaración, rectificación o enmienda.
- Recordemos que estamos en los plazos del CPC, que son de días hábiles. Pero en algunos procedimientos civiles los plazos son de días corridos, como ocurre con la apelación del recurso de protección. También en los procedimientos de quiebra ordenados por el juez.

4.5 Posibles resoluciones sobre la apelación.

Partimos de la base que fue interpuesta ante el tribunal de primera instancia que dictó la resolución contra la cual se recurre, para ante (para que sea conocida esta apelación) por el correspondiente tribunal de alzada, que por regla general será la respectiva Corte de Apelaciones. El tribunal de primera instancia debe dictar determinadas resoluciones frente a la apelación deducida ante él.

Antes de dictar las resoluciones el tribunal debe examinar tres aspectos, el llamado “estudio de admisibilidad”: 1) si la apelación se interpuso en tiempo: 2) si se interpuso en forma y 3) si se ha deducido en contra de resolución respecto de la cual sea admisible.

La admisibilidad o inadmisibilidad mira a la forma del respectivo recurso y no tan sólo se ve en el recurso de apelación, sino también y muy particularmente en los recursos de casación en la forma y fondo y de revisión.

Declarar inadmisibile un recurso significa que el tribunal no entrará al fondo de él porque tiene defectos formales que no le permiten abordar la substancia de la cuestión planteada. Si se apela al 6º día, o no se formulan peticiones concretas, necesariamente el recurso se declara inadmisibile, aunque contenga argumentos sólidos. La admisibilidad de un recurso es prerrequisito para entrar al fondo de la cuestión debatida. Si un tribunal entra al fondo de la cuestión tratándose de un recurso inadmisibile, claramente está fallando fuera de competencia, porque la competencia del tribunal para conocer de un recurso, necesariamente parte de su admisibilidad.

La necesidad de examinar la admisibilidad del recurso aparece claramente de los Arts. 196 y 203, que veremos al tratar el recurso de hecho, en cuanto a corregir admisibilidades o inadmisibilidades mal pronunciadas.

Por ahora adelantemos que lo normal es que el pronunciamiento de admisibilidad o inadmisibilidad que realiza el tribunal de primera instancia es a su vez corregible.

Practicado este examen de admisibilidad al tribunal se le abren dos posibilidades: conceder o denegar el recurso de apelación. Si lo concede no necesita dictar una larga resolución, sino basta con decir “concédese”. Pero si lo deniega, deberá fundamentar la denegatoria. Es decir, indicar las razones, disposiciones o fundamentos en virtud de los cuales se deniega el recurso de apelación deducido.

A su vez, si el tribunal concede el recurso de apelación, se le abre la alternativa de concederlo en ambos efectos, suspensivo y devolutivo a la vez, o bien en el solo efecto devolutivo.

De la esencia del recurso de apelación es el efecto devolutivo, que significa reconocer competencia al tribunal de alzada para conocer de él y revocar o modificar la resolución apelada. El efecto suspensivo es de la naturaleza de este recurso, es decir, de concederse la apelación, el tribunal pierde competencia para seguir conociendo de la cuestión.

El legislador dice que si el tribunal simplemente resuelve “concédese”, sin agregar más, se entiende que es en ambos efectos. Así aparece en el art. 193: “cuando se otorga simplemente apelación, sin limitar sus efectos, se entenderá que comprende el devolutivo y el suspensivo”.

A contrario sensu, la apelación sólo se entiende concedida en el efecto devolutivo cuando el tribunal expresamente así lo declara.

Es inconcebible una apelación sin efecto devolutivo, porque la apelación abre la posibilidad de una revisión por el superior jerárquico.

Sin embargo, el efecto suspensivo es aún hoy, teóricamente al menos, la regla general. Pero el legislador, fundamentalmente para agilizar los procedimientos, ha ido restringiendo la concesión de este recurso en ambos efectos y ha ido convirtiendo el efecto suspensivo en regla excepcional.

La expresión “el solo efecto devolutivo”, o dicho de otra forma, cuando el recurso no se concede en el efecto suspensivo, significa que el tribunal de primera instancia conserva competencia para seguir conociendo del asunto, y más aún, para cumplir la resolución impugnada. O sea, la concesión del recurso en el solo efecto devolutivo hace posible no tan sólo que siga la tramitación íntegra de la causa, sino que además la resolución impugnada se cumpla entre tanto (regla general).

Sin embargo, a veces el legislador ha puesto ciertas cortapisas, como en el juicio ejecutivo, contra la sentencia definitiva que rechazó las excepciones del deudor se concede apelación en el solo efecto devolutivo. Esto habilita para realizar los bienes embargados, pero no para pagar al acreedor (excepción).

Recordemos que al hablar de los títulos ejecutivos, vimos que la sentencia que causa ejecutoria, es decir, la que causa recurrida pero el recurso se concede en el solo efecto devolutivo, no calza en el Nº 1 del art. 434, referido a la sentencia firme o ejecutoriada, sino en el Nº 7: todos aquellos otros títulos a los que la ley da fuerza ejecutiva.

La regla general es que concedido el recurso en ambos efectos, el tribunal de primera instancia pierde competencia para seguir conociendo del asunto. Sin embargo, hay que examinar esta regla a la luz de algunos casos particulares. Por ejemplo, si el expediente, los autos, se tramitan en distintos cuadernos y la apelación se concede en ambos efectos en uno de ellos, ¿el tribunal pierde o no competencia para conocer de los otros cuadernos? El asunto es dudoso y no ha sido expresamente resuelto, pero la lógica entendería, con todas las reservas del caso, que si la apelación se concede en ambos efectos en el cuaderno principal, se produce también la suspensión de competencia en los demás.

Y por el contrario, si la apelación se concede en ambos efectos en un cuaderno distinto del principal, el efecto suspensivo y de pérdida de competencia se produce solamente en este cuaderno donde se concedió la apelación de esta manera. Es lógico, porque el desglose del expediente en varios cuadernos busca que el retardo de uno no influya en mayor tiempo respecto de los demás. (Tema opinable).

Si la apelación se concede en el solo efecto devolutivo, el tribunal a quo o de la instancia conserva la competencia y se sigue actuando en el proceso. Estas actuaciones y cumplimientos posteriores no son definitivos o irreversibles sino sub conditionem, es decir, adquirirán pleno vigor si en definitiva es desestimado el recurso concedido en el solo efecto devolutivo.

En cambio, si el recurso es acogido, la regla general es que las actuaciones y cumplimientos se retrotraen al momento inmediatamente anterior a la interposición del recurso. Sin embargo, el legislador puede limitar estos efectos.

Por ejemplo, el legislador específicamente indica que la apelación del auto de prueba es en subsidio de la reposición y en el solo efecto devolutivo. Si el tribunal de alzada, acogiendo la apelación, agrega puntos, la prueba anteriormente rendida conserva su valor.

Pero respecto de los nuevos puntos se abre un término probatorio especial que sigue las reglas de los incidentes. Es un caso en que el legislador ha señalado claramente las consecuencias de acoger la apelación deducida y concedida en el solo efecto devolutivo.

En la vida real la aplicación a ultranza de esta competencia condicionada y, en consecuencia, la necesidad de retrotraer la situación al estado anterior a la acogida del recurso, puede producir enormes conmociones procesales y substanciales.

La jurisprudencia ha sido vacilante, pero en ciertos casos ha acotado estas consecuencias condicionales y la necesidad de retrotraer que sería teóricamente la regla general irrestricta.

Que la regla general teórica es la concesión del recurso de apelación en ambos efectos arranca, en primer lugar, del art. 193, en cuanto a que la apelación concedida sin apelativo se entiende en ambos efectos. Y, más específicamente, del art. 195: “Fuera de los casos determinados en el artículo precedente, la apelación deberá otorgarse en ambos efectos”.

En el mismo sentido tenemos que remitirnos al Nº 5º del art. 194, que dice que debe concederse en el solo efecto devolutivo la apelación de todas las demás resoluciones que por mandato legal sólo admitan apelación en este efecto. O sea, debe haber ley que expresamente limite la apelación al solo efecto devolutivo, con lo que se concluye que concederla en ambos efectos es la regla general.

4.6 Límites del recurso de apelación.

Hemos dicho que el efecto fundamental de este recurso es que el tribunal de alzada adquiera competencia para revocar o revisar la resolución impugnada. Sin embargo, el tribunal de alzada no es absolutamente libre en esta posibilidad, sino que queda enmarcado por ciertos márgenes: los límites de este recurso, que son objetivos y subjetivos.

Entendemos por límites objetivos los que arrancan de la naturaleza misma del recurso de apelación y por límites subjetivos los que arrancan de la voluntad del respectivo apelante.

1. Límites Objetivos del Recurso de Apelación: se desprenden del art. 208, en cuanto a que, como regla general, el tribunal de alzada sólo puede pronunciarse, por la vía de la apelación, respecto de cuestiones ventiladas y resueltas en primera instancia.

Al decir cuestiones ventiladas en primera instancia, el legislador se refiere a que hayan sido debatidas. Además requiere que hayan sido resueltas, porque el tribunal de alzada es un tribunal revisor y es de la esencia de la revisión que haya un objeto que pueda ser revisado: la resolución que se pronunció sobre la cuestión debatida.

Cuando estudiemos la casación en la forma, veremos que si la cuestión no ha sido resuelta en primera instancia debiendo serlo, hay un claro y grave vicio formal de esta sentencia: falta de decisión del asunto controvertido. En este caso, el tribunal de alzada no puede pronunciarse sobre el asunto, sino que debe anular la sentencia de primera instancia, o eventualmente ordenar que se complete.

Pero no puede pronunciarse sobre una cuestión no resuelta en primera instancia porque la apelación es la consagración del principio de la doble instancia. Por lo tanto, si se permitiera al tribunal de alzada pronunciarse sobre cuestiones no resueltas en primera instancia, estaría fallando en única instancia y alterando este principio.

Sin embargo, esta regla general tiene una regla adicional: el tribunal de alzada puede pronunciarse sobre cuestiones ventiladas y no resueltas en primera instancia con tal que éstas sean incompatibles con lo resuelto. Es decir, si la cuestión fue discutida y hay dos o tres peticiones planteadas por el demandante o el demandado y el tribunal acoge una pero no se pronuncia sobre las demás por incompatibles, el tribunal de alzada puede pronunciarse sobre aquéllas.

Por ejemplo, en primera instancia decimos de nulidad absoluta de un contrato de compraventa, por incapacidad absoluta y subsidiariamente decimos de nulidad relativa por lesión enorme. El tribunal de primera instancia acoge la demanda de nulidad absoluta y, obviamente, no se pronuncia sobre la petición subsidiaria de nulidad relativa. El tribunal de alzada, al revisar la sentencia apelada por el demandado, estima que no hay nulidad absoluta sino relativa. Puede declararla, porque si bien es cierto no hubo pronunciamiento en primera instancia, esto se debe únicamente a que se resolvió una petición incompatible.

Por último, el legislador estableció una regla especial para el juicio sumario, en el art. 692: en segunda instancia, el tribunal de alzada puede pronunciarse sobre cuestiones ventiladas y no resueltas en primera, sin distinguir si esto fue debido a incompatibilidad u omisión.

O sea, frente a una sentencia de primera instancia en juicio sumario, que dejó de resolver el asunto controvertido, por lo que era anulable o casable, el tribunal de alzada, a título excepcional y sólo en este procedimiento, puede resolver la cuestión omitida y no casar ni ordenar completar el fallo. Se evidencia la voluntad del legislador de dar más agilidad al procedimiento sumario.

Volviendo al art. 208, es curioso que no fija la regla general sino la especial: el tribunal puede pronunciarse sobre cuestiones ventiladas pero no resueltas por incompatibles; pero no la regla general,

que sólo debe pronunciarse sobre cuestiones ventiladas y resueltas. Es una norma curiosa: el legislador explicita la excepción pero deja implícita la regla general, que se deduce a contrario sensu.

Sin perjuicio de este límite de la apelación, en cuanto a que como regla general, el tribunal de la apelación sólo puede pronunciarse sobre cuestiones ventiladas y resueltas, el art. 209 reconoce al tribunal de alzada la posibilidad de realizar declaraciones de oficio.

Recordemos que como regla general, en materia procesal civil los tribunales actúan a requerimiento de parte. Pero por excepción pueden actuar de oficio. Por ejemplo el art. 1683 del C.C., que ordena a los jueces declarar la nulidad absoluta que aparece de manifiesto en el acto o contrato; la declaración oficiosa de la incompetencia absoluta según el art. 12 del COT.

En el caso del art. 209, esta declaración debe ser hecha previa audiencia del Ministerio Público (Fiscal Judicial). Es un caso en que la ley ordena que la vista del Ministerio Público sea recabada, si bien ésta no vincula al tribunal.

Cuando el tribunal de alzada, en virtud de esta declaración de oficio declara la incompetencia absoluta, puede apelarse de esta resolución al tribunal superior jerárquico inmediato. Por ejemplo, si una Corte de Apelaciones declara la incompetencia absoluta, y consecuencialmente la nulidad de todo lo obrado, de esta resolución podrá apelarse, excepcionalmente, ante la Corte Suprema.

Es decir, las declaraciones de oficio del tribunal de alzada no son apelables, por regla general. Sólo lo serán cuando se refieran a la incompetencia absoluta.

Dentro de los límites objetivos está un principio inamovible en materia procesal civil, salvo la declaración oficiosa: la non reformatio in pejus, es decir, que el tribunal de alzada no puede modificar la sentencia en perjuicio del apelante. Lo normal es que éste sólo tenga expectativas de ganar, no de quedar en una situación más desmedrada de la que arranca de la sentencia recurrida.

2. Límites Subjetivos del Recurso de Apelación:

a) En general los recursos procesales están en el campo de la libre disposición, por lo que así como el apelante es enteramente soberano para interponer o no el recurso, lo es también para limitarlo o no. O sea, dentro de la resolución puede hacer las distinciones correspondientes y apelar sólo respecto de una parte del pronunciamiento, conformándose con el resto. Si en esta parte la resolución no es atacada por otra vía, adquiere el carácter de firme o ejecutoriada. Se puede dar entonces el fenómeno de que una misma sentencia esté parcialmente firme o ejecutoriada y parcialmente recurrida.

b) Otro límite subjetivo del recurso de apelación es su carácter de personal. O sea, las results de la apelación sólo afectan al apelante y no a otros que hayan sido parte en el respectivo procedimiento. Así, puede haber respecto de partes que estén en idéntica situación substancial dos resoluciones en un mismo juicio: una favorable para uno de ellos y otra desfavorable para su litis consorte.

4.7 Casos en que la apelación se concede en el solo efecto devolutivo.

Como ya hemos dicho, requieren ley expresa. Dentro de las reglas generales de la apelación, el CPC contiene en su art. 194, una casuística de casos en que la apelación se debe conceder en el solo efecto devolutivo. Pero hay además una serie de procedimientos especiales en los que también se señala específicamente que la apelación se debe conceder en este solo efecto.-

El art. 194 en su encabezado fija la regla general teórica: las apelaciones deben ser concedidas en ambos efectos, salvo texto legal expreso en contrario: *“Sin perjuicio de las excepciones expresamente establecidas en la ley se concederá apelación en el solo efecto devolutivo:”* y a continuación indica cinco casos, con una enumeración con criterio de taxatividad morigerada.

1º De las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios.

No se distingue la naturaleza de la resolución, es decir, sea sentencia definitiva, interlocutoria, auto o decreto, en los juicios ejecutivos y sumarios la apelación se concede al demandado en el solo efecto devolutivo.

Que el legislador hable de juicios ejecutivos y sumarios, en plural, no es un mero capricho, sino que tiene enorme importancia en función de la interpretación. Es correcto hablar de juicios ejecutivos, porque los hay por obligación de dar, hacer y no hacer, además de juicios especiales como los juicios hipotecarios y de realización de prenda.

Pero cuando el legislador habla de juicios sumarios, la jurisprudencia y la doctrina interpretan que este número no sólo se refiere al juicio sumario regulado en los Arts. 680 y s.s. del CPC, sino a todos los procedimientos sumarios o concentrados.

Por ejemplo, en un interdicto posesorio, un juicio especial del contrato de arrendamiento o cualquier otro procedimiento particularmente concentrado, las apelaciones de las resoluciones dictadas en contra del demandado se conceden en el solo efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario. Respecto de esta última hay una trascendente excepción: la apelación de la sentencia definitiva del juicio sumario, (el del 680) aunque sea contraria al demandado, debe ser concedida en ambos efectos.

Al referirse a los juicios ejecutivos, el legislador dispone que se conceda en el solo efecto devolutivo la apelación de las resoluciones contrarias al demandado.

Pero ¿qué pasa con las resoluciones dictadas a favor o en contra del tercerista? Como las reglas de excepción deben interpretarse restrictivamente, debiera concluirse que las resoluciones dictadas contra el tercerista se rigen por las reglas generales, o sea, no le sería aplicable el Nº 1 del art. 194.

2º De los autos, decretos y sentencias interlocutorias.

Fruto de una reforma introducida en 1988 que de alguna manera quebró el sistema.

Sin distinguir el procedimiento del que se trata ni si la resolución es agravante para demandante o demandado, el legislador estableció que por expreso mandato, hoy la regla general es que las apelaciones en contra de los autos y decretos y en contra de las sentencias interlocutorias de toda clase, cuando son apelables, se concedan en el solo efecto devolutivo.

Téngase presente que el legislador, al introducir este enorme forado al principio general teórico de las apelaciones en ambos efectos, creó en el recurso de apelación la ONI -- orden de no innovar -- para eventualmente limitar los efectos de la concesión del recurso en el solo efecto devolutivo.

3º De las resoluciones pronunciadas en el incidente sobre ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria.

Muy ligado con el Nº 1, porque el incidente sobre cumplimiento o ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria, es una forma de juicio ejecutivo. Lo interesante es que en este incidente de cumplimiento el ámbito es más amplio que en el Nº 1, porque no se observa si la resolución es contraria para el demandante o demandado (ejecutante o ejecutado). Todas las resoluciones que se dicten en este incidente de cumplimiento incidental son apelables, si procede, en el solo efecto devolutivo.

4º De las resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias.

Con la reforma de 1988 este numerando cuarto se tornó redundante, porque la resolución que ordena el alzamiento de medidas precautorias es un auto y, en consecuencia, por mandato del nuevo Nº 2 su apelación debe ser concedida en el solo efecto devolutivo.

5º De todas las demás resoluciones que por disposición de la ley sólo admitan apelación en el efecto devolutivo.

Refuerza el criterio general de la regla teórica de las apelaciones en ambos efectos, en el sentido que sólo por ley se puede conceder apelación en el solo efecto devolutivo.

Este criterio de regla general teórica nuevamente se reitera en el art. 195: “Fuera de los casos determinados en el artículo precedente, la apelación deberá otorgarse en ambos efectos”.

4.7.1 Ámbito de competencia



¿Cuál es el ámbito de competencia que conserva el tribunal de primera instancia cuando la apelación se concede en el solo efecto devolutivo?

El ámbito de competencia es íntegro: puede seguir conociendo del asunto como si no se hubiera interpuesto recurso de apelación. Más aún, como regla general puede llegar incluso a la ejecución de la resolución impugnada, como si en este caso tampoco se hubiese interpuesto recurso de apelación.

Así lo confirma el inc. 1º del art. 192 del CPC. Pero esta norma de carácter general ha sido atemperada por el legislador en situaciones particulares: en el juicio ejecutivo por obligación de dar, cuando esta obligación es pagar una cantidad de dinero, se puede llegar a la realización de los bienes embargados, pero como regla general no se procede al pago.

Además, la posible orden de no innovar es otra atemperación al rigor legislativo en esta materia, en el ámbito procesal civil (art. 192 inc. 2º y 3º. Se verá después).

La apelación concedida en el solo efecto devolutivo importa la tramitación y cumplimiento condicional para el tribunal de primera instancia, porque si la resolución impugnada es modificada o revocada, y esta modificación o revocación se hace incompatible con la posterior tramitación, se vuelve atrás, al momento inmediatamente anterior a la interposición de este recurso. Es decir, la tramitación subsiguiente y el eventual cumplimiento del fallo impugnado quedan sub conditionem.

Pero hay fallos judiciales en que se ha tratado de atemperar las consecuencias devastadoras que podría tener para el proceso la aplicación irrestricta del principio de condicionalidad, lo que significaría volver íntegramente hacia atrás, perdiendo lo actuado posteriormente.

4.7.2 Las compulsas

¿Cómo se logra materialmente que dos tribunales distintos conozcan en forma simultánea de un mismo asunto, frente al hecho que éste tiene una existencia corpórea que es el expediente? Por ejemplo, el tribunal de la instancia es el de Castro y el de alzada es la Corte de Puerto Montt.

El legislador dispone que en este caso se dupliquen los expedientes, lo que se debe hacer preferentemente por vía de fotocopia certificada, aplicando las reglas generales estudiadas en su momento a propósito de la formación del proceso. El art. 37 inc. final del CPC da preferencia en esta materia a las fotocopias certificadas.

Antes de que existieran las fotocopias, y aun hoy en los lugares donde no es posible obtenerlas, el legislador ordena recurrir al sistema de las compulsas.

Las compulsas son copias, hoy mecanografiadas, de partes del expediente, a fin de lograr que un mismo proceso pueda ser conocido al mismo tiempo por dos tribunales. Antiguamente las compulsas eran manuscritas. Hoy son subsidiarias de las fotocopias, y el legislador distingue ambos medios.

La resolución que ordena conceder una apelación en el solo efecto devolutivo señala precisamente las piezas del proceso que deben fotocoparse o eventualmente compulsarse.

La regla general es que si la apelación se concede en el solo efecto devolutivo respecto de la sentencia definitiva, el tribunal de primera instancia conserva las fotocopias o compulsas, para el cumplimiento de aquella sentencia y eleva a segunda los autos originales.

Pero si la apelación se concede respecto de otro tipo de resolución (auto, decreto, interlocutoria), el expediente original queda en primera instancia, y las compulsas o fotocopias son las que se elevan (197 inc. 1º).

Las piezas que deben fotocoparse o compulsarse son:

1) Las que determinan cuáles son las respectivas personerías, es decir, quiénes son demandantes, demandados, sus representantes, abogados, procuradores.

2) Aquellos elementos que de acuerdo con las circunstancias sean necesarios, ya para cumplir una sentencia definitiva impugnada o bien para dejar al tribunal de alzada en condiciones de conocer del recurso pendiente.

El apelante debe dejar en manos del secretario, dentro de los cinco días siguientes a serle notificada la resolución que le concede la apelación en el solo efecto devolutivo, dinero suficiente para confeccionar las fotocopias o compulsas. De este depósito se debe dejar testimonio en autos. Esto es muy importante, porque el plazo para hacer este depósito es fatal y de acuerdo con el inc. final del art. 197, la sanción por no hacer este depósito es la deserción del recurso de apelación. O sea, se lo tiene por no interpuesto y con ello la resolución impugnada queda firme o ejecutoriada.

Aunque esta norma no lo dice, por aplicación del art. 37 inc. final, estas fotocopias deben ser certificadas, es decir, el secretario debe verificar su correspondencia con los originales.

4.8 La orden de no innovar,

Para atemperar los efectos de la apelación concedida en el solo efecto devolutivo, el legislador introdujo dos importantes incs., al art. 192, que legislan este instituto.

La ONI fue ideada en nuestro país primero por el legislador al dar forma al “Recurso de hecho”. Posteriormente, se convirtió en creación jurisprudencial bastante más allá del recurso de hecho, y tuvo gran trascendencia en el recurso de queja. La orden de no innovar está legislada hoy respecto de los recursos de queja, inaplicabilidad por inconstitucionalidad, protección y amparo económico.

Se ha dicho que la orden de no innovar equivale a un rayo paralizante, porque significa que el expediente queda de inmediato en una situación por así decirlo “pétrea”: no se puede dar ningún paso, ni hacia atrás ni hacia adelante. El tribunal que recibe una orden de no innovar debe abstenerse de realizar cualquier actuación que pueda contravenir esta voluntad paralizante.

Sin embargo, la jurisprudencia ha ido flexibilizando la orden de no innovar en dos sentidos: 1) permitiendo que tengan un efecto más relativo, es decir, que paralice el procedimiento no en su totalidad, sino sólo parcialmente y 2) que no tan sólo tenga este efecto paralizante, sino que se retrotraiga la causa a un estado anterior al de la resolución que se reclama.

4.8.1 La orden de no innovar respecto de la apelación.

En este caso la regla general es que produzca el efecto paralizante absoluto. Pero el propio legislador permite que este efecto sea menor, y en tal evento, el tribunal que decreta la orden de no innovar limita sus consecuencias en la forma que estime del caso.

A. Dónde se plantea

Ante el tribunal de segunda instancia, y en consecuencia, es necesario que hayan llegado el original o las fotocopias a este tribunal.

Una vez presentada la orden de no innovar, el presidente de la Corte respectiva la sortea entre las distintas salas y se resuelve en cuenta, es decir, sin previa vista de la causa.

Si la orden de no innovar es concedida, el asunto se radica en la respectiva sala, o sea, la que concedió la orden y no va nuevamente a sorteo. Y tiene preferencia para ser vista, en su calidad de causa radicada (incs 2º y 3º del art. 192).

Lo que resuelva el tribunal en cuenta respecto de la orden de no innovar, sea que la conceda o deniegue, no lo inhabilita para conocer de la cuestión principal. Es lógico, y con ello se despeja cualquier duda sobre una eventual recusación basada en adelantar juicio en torno a la materia sometida a su conocimiento.

La resolución que concede o deniega una orden de no innovar es inapelable.

B. Plazo para solicitar la orden de no innovar

El legislador no lo señala, por lo cual se la puede pedir en cualquier momento. Y como se plantea ante el tribunal de alzada, es decir, la respectiva Corte de Apelaciones, esto se hace en solicitud separada, no en la solicitud en la que se deduce el recurso, porque ésta se dirige al juez de primera instancia.

4.9 Consecuencias de la apelación concedida en ambos efectos respecto del tribunal de primera instancia.

1. Como ya se dijo, la regla general es que frente a una apelación concedida en ambos efectos, el tribunal de primera instancia pierde competencia para seguir conociendo del asunto (art. 191 inc. 1º).

El inc. 2º de este art., señala una evidente excepción: esta pérdida de competencia del tribunal de primera instancia no significa que la pierda en todo lo relacionado con el recurso interpuesto. También la conserva para declarar la deserción o la prescripción de dicho recurso. O sea, todo lo que dice relación con el recurso interpuesto, sigue dentro del ámbito del tribunal de primera instancia.

2. Pese a que esta norma señala que sólo conserva competencia frente a norma expresa, se ha estimado que no obstante la apelación concedida, el tribunal puede pronunciarse sobre medidas precautorias, sea su concesión, mantención o alzamiento, y también respecto de nulidades procesales.

3. Por último, que el tribunal pierde su competencia para seguir conociendo del asunto concedida la apelación en ambos efectos, es clara si existe un solo cuaderno principal y en él se concede la apelación. Pero si existe multiplicidad de cuadernos la situación es dudosa: para algunos la apelación concedida en el cuaderno principal hace perder competencia en todos los demás cuadernos, pero la concedida en un cuaderno no principal, no hace perder competencia ni en los demás cuadernos ni en el principal.

4.10 Tramitación de la apelación.

Para los efectos de nuestro análisis nos pondremos en las dos hipótesis: concedido en ambos efectos y en el solo efecto devolutivo.

Si la apelación se ha concedido en el solo efecto devolutivo, se han confeccionado las compulsas o fotocopias según corresponda, y se remiten los autos originales, o las fotocopias, al tribunal de alzada.

Si se ha concedido en ambos efectos, es claro que los autos originales se han remitido al tribunal de alzada.

Sobre el particular, el art. 197 se refiere al inicio de esta tramitación en segunda instancia.

Hemos visto que la regla general, cuando se concede la apelación en el solo efecto devolutivo, son las fotocopias. Tratándose de sentencia definitiva, las fotocopias quedan en primera instancia y se mandan los autos originales a segunda. En cambio, tratándose de otras resoluciones, se mandan las fotocopias a segunda instancia y se conservan los originales en primera.

Pero cualquiera sea la forma, llegan a segunda los autos originales, las fotocopias o las compulsas en su caso.

La remisión del expediente, dice el art. 198, debe hacerla el tribunal inferior al día siguiente de la última notificación recaída en el escrito de apelación. Pero si hay que sacar fotocopias o compulsas, el plazo se amplía según la extensión del expediente o según el tribunal lo estime.

Cuando los autos originales o las fotocopias llegan al tribunal de alzada, se estampa un certificado de ingreso. La ley no lo dice, pero es muy importante porque en segunda instancia normalmente ocurren dos cosas:

1) se estampa este certificado de ingreso firmado por el secretario de la Corte, y

2) normalmente se dicta una resolución que, con mucha frecuencia, es la de “autos en relación”.

Lo determinante es el certificado, porque desde su fecha -- no desde la fecha de la resolución -- empieza a correr la fecha para que apelante y apelado se hagan parte en el respectivo recurso. Así se desprende del inc. 1º del art. 200, que da a las partes el plazo de cinco días para comparecer al tribunal superior a seguir el recurso interpuesto, contados desde la fecha de recepción de los autos en la secretaría del tribunal de segunda instancia. De esta recepción se deja testimonio mediante el certificado de ingreso.

Ingresados los autos al tribunal de segunda instancia, éste se pronuncia sobre su admisibilidad, conforme al art. 213. La admisibilidad es un juicio formal que mira a dos extremos: que el recurso haya sido opuesto en tiempo, es decir, oportunamente, y en forma, o sea, cumpliendo con los requisitos del recurso de apelación según la naturaleza de la respectiva resolución.

Lo normal es que este examen de admisibilidad se haga en cuenta. Pero si el tribunal tiene dudas puede ordenar que se traigan los autos en relación y resolver la admisibilidad previa vista de la causa.

Cuando el tribunal de segunda instancia estima que el recurso es admisible no lo declara expresamente, sino que ordena seguir el trámite de la apelación según corresponda. Pero cuando estima que el recurso es inadmisibile, lo declara expresamente y señala las razones por las cuales así lo estima.

Si el tribunal de segunda instancia declara inadmisibile el recurso, dictada esta resolución ordena devolver los antecedentes al tribunal de primera; si por el contrario, lo estima admisible, ordena seguir con la tramitación de la causa según corresponda.

Así se desprende del art. 214, el que sin embargo contiene un error en su oración final; en ella, el legislador parte del supuesto que la necesaria primera resolución, una vez admitido el recurso, es “autos en relación”, lo que significa que la apelación debe resolverse previa vista de la causa. Pero ocurre que

fruto de una importante reforma, que luego veremos, hay apelaciones que son conocidas en cuenta, y la resolución que se vista es “dese cuenta” y no “autos en relación”. Cuando se introdujo esta modificación no se tuvo el cuidado de modificar el art. 214, que quedó en esta parte tácitamente derogado.

4.10.1 Comparecencia de las partes.

Apelante y apelado tienen un plazo fatal para el apelante y no fatal para el apelado, para comparecer ante la segunda instancia. Como ya se dijo, se cuenta desde el certificado de ingreso, no desde la resolución, y es de cinco días.

Estos cinco días se aumentan en tres días si el tribunal a quo se encuentra dentro del territorio jurisdiccional pero fuera de su comuna de asiento, y también se aumentará según la tabla de emplazamiento si el tribunal a quo se encuentra fuera del territorio jurisdiccional del tribunal de alzada (arts. 200 a 202).

Este plazo para comparecer es uno de los elementos del emplazamiento para la segunda instancia. Cuando veamos la discusión en torno a determinar si el recurso de apelación era el mismo juicio o uno distinto, dijimos que una de las similitudes de un juicio y la apelación es que en ésta también hay emplazamiento para segunda instancia.

La importancia del emplazamiento para la segunda instancia es su carácter de trámite esencial, conforme al art. 800 Nº 1 del CPC en los juicios de mayor o menor cuantía y en los juicios especiales. Las partes deben ser emplazadas antes que el tribunal superior conozca del recurso. El emplazamiento para la segunda instancia tiene los mismos elementos del emplazamiento general, porque el concepto de emplazamiento es común: 1) notificación de una resolución determinada y 2) el transcurso de un plazo o la fijación de una oportunidad para efectuar un determinado acto procesal.

En consecuencia, son elementos del emplazamiento de segunda instancia:

a) La resolución que concede en primera instancia el recurso de apelación.

El plazo para hacerse parte en segunda instancia.

Las apelaciones ante los tribunales de alzada pueden resolverse en cuenta o previa vista de la causa. Hoy, la regla general teórica es que se vean en cuenta, y para este efecto se sortean entre las distintas salas de la Corte y con la sola cuenta del relator, ésta resuelve la respectiva apelación. Sin embargo, tratándose de sentencias definitivas, la apelación se resuelve previa vista de la causa.

Con todo, cuando se trata de una resolución que pueda resolverse sólo en cuenta, cualquiera de las partes -- apelante o apelado -- puede pedir al tribunal de alzada que la resuelva previa vista.

El tribunal de alzada necesariamente accederá a la solicitud, siempre que la parte interesada la formule dentro del plazo para comparecer. De no hacerse en él, se resolverá en cuenta.

Hemos dicho que la resolución de la apelación en cuenta es sólo la regla general teórica, porque lo normal es que apelante o apelado planteen su resolución previa vista.

En la práctica, estampado el certificado de ingreso, si la resolución recurrida es una sentencia definitiva, el tribunal de alzada proveerá “autos en relación”, lo que significa que la apelación se resolverá previa vista de la causa. Pero si no es una sentencia definitiva, el tribunal nada provee sino que espera la conducta de las partes en el plazo para comparecer. Si éstas no piden alegatos, al día siguiente de cumplido el plazo, provee “dese cuenta”, lo que significa que la apelación se resolverá en cuenta. Pero si las partes piden alegatos, proveerá “autos en relación”.

El plazo para ejercer el derecho de pedir la vista de la causa cuando se trata de resoluciones que como regla general deben verse en cuenta, es fatal tanto para apelante como para apelado (art. 199).

El inc. final de este artículo contiene una norma que ordena a las Cortes fijar horas especiales de funcionamiento para fallar las cuestiones que se vean en cuenta, la cual es poco aplicada en la práctica.

4.10.2 Sanciones por la incomparecencia.

Hay que distinguir las que afectan al apelante y al apelado.

1. Sanciones contra el apelante (art. 201 CPC): si no comparece dentro del plazo fatal de cinco días más el emplazamiento, el secretario del tribunal certifica, de oficio, este hecho (con mayor razón a petición de parte, que basta que la haga verbalmente). Con este atestado, la Corte declara la deserción del recurso de apelación a petición de parte, que puede plantearla también verbalmente, o por escrito.

La resolución que declara la deserción del recurso de apelación produce sus efectos sin necesidad de ser notificada, lo que es una calificada excepción al art. 38 del CPC, que establece como regla muy general que las resoluciones judiciales producen efectos sólo a partir de su notificación.

De esta resolución puede pedirse reposición dentro de tercero día invocando error de hecho.

Es interesante que el legislador hable de la “deserción” del recurso de apelación, con la que el apelante se convierte, procesalmente hablando, en un “desertor” de este recurso, el cual se declara “desierto”. Declarada, la resolución que fue impugnada queda firme o ejecutoriada.

2. Sanciones contra el apelado: tiene un plazo no fatal para comparecer, es decir, puede hacerlo en cualquier momento antes de que sea vista la apelación. Pero si no comparece en los cinco días más emplazamiento, 1) se le tiene por rebelde de pleno derecho, sin necesidad de notificación o resolución. 2) Además, las resoluciones que se dicten resolviendo la apelación, le producen efecto y le empecen sin necesidad de notificación y 3) si comparece después de vencido el plazo, debe hacerlo a través de procurador del número o de abogado habilitado, no personalmente. En cambio, si comparece dentro del plazo, puede hacerlo por tres vías: personalmente, por abogado o por procurador. Así se desprende del art. 398 del COT en relación con el 202 CPC.

El 398 permite la representación por procurador del número o abogado habilitado.

4.10.3 Formas de comparecencia

Hay dos formas de comparecer ante el tribunal de alzada.

1. Lo normal es por escrito: apelante o apelado se hacen parte. Se presenta el escrito, se timbra y se guarda la copia.
2. También puede hacerse parte el apelante o el apelado notificándose personalmente de la resolución que dictó el tribunal de alzada. Por ejemplo, si éste dictó “autos en relación” o “dése cuenta”, apelante o apelado puede concurrir a la secretaría y notificarse en persona de la resolución respectiva. Se entiende que con esta notificación personal se han hecho partes en el respectivo recurso de apelación. Ante las Cortes de Apelaciones se puede hacer parte el apelante o el apelado, como regla general personalmente, mediante su abogado o mediante procurador del número. Ante la Corte Suprema, no puede comparecer personalmente la parte; o sea, sólo le cabe hacerlo por procurador del número o por abogado habilitado.

4.10.4 Tramitación del decreto que conoce la apelación.

Es distinta según si se trate del decreto “autos en relación” o “dése cuenta”.

1. La más simple: cuando la corte ordena “dése cuenta”, se sortea el expediente entre sus distintas salas, por una sola vez, y se verá en cuenta con la sola participación del relator. No comparecen ni abogados ni procuradores, sino que el relator reseña el asunto y la corte resuelve. Hemos visto que para este efecto, las cortes deben fijar días especiales de audiencia para resolver las cuentas, lo que como ya dijimos es más teórico.
2. La más compleja: cuando la corte ordena “autos en relación”. En virtud de ella, la causa pasa a integrar el “rol general de causas en estado de tabla”, cuya importancia radica en que según el número de causas en él se determina si hay o no retardo en la respectiva corte. Cuando lo hay, se produce su funcionamiento extraordinario en un mayor número de salas.

Posteriormente, de acuerdo con el orden en que se van estampando las resoluciones “en relación” o dándose preferencia a causas especiales si las hay, se confeccionan las tablas (el último día hábil de cada semana), tantas cuantas sean las salas de la respectiva corte. Estas tablas se entregan a los relatores, para que conozcan las causas que deberán informar.

Estas tablas se sortean semanalmente en las distintas salas, fijándose día para la vista de la causa. Así, v.g., si una tabla con un relator se sortee una semana para la segunda sala, no significa que la próxima semana siga necesariamente en ella.

Sin embargo hay casos excepcionales: las “causas radicadas” y las “causas agregadas”.

Las causas radicadas, producida la radicación no vuelven a entrar a sorteo, sino quedan en la sala ante la cual se radicaron.

Las causas agregadas no figuran en la tabla que se publica el último día de la semana anterior, sino que previo sorteo se asignan a cualquiera de las salas de la respectiva corte.

Por ejemplo, los recursos de protección son causas agregadas que van a la sala respectiva previo sorteo. Pero la regla general es que las tablas se sortean, enteras, cada semana.

Todo ello aparece del art. 163, ubicado en el título de las resoluciones judiciales.

La tabla tiene tres menciones: 1) nombre de las partes, según aparezca en la carátula; 2) rol de ingreso de la causa ante la corte y 3) posibilidad o no de suspender la causa.

Después de confeccionadas, figuran en el anaquel de la respectiva sala, y con ello todas las causas que se verán en esa semana, según el día en que se verán. Pero ¡cuidado! Tratándose de las causas agregadas y radicadas hay que ir a unos registros especiales.

Así, v.g., empieza la audiencia del día martes. Se sabe cuáles causas se verán ese día, por estricto orden de figuración en tabla. Pero hay ciertas causas que pueden no verse, por suspensión u otros inconvenientes. Inmediatamente antes de comenzar a verse la causa, se cuelga el número de orden respectivo.

La práctica indica que el oficial de sala (el portero) debe hacer ostensible anuncio de este hecho. Se usan unos números grandes de latón, que se golpean contra el tablero haciendo ruido, y además este oficial golpea sus manos mientras vocea “causa número tanto”.

De acuerdo con el inc. 1º del art. 222, el relator debe, antes del inicio de la vista de las causas de cada día, dar cuenta de los vicios u omisiones que haya observado. Esto puede dar lugar a lo que se llama “trámites en segunda instancia”.

Por ejemplo, el abogado acompañó documentos en primera, que se guardaron en secretaría, pero al remitir el expediente no se mandaron.

El trámite será “tráigase a la vista los documentos acompañados según constancia de fojas xxx”. O una omisión más grave: la concesión del recurso no fue notificada en primera instancia. “Vuelva a primera instancia a los efectos de que sea notificada debidamente la concesión del recurso”.

Si efectivamente se ordenan estos trámites en segunda instancia, deben cumplirse previamente, por lo que no se verá la causa.

Así lo señala el art. 222, que se remite al art. 373 del COT, el cual establece entre las obligaciones de los relatores examinar los posibles vicios u omisiones que previamente deban ser subsanados.

Antes de que se inicien las vistas de las respectivas causas, cuando el relator ya ha sido llamado, se prepara lo que en jerga judicial se llama “el papelito”. Es el anuncio hecho por el relator, donde indica qué causas de esa tabla no se verán ese día pese a figurar en ella, e indica además hasta qué causa se verá según el tiempo disponible y el tiempo anunciado por los abogados para los alegatos.

En el papelito se enumeran las causas que no se verán y las razones de ello, que pueden ser: 1) suspensión de la vista de la causa, 2) hay un miembro del tribunal que está inhabilitado; 3) se ha ordenado un trámite; 4) no está el expediente ó 5) porque el relator no se preparó (situación gravísima para él). Y en el mismo papelito, se precisa hasta qué causa se verá (según el número). Cuando así lo señala, tiene la obligación teórica de ver hasta la causa que ha indicado.

Para ordenar el tiempo respectivo, los abogados que van a alegar las causas tienen que anunciarse anteladamente, anuncio que se hace al relator antes del inicio de la audiencia (entre las 8 y 8:30 am), indicando el tiempo del alegato. Si al abogado “se le pasó” anunciarse, no se le admite a la vista de la causa.

De acuerdo con un auto acordado de la Corte de Apelaciones de Santiago, ella puede ver las causas que no tienen abogado anunciado, aun cuando estén en un orden posterior al señalado en el papelito.

Por ejemplo, no obstante se haya dicho que se verá hasta la causa N° 5, pueden verse también las causas siguientes que no tengan abogado.

Complementan a este auto acordado los Arts. 222 inc. 2º y 165 N° 7 del CPC, referido éste a los posibles trámites que puede ordenar el tribunal, errores respecto de la figuración en tabla y la necesidad que en ésta se señale si hay o no la posibilidad de suspender la respectiva causa.

Esta norma se introdujo para evitar los trámites excesivos: el traer a la vista un expediente o algún documento no es causal de trámite, sino que debería verse la causa y cumplirse posteriormente el trámite. Pero en la realidad esta norma no se cumple, y las cortes siguen ordenando trámites de traer a la vista expedientes o documentos.

Cuando tiene que cumplirse un trámite, la causa sale de tabla en tanto no se cumple. Pero volverá a ella cumplido que sea, con el mismo número que originalmente tenía.

Los pequeños errores de transcripción en la tabla respecto de cómo figura la causa en la carátula del expediente, no importan suspender la vista.

Además, el relator debe dejar testimonio en la tabla si hay o no suspensiones pendientes.

4.10.5 Desarrollo de la vista de la causa

La vista de la causa tiene tres elementos: relación, alegatos y acuerdo. Así lo señala el art. 223 del CPC, complementado por la práctica y algunos autos acordados.

La relación es hoy pública para los abogados que se anunciaron para alegar, en virtud de una reforma introducida en 1994 al CPC y un auto acordado de la Suprema del mismo año. Hasta antes de ella, las relaciones eran privadas, no por disposición de la ley, sino por práctica judicial. Sólo eran públicas

cuando expresamente se pedía así. Esto significaba que los abogados perdían gran parte del tiempo de sus alegatos haciendo una relación de la apelación pendiente.

Durante la relación, los ministros pueden formular preguntas al relator, y la norma dice que éstas no los inhabilitan ni pueden invocarse a su respecto como causales de inhabilidad.

Concluida la relación, se procede a los alegatos. Comienza el abogado del apelante y luego continúa el del apelado. Si son varios apelantes, según el orden de sus apelaciones; si son varios los apelados, por el orden alfabético de las respectivas partes apeladas.

La ley permite que al término de su alegato, el abogado deje su minuta a la corte, la que puede ser ilustrativa.

Asimismo, es posible y útil que los ministros hagan preguntas o le pidan a los abogados referirse a puntos específicos. Terminados los alegatos de apelante y apelado, surge la posibilidad de las “rectificaciones de hecho”.

Consisten en que el apelante, frente al alegato del apelado, pida la palabra pero sólo para rectificar afirmaciones de hecho, no para rebatir alegaciones o argumentos de derecho. En general, los tribunales son muy estrictos y sólo admiten rectificaciones fácticas, no así replantear argumentos jurídicos.

La duración de los alegatos en las apelaciones es hoy de sólo media hora, si bien puede ser prorrogada por el tiempo que el tribunal estime conveniente, a petición del interesado.

El art. 223 consagra la libertad del defensor de enfrentar la defensa como lo estime, sin perjuicio del derecho del tribunal de pedirle que se refiera a ciertos aspectos que le son de interés.

El inc. final del art. 223 dispone que si un abogado se anunció para alegar y no concurre puede ser objeto de una grave sanción pecuniaria (una a cinco UTM, duplicable en caso de reincidencia en un mismo año calendario), salvo que acredite impedimento grave. Mientras no la solventa, queda impedido de alegar ante esa corte.

Las normas sobre apelaciones son de aplicación general, en todas las vistas de la causa, cualquiera sea el recurso. Se aplican también ante la Corte Suprema, salvo norma expresa en contrario.

El art. 224 dice que si los asuntos planteados en una apelación son independientes entre sí, y susceptibles de resolución por separado, el tribunal puede disponer que los abogados aleguen en forma separada y sucesiva sobre cada punto. Pero esta posibilidad de separación no aumenta el tiempo disponible.

El art. 225 carece hoy de importancia. Dispone que en la vista de la causa sólo pueda alegar un abogado por cada parte, y que no puedan alegar ambos (parte y abogado). Antes era posible que un no letrado alegara ante un tribunal. Pero hoy, el art. 527 del COT dispone que las defensas orales sólo puedan ser hechas por abogados.

Sobre este punto, algunos tribunales aplicando restrictivamente dicha norma sostienen que los procuradores no abogados no pueden contestar la demanda en el juicio sumario, en la medida en que esta contestación debe ser oral.

Por último, el art. 226 señala lo ya dicho en cuanto a que se prohíbe presentar y leer defensas escritas en la vista de la causa.

Vista la causa queda cerrado el debate y el juicio entra en estado de dictarse sentencia. Así lo dice el inc. 1º del art. 227.

La importancia de esta norma es que en segunda instancia también existe, con carácter de trámite esencial, la citación a oír sentencia. Pero, a diferencia de lo que ocurre en primera, donde la citación para oír sentencia es un trámite simple, que nace de la resolución respectiva y su notificación, en segunda instancia es un trámite complejo, conformado por sucesivos elementos que se van integrando.

Parte con 1) el decreto “autos en relación” y su notificación y sigue, sucesivamente, con 2) la figuración de la causa en el rol, 3) la tabla, y 4) la vista de la causa, completándose al terminar ésta.

En forma congruente, el inc. 2º del art. 227 señala que cerrado el debate y por ende producida la citación a oír sentencia en segunda instancia, nace la posibilidad para los tribunales de segunda instancia de dictar medidas para mejor resolver. Para ello se remiten al art. 159 estudiado el año pasado.

Estas medidas se cumplen en la forma, plazos y apercibimientos decretados por éste, con la salvedad que el tribunal puede actuar en pleno o cometer a uno de sus integrantes la práctica de diligencias concretas. El decretarse medidas para mejor resolver no altera cuál es el tribunal que debe fallar, que es el que intervino en la vista de la causa y decretó estas medidas. O sea, no se integra de nuevo o en forma distinta.

Hay una cuestión relativamente importante, pero de aplicación poco frecuente: la posibilidad que al conocer de una apelación, los tribunales decreten informes en derecho, a petición de alguna de las partes. Estos informes se evacúan por la o las personas a quienes el tribunal los encomienda, dentro del plazo fijado por él, que no puede ser de más de 60 días, salvo acuerdo en contrario de las partes. Se agrega al expediente y el relator debe certificar que los hechos consignados en él corresponden con los

establecidos en la causa. O sea, este informe sólo se pronuncia sobre puntos de derecho, pero debe aceptar como ciertos los hechos de la causa. Se acompañan impresos (Arts. 228 a 230).

Estos informes no pueden estimarse como medios de prueba, ya que la prueba recae sobre hechos. Sólo sirven al tribunal como antecedentes adicionales para que, eventualmente, el tribunal los considere en su fallo.

La referencia del art. 230 del CPC al 372 Nº 5 del COT se entiende como que es el relator de la causa quien debe certificar la coincidencia de los hechos consignados en el informe con los hechos de la causa.

Además de estos informes en derecho ordenados por el tribunal, es frecuente que en cuestiones complejas las partes los encarguen por propia iniciativa. Pero las normas del CPC se refieren a los informes decretados por el tribunal.

Evacuadas -- si las hubo -- las medidas para mejor resolver, o terminada la vista de la causa, debe producirse el acuerdo según las normas del COT: cuáles son los extremos que en cada caso deben concurrir para que se entienda que hay acuerdo, con las mayorías legales correspondientes.

Posteriormente se redacta el fallo y lo firman los ministros concurrentes. En esto nuestra legislación fue innovadora, porque permite que se certifique la firma. O sea, que se deje testimonio de que no firma alguno de los concurrentes a la vista y al acuerdo, por ausencia. Es decir, no es condición de validez la firma de todos los que estuvieron en la vista del acuerdo, sino de quienes se deja testimonio de que lo firmaron por estar habilitados para hacerlo.

Posteriormente el fallo se notifica por el estado diario, lo que es importante porque modifica substancialmente lo que ocurre con el fallo de primera instancia, el que se notifica por cédula. A partir de esta notificación por el estado corren los plazos para eventuales recursos de casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema.

Este fallo puede ser confirmatorio, revocatorio o modificatorio.

Será confirmatorio cuando la parte decisoria es mantenida por el tribunal de alzada; revocatorio si la parte decisoria es substituida en todo o en parte y modificatorio cuando manteniéndose la parte decisoria se modifican sus fundamentos, o bien se modifica en algo la parte decisoria. Por ejemplo, si la resolución del tribunal es “se confirma con declaración que...” estamos ante un fallo modificatorio.

4.11 Suspensión de la vista de la causa (art. 165 C.P.C.)

Es la situación que se da cuando, pese a estar la causa en la tabla respectiva para ese día, el tribunal no la ve. Es una materia muy reglamentada y se señalan las razones que legitiman una solicitud de suspensión, las que se han restringido bastante para evitar abusos al invocarlas, que retardaban innecesariamente la entrada a la vista de la causa y la resolución correspondiente.

El encabezado de esta norma dice “Sólo podrá suspenderse en el día designado al efecto la vista de una causa, o retardarse dentro del mismo día”, lo que nos da cuenta de dos mecanismos: suspensión y retardo.

La suspensión significa que la causa no es vista en el día correspondiente; el retardo, que la causa será vista dentro del mismo día, pero en un momento posterior al inicialmente fijado.

Nº 1 La causa no se ve porque se ven las anteriores, pero además por haber una continuación del día anterior. Por razones de tiempo, el día previo se vio sólo la relación de una causa, quedando pendientes los alegatos, o bien no se oyó el alegato de todas las partes.

Las continuaciones se ven después de las causas agregadas. El Código habla de “día anterior”, pero no significa el inmediatamente anterior. Dependerá de la disponibilidad de tiempo del tribunal.

Nº 2 Por falta de miembros del tribunal en número suficiente para pronunciar sentencia.

Los tribunales siempre se constituyen con número suficiente, y así aparece en el “acta de instalación”, que contiene el nombre de los integrantes del tribunal que ese día lo componen. Pero puede que alguno de los miembros esté inhabilitado, y no se pueda recomponer el tribunal con integrantes de otras salas, por lo que queda sin número suficiente para funcionar. Lo normal es que la falta de número suficiente sea consecuencia de una causal de inhabilidad que afecte a uno de los integrantes que figuran en el acta respectiva.

Nº 3 Por muerte del abogado patrocinante, del procurador o del litigante que gestiona por sí en el pleito.

Se suspende la vista por 15 días, contados desde que se notifica dicha muerte al patrocinado o mandante, para dar tiempo a designar una nueva representación que permita continuar con el recurso.

Nº 4 Por muerte del cónyuge o algún pariente cercano del abogado defensor (de cualquiera de las partes), ocurrida dentro de los ocho días anteriores al designado para la vista.

Nº 5 Las suspensiones, restringidas por sucesivas modificaciones.

La suspensión puede ser realizada de común acuerdo o a petición de cualquiera de las partes.

Si es de común acuerdo, sólo se puede suspender por una vez; a petición de las partes también se puede pedir una sola vez. El derecho a suspender se agota por la sola circunstancia de impetrarlo, aun cuando la causa por su número de orden no llegue o no habría llegado a ser vista ese día. Por ejemplo, si la causa es la Nº 15, se impetra el derecho a suspenderla, pero ese día sólo se ve hasta la Nº 10, se agota el derecho a pedir suspensión. Si son varios los litigantes que actúan por una sola cuerda, todos ellos pueden suspender por una sola vez. En total se puede suspender un máximo de dos veces.

La suspensión debe ser presentada a más tardar antes de las 12.00 hrs del día hábil inmediatamente anterior, y además, junto con suspender hay que pagar un impuesto, lo que evidencia la voluntad del legislador de desincentivar las suspensiones.

Nº 6 Es posible que el mismo día de la vista de la causa, el abogado tenga otras vistas en distintos tribunales, o deba necesariamente comparecer en otra causa. Si se trata de una vista en otra sala del mismo tribunal, o de la Corte Suprema, se deja testimonio con el respectivo relator, sin necesidad de otro certificado. Pero si el comparendo es en otro tribunal, hay que acreditarlo con el certificado correspondiente. La vista en otra sala, o el comparendo en otro tribunal, pueden traer como consecuencia la suspensión o el retardo, dependiendo de las circunstancias.

Cuando ocurre este fenómeno, la práctica indica que si hay causas ante la Corte Suprema y ante la de Apelaciones, se prefiere la primera. Si hay causas en distintas salas de una misma corte de Apelaciones, por regla general se prefiere la causa cuyo número se cuelga primero.

Pero si se trata de recursos de amparo o protección, se prefieren éstos por sobre las causas.

La del **Nº 7** ya fue vista (trámites, traer expedientes, etc.).

4.11.1 Causal de suspensión del Nº 2. Falta de miembros del tribunal en número suficiente para pronunciar sentencia.

Se produce como consecuencia de la inhabilidad de alguno de sus miembros.

Las impugnancias son una situación muy extrema, que por lo general no se produce; en cambio las recusaciones son bastante frecuentes, en especial de los abogados integrantes, designados por un año para las cortes de Apelaciones y por tres para la Suprema, que integran las respectivas salas a falta de otros integrantes.

Las recusaciones juegan especialmente respecto de los abogados integrantes por dos razones: 1) las causales son más numerosas que respecto de funcionarios titulares y 2) se puede recusar al abogado integrante sin expresión de causa.

En la vida real, el mecanismo de recusación de los abogados integrantes se ha convertido en una forma oblicua de obtener la suspensión de la vista de la causa, con la ventaja que, a diferencia de la recusación normal, la del abogado integrante puede hacerse el mismo día, antes del inicio de las respectivas audiencias. Se hace verbalmente ante el relator y la ley exige el pago inmediato de un impuesto en estampillas fiscales, para hacer efectiva esta recusación.

El legislador no quiere que estas recusaciones se usen como forma de suspensión, y al tratarlas dice que producida una recusación, el presidente del tribunal procurará -- por propia iniciativa o a petición de la contraparte -- integrar nuevamente el tribunal para que se vea la causa. Por ello, no hay que confiarse de que la recusación produzca de pleno derecho la suspensión de la vista.

Hay una disposición poco conocida y por ello poco usada, pero muy útil: el art. 166. Dispone que cuando un tribunal debe integrarse por personal distinto del ordinario, este hecho debe ser comunicado por el

relator a los abogados que han concurrido a alegar, los cuales, en el acto, deben señalar si hay alguna causal de inhabilidad respecto de estos nuevos integrantes que no figuran en el acta. O bien, señalar la causal y decir que formalmente se deducirá implicancia o recusación dentro de tercero día. Si el abogado hace uso de este derecho, se puede obtener la suspensión de la vista de la causa. Pero si en el plazo indicado no se deduce, el abogado será multado.

Otra cuestión importante respecto de implicancias y recusaciones es que cuando un ministro o un integrante de un tribunal colegiado estima que a su respecto concurre una causal de recusación, debe dejar testimonio de ella. Se entiende que las partes renuncian a ella si no la hacen valer dentro de tercero día. La ley no lo dice, pero la práctica ha aceptado que cuando un integrante de la sala deja constancia que a su respecto concurre una causal de recusación, no de implicancia, los abogados pueden renunciar a ella en el mismo acto, y se puede proceder de inmediato a la vista de la respectiva causa.

4.12 La adhesión a la apelación.

Es la expresión de voluntad del apelado que solicita que la sentencia sea modificada también en su beneficio. Este concepto está en el art. 216 que en su inc. 1º la permite y en su inc. 2º la conceptualiza, señalando que adherirse a la apelación es ***“pedir la reforma de la sentencia apelada en la parte en que la estime gravosa el apelado”***.

Imagínese que una sentencia resulta favorable en un 95% quien desestima apelar para obtener una sentencia 100% favorable, por cuanto la apelación dilatará el cumplimiento del fallo. Pero si la contraparte apela, el retardo igual se producirá. En tal evento, se adhiere a la apelación y solicita que la sentencia sea modificada en su beneficio, en la pequeña parte en que no le favoreció.

De este concepto se desprende que para que se pueda producir la adhesión, debe existir apelación pendiente. Si el apelante se desiste de la apelación, y el apelado se quiere adherir, no puede hacerlo porque ya no hay apelación pendiente. Los tribunales exigen cargo de hora respecto de los desistimientos y las adhesiones a las apelaciones, para comprobar la vigencia o no de la apelación que las sustenta.

Otro punto interesante es determinar si la apelación se concede en el solo efecto devolutivo y la adhesión, que como apelación independiente se debería haber concedido en ambos efectos modifica o no el efecto de la apelación. O por el contrario, si la apelación se concede en ambos efectos, y la adhesión, como apelación independiente se hubiese debido conceder en el solo efecto devolutivo, modifica el efecto de la apelación primitiva. Por ejemplo, apela el ejecutado -- apelación en el solo efecto devolutivo -- y el ejecutante se adhiere -- cuya apelación directa se habría concedido en ambos efectos. Esta adhesión ¿cambia el efecto en que se concedió la apelación primitiva?

La ley no lo resuelve y hay opiniones en ambos sentidos. Estimamos, con reservas, que la adhesión no cambia los efectos propios de la apelación inicial. O sea, la apelación deducida subsiste con las mismas características y efecto -- o efectos -- en que se la concedió inicialmente, sin ser afectada por la adhesión.

4.12.1 Oportunidades para adherirse a la apelación (art. 217 inc. 1º).

El apelado tiene dos oportunidades:

- 1) En cualquier momento, en primera instancia, antes de la remisión de los autos a segunda.
- 2) En segunda instancia, dentro del plazo para comparecer (5º día fatal aumentado según emplazamiento).

El escrito de adhesión tiene los mismos requisitos que el de apelación, es decir, cuando la apelación debe ser fundada y con peticiones concretas, la adhesión también debe serlo. El adherente a la apelación se convierte en un verdadero apelante, y a su respecto rigen las mismas exigencias y prescripciones que respecto al apelante directo. O sea, debe comparecer en un plazo fatal, si no lo hace tiene la correspondiente sanción y se le aplican los principios de prescripción de la apelación. De allí la remisión del art. 217 a los Arts. 200, 201 y 211.

Como ya decíamos, precluye la posibilidad de adherirse a la apelación si ésta no está vigente, por ejemplo, si el primer apelante se desiste. Se exige el cargo de horas según ya se explicó (incs 2º y 3º).

4.13 La prueba en segunda instancia.

La regla general está en el inc. 1º del art. 207: no cabe prueba en segunda instancia. Sin embargo esta norma contiene tres excepciones: dos que lo son propiamente y una excepción aparente.

Las excepciones están en los Arts. 348 y 385.

1) El art. 348 se refiere a la prueba instrumenta, permitida en segunda instancia siempre que los instrumentos se presenten hasta antes de la vista de la causa.

2) El art. 385 es la prueba confesional en segunda instancia, que puede pedirse una vez más en ella, y excepcionalmente hasta una segunda vez, cuando se alegan hechos nuevos.

3) El art. 310 contiene la excepción aparente y se refiere a las excepciones anómalas, que se pueden alegar también durante la segunda instancia: prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda.

La importancia de esto es que las excepciones anómalas son substancialmente perentorias, salvo la cosa juzgada que es mixta -- aunque no es erróneo categorizarla como perentoria. Sabemos además que por su enorme entidad, se pueden alegar en primera instancia después de la discusión y hasta antes de la citación a oír sentencia. En forma perfectamente congruente, el legislador permite alegarlas en segunda

instancia hasta antes de la vista de la causa, que cierra este trámite complejo de la citación para oír sentencia.

Cuando las excepciones anómalas se alegan en segunda instancia, deben plantarse antes de la vista de la causa, y el tribunal las falla en la sentencia de segunda instancia, en única instancia.

Además son una excepción al principio según el cual la sentencia de segunda sólo puede resolver lo ventilado y fallado en primera, ya que en este caso puede resolver cuestiones no ventiladas ni falladas en primera.

La excepción aparente al principio que no permite la prueba en segunda instancia, consiste en que tratándose de las excepciones anómalas, el tribunal puede abrir a su respecto un término probatorio, el que se rige por las reglas de los incidentes (Arts. 207 inc. 1º y 310).

La regla general de no admitir prueba en segunda instancia, tiene una calificada excepción respecto de una posible prueba testimonial en ella, la cual debe ser decretada por el tribunal como una medida para mejor resolver, pero es sui generis, es decir, distinta a las del art. 159.

Esta prueba testimonial debe 1) referirse a hechos que no figuren en la prueba rendida en autos, 2) decretársela sólo si no fue posible rendirla en primera instancia, y 3) referirse a hechos que el tribunal estima estrictamente necesarios para la acertada resolución del juicio.

Es tan exigente el legislador en este caso, que en la vida real casi nunca se ordena prueba testimonial en segunda instancia. Pero si procede, el tribunal debe abrir un término especial de prueba por un máximo de ocho días, debiendo las partes presentar listas de testigos en los dos primeros, contados desde que se les notifica la resolución por el estado diario. O sea, se aplica el término probatorio de los incidentes.

Se trata de una medida para mejor resolver sui generis, porque comparando el art. 207 con el Nº 5 del art. 159, que se refiere a la prueba testimonial como medida para mejor resolver en primera instancia, apreciamos que en ésta se permite al tribunal citar a testigos que ya declararon, para que aclaren o expliquen sus dichos. En cambio, la del art. 207 permite que declaren testigos que no han depuesto.

4.14 Incidentes durante la segunda instancia.

No se trata de revisión de sentencias interlocutorias recaídas en incidentes promovidos en primera instancia. Hablamos, por ejemplo, de si durante la segunda se produce un incidente sobre la integridad de un documento, la prueba confesional o se plantea la prescripción de la apelación.

Es muy importante tener presente que los incidentes que se promueven durante la segunda instancia son resueltos en única instancia por el tribunal de alzada. Es decir, las sentencias interlocutorias o autos dictados en segunda instancia, no son a su vez apelables, conforme al art. 210.

Tramitación: La regla está contenida en el art. 220, que da al tribunal una alternativa: los falla de plano o les da trámite incidental. En este último caso, puede existir claramente la posibilidad de prueba.

Fallo: En cuenta (regla general) o excepcionalmente ordena traer los autos en relación respecto a este mismo incidente.

Notificaciones. La regla general es que las resoluciones dictadas durante la segunda instancia, incluso la sentencia definitiva, se notifiquen por el estado diario. Sin embargo, la primera resolución debe notificarse personalmente (221). O sea, la forma de comparecer en segunda instancia es notificándose personalmente de la resolución que dicta el tribunal. Pero en la vida real esta notificación no es personal, sino tácita, y se produce por la comparecencia por escrito ante la segunda instancia. Es lógico, porque en este caso la notificación tácita reemplaza a la personal.

Sin embargo, esta misma norma recuerda que respecto del apelante rebelde no se le notifica nada. Al apelado rebelde, las resoluciones le afectan desde el momento en que se dictan, y tampoco es necesario notificarle nada. (De ahí la remisión a los Arts. 201 y 202).

El inc. 2º del art. 221 permite al tribunal ordenar una forma distinta de notificación, cuando lo estime conveniente.

4.15 Extinción del recurso de apelación.

Genéricamente hay dos formas: normal y anormal.

1. La extinción normal del recurso de apelación opera cuando se dicta la resolución de segunda instancia que se pronuncia sobre él, y que puede ser confirmatorio, modificatorio o revocatorio. Extinguido el recurso por esta vía, los autos se remiten a primera instancia, ordenándose al tribunal estampar el cúmplase respectivo y notificarlo por el estado diario, para que se proceda a ejecutar lo resuelto.

2. La extinción anormal puede revestir tres formas distintas: desistimiento, deserción y prescripción.

4.15.1 Desistimiento.

Es la explícita expresión de voluntad del apelante -y adherente, por consecuencia- de no perseverar en la apelación deducida. O sea, frente a una apelación interpuesta, o nacida de una adhesión, el apelante o adherente manifiestan formalmente su voluntad de no perseverar en este recurso. Como la apelación mira al solo interés del apelante, el tribunal lo tiene por desistido del recurso, pero podríamos decir que el desistimiento no arranca de la resolución en tal sentido, sino del acto formal del desistimiento. En él se consuma esta forma anómala de extinción.

Si bien ambas son expresiones de voluntad, no es lo mismo el desistimiento de la apelación que la renuncia a este recurso.

En nuestro ordenamiento jurídico es perfectamente posible renunciar a la apelación. En el juicio ante árbitro arbitrador hay formas tácitas para ello, cuando las partes expresamente no se lo reservan o no designan al tribunal de segunda instancia que debe conocerlo.

La diferencia substancial es que la renuncia es anterior a la interposición del recurso, mientras que el desistimiento es posterior. Para renunciar a los recursos legales se requiere el poder especial del inc. 2º del art. 7º del CPC, no así para desistirse de ellos.

En consecuencia, el mandatario con facultades ordinarias puede desistirse de un recurso de apelación.

Esta norma es de general aplicación a todos los recursos procesales.

El desistimiento del recurso de apelación puede producirse en primera o segunda instancia, y sólo precluye este derecho cuando se ha producido la vista de la causa, que pone fin al trámite de la citación para oír sentencia en la segunda instancia.

El efecto del desistimiento es que si no hay otras apelaciones pendientes, la respectiva resolución queda firme o ejecutoriada.

Desistimiento y adhesión: si la adhesión se produce antes del desistimiento, subsiste producido éste; pero si se pretende adherirse producido el desistimiento, ello no es posible.

En este desistimiento no hay incidente ni oposición posible, como en el desistimiento de la demanda. Basta la voluntad del apelante, o del adherente en su caso.

4.15.2 Deserción.

Es el término del recurso de apelación por incumplimiento del apelante de alguna de las cargas que la ley le impone, y que conlleve como sanción la deserción.

- 1) La deserción es forma anómala de poner término a este recurso.
- 2) Es una sanción al apelante, eventualmente al adherente que en verdad se convierte también en apelante.
- 3) Opera por el incumplimiento del apelante o adherente, de determinadas cargas, siempre que el incumplimiento de ellas esté precisamente sancionado con deserción por norma legal expresa.

Es decir, bien puede que el apelante no cumpla alguna carga o alguna obligación procesal (v.g., no dejar copia de sus escritos). Pero si la ley no sanciona precisamente este incumplimiento con deserción, no la hay.

Los casos de deserción son tres:

- a) Falta de depósito para la confección de las fotocopias o compulsas, según corresponda (art. 197 inc. 2º). Ya visto a propósito de la apelación.

b) No comparecencia del apelante. (art. 201 inc. 1º).

c) Falta de debido fundamento de la apelación y falta de peticiones concretas del recurso (art. 201 inc. 1º), con la salvedad de que la debida fundamentación sólo es exigible cuando la ley así lo señala.

Es posible que esta situación sea calificada de deserción del recurso de apelación, pero asimismo puede ser vista -- y quizás más propiamente -- como causal de inadmisibilidad de éste. Pero en todo caso, significa el incumplimiento de esta carga procesal por parte del apelante y que extingue anormalmente el recurso de apelación.

La declaración de deserción puede ser pedida verbalmente o por escrito, y la no comparecencia puede ser certificada de oficio por el respectivo tribunal, o bien a petición de parte.

La resolución que declara la deserción del recurso de apelación es susceptible de ser repuesta, pero, curiosamente, la reposición debe en este caso, interponerse dentro de tercero día, y no de quinto como es la regla general (art. 201 inc. 2º). Dictada la resolución, o a firme en su caso, se produce el efecto extintivo.

4.15.3 Prescripción.

Se refieren a esta institución los Arts. 211 y 212.

La prescripción del recurso de apelación es una nueva sanción frente al incumplimiento de la carga procesal del impulso. O sea, en relación con el recurso de apelación, el apelante está cargado con la necesidad de impulsarlo y si este impulso no se da oportunamente, la sanción del incumplimiento se traduce en la prescripción de este recurso.



Concepto: *“es el término del recurso de apelación, por haber dejado transcurrir ambas partes, cierto plazo sin haber realizado gestión alguna para llevarlo a efecto y dejarlo en estado de fallo”.*

De este concepto se desprende claramente que se requiere inactividad, que debe afectar a ambas partes. Así, la actividad del apelante, o la del apelado, impiden la declaración de prescripción. Pero esta actividad debe ir encaminada a impulsar la tramitación del recurso de tal manera que quede efectivamente en estado de ser resuelto por el tribunal de alzada.

La inactividad se sanciona cuando efectivamente se exige la carga de la actividad, por lo que es perfectamente posible que transcurran, v.g., varios meses y aun años sin actividad en un recurso de apelación, sin que ello conlleve prescripción. Esto sucede cuando las partes ya han realizado lo que les correspondía, y sólo por la mecánica de la espera se demora la resolución del recurso.

Ejemplo típico: se concedió una apelación en primera instancia y las partes han instado por el envío del expediente a segunda instancia. Se ha certificado su ingreso, se han hecho parte oportunamente y el tribunal ha dictado el decreto “autos en relación” o “dése cuenta”, según proceda, termina la necesaria actividad de las partes. Dependerá de la mecánica del tribunal el momento en que se resuelva en definitiva la apelación.

Esto se relaciona con el abandono del procedimiento en materia civil, que también es sanción por inactividad, siendo consubstancial a él que exista la carga de la inactividad. Así, cuando sobreviene la citación a oír sentencia, que significa que las partes ya no necesitan realizar actividad alguna, puede pasar todo el tiempo necesario sin que sobrevenga sanción por el abandono.

En materia de apelación es lo mismo: dictado el decreto “autos en relación” o “dése cuenta” no es necesaria más actividad de las partes, pues ellas han hecho todo lo posible para que el recurso sea visto.

Respecto de la duración de la inactividad para que el recurso sea declarado desierto, el legislador distingue.

- Si se trata de una sentencia definitiva sólo cabe pedir la prescripción del recurso transcurridos tres meses.
- En los demás casos, es decir, interlocutoria, auto, decreto, basta inactividad de un mes.

En ambos casos la inactividad debe ser de las dos partes y, muy importante, el plazo es de meses, no de días; en consecuencia, no se interrumpe ni suspende en días feriados. Así, v.g., si la inactividad empezó el 27 de enero, no se interrumpe el plazo por el feriado judicial.

La actividad de las partes para que se entienda interrumpido el plazo de prescripción debe ser útil, porque el art. 211 exige que ella se oriente a que el recurso quede “en estado de ser fallado”, o sea, a darle impulso a este recurso.

Así, el pedir copia autorizada, por ejemplo, no interrumpe la prescripción.

¿Ante quién se pide la prescripción?

Ante el tribunal de primera o el de segunda instancia. O sea, donde estén los autos correspondientes, relacionados con la apelación. Así, si por ejemplo, el apelante nada ha hecho para que los autos sean remitidos a segunda instancia, el apelado puede pedir la prescripción ante el tribunal de primera, incluso si la apelación fue concedida en ambos efectos.



En este aspecto, la prescripción es una calificada excepción al principio de pérdida de competencia del tribunal de primera instancia cuando la apelación es también concedida en el efecto suspensivo.

Hemos dicho que la prescripción se interrumpe por inactividad de apelante o apelado. Pero, curiosamente, cualquier gestión que realice el apelado dentro del plazo de prescripción y que no vaya precisamente encaminada a obtener la declaración, interrumpe el plazo de prescripción. En otras palabras, si v.g., pasaron dos meses y medio (imaginemos que es prescripción de sentencia definitiva) y el apelado pide copia autorizada, interrumpe con ello el plazo de prescripción y debe contarse nuevamente a partir de cero (art. 211 inc. final).

Concluimos que se refiere a una gestión del apelado, porque el inc. final del art. 211 dice: “Interrúmpese esta prescripción por cualquiera gestión que se haga en el juicio antes de alegarla”. Y el único que puede pedirla es el apelado. Si él hace cualquier gestión en el juicio, antes de alegar la prescripción, se la entiende interrumpida. Y aplicando los principios generales del derecho, la interrupción de la prescripción trae aparejada la pérdida de todo el tiempo transcurrido.

Por último, según el art. 212, la resolución que declara prescrito al recurso de apelación es reponible dentro de tercero día, fundada la reposición en error de hecho.

4.15.4 Observaciones de carácter general

Cuando la deserción o prescripción se refieren a una apelación deducida en contra de sentencia definitiva y la resolución que declara una u otra ha sido dictada por una corte de apelaciones, contra ella cabe el recurso de casación en el fondo porque se trata de una sentencia interlocutoria que pone término al juicio o impide su continuación.

Tema 5: Recurso de Hecho.

5.1 Concepto.



“Es el recurso que se interpone con el objeto que el tribunal ad quem enmiende, conforme a derecho, los agravios inferidos por el tribunal a quo al pronunciarse sobre la concesión de un recurso de apelación”.

Previamente digamos que la distinción entre tribunal a quo y tribunal ad quem no sólo está reservada al recurso de apelación, sino que también se usa a propósito del recurso de apelación. Tribunal a quo es el que dictó la resolución recurrida y tribunal ad quem es el que conoce del recurso deducido en contra de ella. Así, v.g., en el recurso de apelación, el tribunal a quo es el de primera instancia y el ad quem es el de segunda.

En la casación en la forma, el tribunal a quo es el que dictó la resolución (no necesariamente de primera instancia) y el ad quem el que conoce del recurso deducido contra ella.

De esta manera, puede ser tribunal a quo en la apelación el juez de letras (regla general); pero también puede serlo la corte de Apelaciones, cuando dicta una resolución en primera instancia, como un recurso

de amparo o de protección. Y puede ser tribunal ad quem la Corte de Apelaciones (regla general), pero también podrá serlo la Suprema.

El recurso de hecho dice relación con los posibles agravios que haya inferido el tribunal a quo al pronunciarse sobre un recurso de apelación. El agraviado puede ser tanto apelante como apelado, y el agravio puede provenir de cuatro vertientes distintas:

- 1) El tribunal a quo denegó una apelación que debía ser concedida. Es la situación más grave, extrema, y da lugar a lo que la doctrina en forma más consistente, y la jurisprudencia con vacilaciones, denominan “verdadero recurso de hecho”. Agravio al apelante.
- 2) El tribunal a quo concede en el solo efecto devolutivo una apelación que debió conceder en ambos efectos. Agravio al apelante.
- 3) El tribunal a quo concede un recurso de apelación que debió ser denegado. Agravio al apelado.
- 4) El tribunal a quo concede en ambos efectos una apelación que debió serlo sólo en lo devolutivo. Agravio al apelado.

5.2 Características del recurso de hecho.

1. Se vincula íntimamente con el de apelación, ya que los agravios que se pretende enmendar por esta vía, son consecuencia del pronunciamiento del tribunal sobre la apelación deducida.
2. Curiosamente, se interpone directamente ante el tribunal ad quem, es decir, ante el tribunal que debió o debe conocer la respectiva apelación y no ante el que se pronuncia sobre la apelación deducida.
3. Se lo califica de recurso extraordinario, ya que su interposición está legitimada por causales específicas, si bien otros sostienen que es un recurso ordinario, en la medida que tan íntimamente se vincula con la apelación, que como ya se ha dicho, es el recurso ordinario por excelencia.
4. Se interpone sin necesidad de consignación, siguiendo la regla hoy casi absoluta de todos los recursos.

Las cuatro vertientes de concesión del recurso de hecho están tratadas en disposiciones diferentes. Su procedencia en el primer caso está en el art. 203. Los demás están tratados en los Arts. 196 incs 1º y 2º. Esta distinción hecha por el legislador ha llamado a que la doctrina, y con vacilaciones la jurisprudencia, distingan entre verdadero y falso recurso de hecho.

Se reserva el nombre de “verdadero recurso de hecho” al interpuesto para enmendar el agravio nacido de la circunstancia de haberse denegado un recurso que debió ser concedido y se habla de “falso recurso de hecho” para referirse a las otras tres situaciones.

Se los considera creación doctrinaria porque el legislador no distingue entre verdadero y falso recurso de hecho con estos nombres. Aún más, de alguna manera esta distinción entre verdadero y falso recurso de hecho se ha ido desdibujando, porque nuestra jurisprudencia ha tratado de ir asimilando unos y otros, eliminando así las substanciales diferencias planteadas a nivel doctrinario.

5.3 Verdadero recurso de hecho (arts. 203 a 206).

En cuanto al plazo para interponerlo hay una técnica legislativa imperfecta que puede llevar a errores de interpretación, porque el art. 203 no lo señala, sino que se remite al art. 200, que es el plazo para comparecer en segunda instancia: 5 + 3 + TE.

Sin embargo, esta referencia es equívoca porque el plazo del art. 200 es fatal para el apelante, pero no fatal para el apelado, y además, se cuenta desde el certificado de ingreso.

Pero el plazo para interponer el recurso de hecho siempre es fatal: 5 + 3 + TE y además se cuenta desde que se notifica por el estado diario, la resolución que se pronunció denegando la apelación deducida.

El legislador debió decirlo derechamente, en vez de hacer esta remisión a un plazo que tiene o puede tener otras características.

5.3.1 Tramitación.

El inc. 1º del art. 204 dice que se interpone directamente ante el tribunal ad quem, es decir, el que debe o debió conocer el respectivo recurso de apelación. En el caso de un juez de letras, se concurre a la secretaría en lo civil de la respectiva corte. Se le pide enmendar el error y declarar que la apelación debe ser concedida. Es posible que el tribunal ad quem exija al recurrente un certificado que acredite su personería, individualización del expediente en el cual incide el recurso y fecha de la resolución denegatoria, todo lo cual se acompaña en un otrosí. Por práctica, si no se acompaña el certificado pedido, y la respectiva corte estima que ello debe hacerse, ordena agregarlo en un plazo que fija, bajo apercibimiento de tener por no interpuesto el recurso de hecho, es decir, desistido de él al recurrente.

Con los antecedentes, el tribunal ad quem pide informes al a quo; le manda un oficio con copia del recurso deducido. El tribunal a quo lo evacúa, indicando las razones por las que denegó la apelación.

La ley no le fija un plazo para informar, pero si esto no se hace en un plazo prudente, el recurrente puede pedir que se lo fije bajo apercibimiento de que se aplique una medida disciplinaria al tribunal a quo que demora en exceso este trámite.

Recibido, el tribunal ad quem le estampa decreto “autos en relación”. La ley no lo dice expresamente, pero por práctica, los recursos de hecho se ven previa vista de la causa, que es la regla general de todos los asuntos conocidos por los tribunales colegiados. Terminada su tramitación, resuelve acogiendo o denegándolo.

Si lo acoge, declara que la apelación debe ser concedida; si lo rechaza, declara que el tribunal a quo resolvió bien al denegarla.

De acuerdo con el inc. 2º del art. 204, el tribunal ad quem puede también ordenar la remisión del expediente, siempre que a su juicio sea necesaria para la acertada resolución del asunto. Y, como indica

el inc. final de este art., puede ordenar que no se innove, cuando haya antecedentes que justifiquen esta medida.

Ya nos hemos referido a la orden de no innovar como un “rayo paralizante” cuya consecuencia es que la causa respectiva quede petrificada, sin avanzar. Tal es el efecto de la orden de no innovar dada genéricamente, sin perjuicio, como ya se dijo, que la orden de no innovar puede darse también de forma más restringida.

La orden de no innovar ha ampliado su ámbito. Jurisprudencialmente primero, y luego desde el punto de vista legal. Hoy son muchos los recursos en los cuales es posible obtenerla, v.g., la apelación en lo devolutivo, el recurso de queja, el llamado recurso de repetición, el recurso de amparo económico, etc.

Pero lo importante es que la fuente primordial de la orden de no innovar, en nuestra legislación la encontramos en esta norma, y específicamente en el verdadero recurso de hecho. Ello se debe a que este recurso trata de que se conceda una apelación inicialmente denegada, que de ser concedida trae o puede traer aparejado el cumplimiento de la resolución recurrida. Para evitar o paralizar este cumplimiento se estableció la posibilidad de que el recurrente pidiese orden de no innovar.

Aunque la ley no lo dice expresamente, debemos concluir que la orden de no innovar sólo puede ser concedida a petición de parte; es decir, siguiendo la regla general de la pasividad, los tribunales no pueden de oficio concederla ni ordenar no innovar.

Pongámonos en las dos hipótesis: rechazo o acogida del recurso.

1. Rechazo del recurso de hecho: se comunica esta circunstancia al tribunal de primera instancia, y eventualmente se devuelven los autos, si se ordenaron tener a la vista. El rechazo deja sin efecto la posible ONI que se pudiera haber dictado.

2. Acogida del recurso de hecho: el tribunal ad quem declara admisible la apelación deducida. Si trajo a la vista el expediente, ordena que inicie su tramitación en segunda instancia. Si, en cambio, no lo trajo a la vista, oficia al tribunal de primera comunicando la resolución, con el objeto que se lo remita.

Si se acoge este recurso y no se ha dictado orden de no innovar, es posible que se haya realizado una serie de trámites posteriores, consecuenciales de la apelación denegada. Acogido este recurso, quedan sin efecto todas las gestiones posteriores a dicha denegatoria, que sean consecuencia directa e inmediata de la respectiva resolución (art. 206).

5.3.2 Recursos que proceden contra la resolución que falla el recurso de hecho.

Es una materia que no está legislada específicamente, sino es consecuencia de los principios generales con arreglo a los cuales han obrado doctrina y jurisprudencia:

1. Se ha concluido que contra la resolución que falla el recurso de hecho, acogiéndolo o denegándolo, no procede el recurso de reposición porque se ha estimado que dicha resolución es una sentencia interlocutoria.
2. La jurisprudencia ha estimado que tampoco admisible a su respecto el recurso de apelación, interpretando extensivamente la norma que señala que las cuestiones que se suscitan durante la segunda instancia se fallan en única instancia. Y extensivamente se ha entendido que esta es una cuestión que se suscita durante, o con motivo de la eventual segunda instancia, y en consecuencia se falla en única instancia.
Es una interpretación forzada, porque quebranta la regla general de la doble instancia y se refiere a una cuestión que no ha surgido precisamente durante la segunda instancia. Pero es un criterio reiterado en nuestros tribunales.
3. Eventualmente cabe a su respecto casación en el fondo, si el recurso de hecho incide en una apelación denegada respecto de una sentencia definitiva, porque con ello se pone término al juicio o se impide su continuación, con lo cual quedará a firme esta sentencia, que se estimaba apelable.
4. Tras la reforma al recurso de Queja, tampoco es susceptible de este recurso la resolución que falla el verdadero recurso de hecho.

5.4 Falso recurso de hecho (art. 196 inc. 1º y 2º)

El falso recurso de hecho es compatible con el recurso de reposición. Es decir, frente a cualquiera de las tres situaciones que motivan este recurso, la parte tiene la alternativa de recurrir de falso recurso de hecho al tribunal ad quem, o le pide al propio tribunal de primera instancia que enmiende el agravio.

Es muy curioso que esta situación no esté expresamente contemplada respecto del verdadero recurso de hecho, por lo cual se ha concluido, lo que es muy discutible, que no cabe reposición cuando una apelación ha sido denegada debiendo ser concedida, sino sólo cabe reposición ante el tribunal a quo en la casuística del falso recurso de hecho.

Que sea compatible con la reposición significa que no precluye la posibilidad de falso recurso de hecho por la circunstancia de recurrir de reposición.

Es decir, se pueden pedir ambos, pero la reposición no suspende el plazo para interponer el falso recurso de hecho, sino que este plazo se cuenta desde la notificación de la resolución que agravio al recurrente al pronunciarse sobre el recurso de apelación.

5.4.1 Plazo para interponerlo.

Fruto de una reforma substancial de la ley 18705, de 1988, el inc. 1º del art. 196 dispone que este plazo es el mismo que para interponer el verdadero recurso de hecho: 5 + 3 + TE.

Sin embargo, la discusión se plantea en relación a desde cuándo se cuenta el plazo para interponer este recurso: a) desde que se notifica por el estado diario la resolución que se pronunció sobre la respectiva

apelación; b) como hay apelación concedida el plazo se contaría desde que los autos ingresan a la respectiva Corte de Apelaciones.

5.4.2 Tramitación.

Aunque la ley no lo dice, implícitamente debe hacerse una distinción, porque el falso recurso de hecho se interpone, lo mismo que el verdadero, ante el tribunal ad quem. Pero pueden haber sucedido dos cosas que determinan la tramitación: que haya llegado el expediente o sus copias al tribunal ad quem, o que esto no haya sucedido.

Esto es así porque en el falso recurso de hecho siempre estamos frente a una apelación concedida, la cual importa remitir el expediente o las copias al tribunal de alzada. Pero bien puede que estos hayan llegado, como bien puede que no lo hayan hecho, en el plazo de interposición del recurso. En tal caso, la tramitación es distinta, lo que no tiene base legal sino es fruto de la práctica.

1. Si no ha llegado el expediente o las copias (esta hipótesis sólo se aplica si se estima que el plazo se cuenta desde que se notifica por el estado diario la resolución que concede la apelación). Se interpone el recurso independientemente ante el propio tribunal ad quem. Conviene acompañar el certificado respectivo, en el que conste la fecha de la resolución, la individualización del expediente y la personería del respectivo apoderado. Y puede que también el tribunal ad quem ordene acompañar el certificado y fije un apercibimiento si ello no ocurre.

El tribunal ad quem pide informes al a quo, y a diferencia de lo que ocurre con el verdadero recurso de hecho, la práctica ha señalado que este falso recurso de hecho se ve en cuenta, en cuaderno separado, y se falla por el tribunal previa cuenta.

Se ha interpretado así porque se ha dicho que el falso recurso de hecho es, en el fondo, un incidente durante la segunda instancia, la que se abrió en virtud de la concesión del recurso. Y los incidentes en segunda instancia se resuelven normalmente en cuenta, salvo que el tribunal expresamente ordene lo contrario.

2. Si llegó el expediente o las copias: el falso recurso de hecho se interpone siempre ante el superior jerárquico, pero no es necesario acompañar certificados, porque del expediente o las copias, en su caso, aparecen las características de los autos, quiénes son los apoderados y la fecha de la respectiva resolución. Por ende tampoco es necesario pedir informes, porque ya constan todos los antecedentes. Y se ordena resolver en cuenta, lo que en este caso es claro porque no hay dudas de que se trata de un incidente suscitado en segunda instancia y la cuestión se resuelve en el mismo cuaderno o en las copias que llegaron. No hay cuaderno separado.

El tribunal de alzada debe pronunciarse sobre la admisibilidad y de oficio puede declarar inadmisibile la apelación deducida o corregir la forma cómo ésta fue concebida, incluso en el evento de no interponerse falso recurso de hecho.

5.4.3 Fallo.

El **fallo** del falso recurso de hecho es comunicado, o queda estampado en el expediente o copia que se devuelve a primera instancia.

Si lo rechaza, el tribunal ad quem sigue conociendo del asunto según como fue concedido el respectivo recurso: en ambos efectos o en el solo efecto devolutivo.

Por el contrario, si lo acoge, declara inadmisibile la apelación indebidamente concedida o corrige el efecto en el que ésta fue concedida.

Si se da el caso de la apelación concedida en ambos efectos debiendo haberlo sido en el solo efecto devolutivo y el tribunal ad quem acoge el falso recurso de hecho, ordena que vuelvan los autos a primera instancia para que se siga tramitando la apelación en el solo efecto devolutivo. Surge la necesidad de copias, compulsas, remisión, siguiendo las reglas generales.

Si es el caso de apelación concedida en el solo efecto devolutivo debiendo serlo en ambos, lo comunica al tribunal a quo para los efectos de la paralización del expediente, que debe operar como consecuencia del efecto suspensivo.

5.4.4 Recursos contra el falso recurso de hecho.

Vale lo dicho para el verdadero recurso de hecho.

Tema 6: Consulta en Materia Civil.

6.1 Concepto

“Es un trámite establecido excepcionalmente en materia civil, en virtud del cual el tribunal de alzada, no obstante no mediar recurso de apelación, puede rever la sentencia del tribunal a quo y confirmarla, modificarla o revocarla”.



De este concepto se destaca:

- 1) La consulta es un trámite, no un recurso procesal. La tratamos en esta oportunidad porque tiene, o puede tener, efectos similares al recurso de apelación.
- 2) Es excepcionalísima porque en materia civil la regla muy general es la libre disponibilidad de las partes. En consecuencia, que exista posibilidad de revisión sin que previamente haya mediado voluntad de las partes escapa a esta regla.
- 3) Los casos de consulta en materia civil son sólo tres:
 - a) art. 751 CPC: juicios de hacienda.
 - b) amparo económico, que por expreso mandato de la ley que lo regula, la sentencia que deniega este recurso en primera instancia debe ser consultada a la Corte Suprema.

6.2 Límites de la consulta.

a) Objetivamente, lo mismo que con la apelación, hay materias que el tribunal que conoce de la consulta no puede abordar. Su límite objetivo característico, coincidente con la apelación, es que el tribunal de la consulta sólo puede conocer de las materias ventiladas y resueltas en primera instancia o, excepcionalmente, de asuntos ventilados pero no resueltos en primera instancia, por ser incompatibles con los resueltos. En consecuencia, el tribunal de la consulta no puede resolver cuestiones no ventiladas en primera instancia, o no resueltas siendo compatibles.

Sin perjuicio de ello, el tribunal que conoce de la consulta puede, y eventualmente debe, realizar las declaraciones que los tribunales pueden o deben efectuar de oficio. Se ha entendido que, al igual que en materia civil, estas declaraciones que el tribunal de la consulta realiza de oficio deben ser pronunciadas previa vista al Ministerio Público (Fiscal Judicial).

b) Subjetivamente, a diferencia de la apelación, en la consulta no los hay, ya que estos límites arrancan de la voluntad del apelante. En la consulta no hay apelante, no hay parte.

6.3 Tramitación de la consulta en el juicio de hacienda.

El art. 751 del CPC establece una forma particularmente expedita para que ésta efectivamente se produzca.

Deben ser objeto de consulta todas las sentencias dictadas en juicios de hacienda en primera instancia y que no se apelen, cuando son desfavorables al interés fiscal. Recordemos que la sentencia se entiende desfavorable al interés fiscal cuando no acoge en todas sus partes la demanda o la reconvención del fisco, o cuando no desecha en todas sus partes la demanda o reconvención deducida en su contra.

La forma de esta consulta es muy simple: recibidos los autos, el tribunal revisa en cuenta la sentencia y la aprueba si la estima ajustada a derecho. En caso contrario, retiene el conocimiento del asunto y señala en la respectiva resolución los puntos que le merecen dudas, ordenando traer los autos en relación. Hecho esto, se procede según las reglas generales de la apelación. Sin embargo, la vista de la causa se hace ante la misma sala que ordenó retener el conocimiento, es decir, la causa queda radicada en ella. Pero esta vista sólo se limita a los puntos de derecho indicados en la resolución que ordenó retener el conocimiento.

Para efectos de determinar cuál es la sala que conoce de ellas en la respectiva corte, las consultas se sortean por su presidente.

Esta norma se refiere a la consulta de la sentencia definitiva en un juicio de hacienda, lo que concluimos porque sólo esta sentencia se pronuncia sobre una demanda o reconvención.

En la sentencia misma que se consulta dirá “consúltese si no fuese apelada”. Si transcurrido el plazo para deducir apelación esto no ha sucedido, el tribunal ordena “elévense” (los autos a segunda instancia).

Llegados a ésta, siguiendo las reglas generales se estampa un certificado de ingreso, y la primera providencia decretada por la corte es “dése cuenta”, en cuya virtud su presidente sortea las causas en consulta entre las distintas salas.

La alternativa es que la sala a la que le corresponde la causa por sorteo la apruebe, con lo cual termina la consulta y vuelven los autos a primera instancia para efectos del cúmplase; o bien que la sala respectiva, conociendo en cuenta, retenga el conocimiento del asunto e indique los puntos a su juicio dudosos del fallo respectivo.

Si la sala retiene el conocimiento, ordena “autos en relación” y procede ella misma a la vista de la causa según las reglas generales, con la posibilidad de alegatos y relato oral y público. La vista de la causa se limita a los puntos que fueron indicados como susceptibles de revisión en la resolución que ordenó retener el conocimiento.

Tema 7: Recurso de Casación en la Forma.

7.1 Generalidades

7.1.1 Concepto.



Es un recurso extraordinario que la ley concede a la parte agraviada en contra de determinadas resoluciones judiciales para obtener su anulación cuando han sido dictadas con omisión de sus requisitos formales o dentro de un procedimiento vicioso.

7.1.2 Características del concepto.

1. Es un recurso, es decir, una manera de impugnar una resolución judicial.

Insistimos en su carácter de recurso porque más adelante veremos que existe la posibilidad de la casación en la forma de oficio, es decir, los tribunales pueden en ciertos casos y circunstancias, casar en la forma determinadas resoluciones aun cuando no se interpusiere a su respecto este recurso. Dicho de otra manera, la sentencia que declara la nulidad por alguna causal de casación en la forma puede ser consecuencia de un recurso, o bien de una declaración de oficio sin que sea necesario interponer el correspondiente recurso.

2. Es un recurso extraordinario, a diferencia de lo que ocurre con la apelación, la reposición, la aclaración, rectificación o enmienda.

Su carácter extraordinario arranca de dos vertientes: 1) procede sólo contra determinadas resoluciones y 2) procede por causales específicas. No basta expresar o señalar que la resolución es agravante, sino que hay que invocar alguna de las específicas causales que señala el legislador y que justifican o legitiman su interposición.

Esto guarda relación con los requisitos formales del escrito en que se deduce la casación en la forma, que son muy exigentes en cuanto a que se debe señalar con precisión el vicio que se invoca, la causal de ley que concede el recurso por dicho vicio y la firma de un abogado que patrocine el recurso, sin perjuicio del patrocinio de la causa.

3. Lo debe intentar necesariamente la parte agraviada. Si sabemos que de acuerdo a las reglas generales todo recurso debe ser interpuesto por parte agraviada, es decir, de la resolución de que se trate deben emanar consecuencias dañosas para la respectiva parte, porque sin agravio no hay recurso ¿cuál es la novedad? La novedad es que tratándose del recurso de casación en la forma se requiere un doble agravio: 1) debe ser agravante la resolución misma, en cuanto a que de ella efectivamente se derive un daño o perjuicio a la respectiva parte y 2) la causal o razón que se invoca debe agraviar precisamente al recurrente y no a la parte contraria. Éste es el rasgo distintivo.

Ejemplo 1) si yo acompañé un documento y el tribunal no lo tuvo por acompañado con citación de la contraparte, pero lo ponderó en mi beneficio, yo no puedo invocar la falta de citación para decir de procedimiento vicioso, porque esa falta de citación no me perjudica a mí, sino a la contraparte. Si la sentencia me hubiera sido desfavorable, no puedo invocar esta causal de falta de citación a la contraparte para recurrir de casación en la forma contra ella. 2) si yo soy demandante y en definitiva mi demanda es rechazada, no puedo invocar que esa sentencia definitiva no ponderó debidamente la prueba de la contraparte, porque ello no me desfavorece a mí, sino que por el contrario, me puede beneficiar.

4. Este recurso persigue no la reforma sino la anulación de la resolución impugnada. Es decir, que al acoger la casación en la forma, el tribunal declare nula la resolución contra la cual este recurso se dedujo. Y esta declaración de nulidad significará, como regla muy general, la necesidad de dictar una nueva sentencia que substituya o reemplace a la declarada nula. Es típicamente un recurso de anulación, no de reforma.

5. Son dos las vertientes genéricas de la casación en la forma: vicio en el fallo que se invoca o en el procedimiento en el cual este fallo se dictó. La mayoría de las causales de casación se refieren a vicios en el fallo mismo, pero algunas como la del Nº 9 del art. 768 del CPC aluden a vicios en el procedimiento,

en cuanto en éste se hayan omitido trámites esenciales según la ley o por cuyo defecto la ley expresamente establezca que hay nulidad.-

7.1.3 El agravio.

El agravio es el sustento de todo recurso procesal, es decir, que la resolución que se impugna efectivamente sea perjudicial, dañina, para la parte que interpone el recurso. No hay recurso sin agravio.

Como ya dijimos, la casación en la forma requiere de un doble agravio: en primer lugar, que la resolución misma sea perjudicial a la parte que interpone el recurso y, además, que el vicio que se invoca y que se pretende cometido, sea también precisamente perjudicial para la parte que interpone el recurso.

Por ejemplo: en un juicio ordinario, el demandado opone excepción de prescripción y la de nulidad de la obligación. La sentencia acoge la primera pero no se pronuncia sobre la segunda. El demandante es perjudicado por el fallo, en la medida que es rechazada su demanda por haberse acogido la excepción de prescripción. Es un fallo técnicamente vicioso porque en la medida en que no se pronunció sobre todas las excepciones, ha dejado de resolver el asunto controvertido.

¿En este caso, puede el demandante atacar la sentencia diciendo de falta de decisión del asunto controvertido por ni haberse pronunciado el tribunal sobre la excepción de nulidad?



La respuesta es No, porque la falta de decisión sobre esta excepción (nulidad) no lo perjudica, sino que sólo habría perjudicado al demandante. En consecuencia, no tan sólo se trata de que la resolución sea agravante, sino que el vicio que se invoca sea precisamente agravante para el recurrente.

En suma, no todo vicio da pábulo o pie para recurrir de casación en la forma, sino que se requiere que el vicio específico que se invoca sea precisamente agravante para el recurrente.

Asimismo, dijimos que este recurso es típicamente uno de anulación y no de modificación, y de ser acogido deberá dictarse un nuevo fallo.

Por último, habíamos dicho que conforme al concepto dado, el recurso de casación en la forma tiene dos grandes vertientes: vicios formales de la resolución respectiva o que ésta se haya dictado en un procedimiento vicioso.

Por la casación en la forma se intenta la nulidad procesal; es decir, una de las formas, la más paradigmática o característica, de hacer valer la nulidad procesal, es por vía de casación en la forma.

Ello, porque cuando se dice de casación en la forma se está diciendo de nulidad procesal por el recurso más típicamente dirigido a obtenerla.

Pero no es la única forma para decir de nulidad procesal, ya que ésta se puede intentar también por vía incidental e incluso usando las vías de los recursos ordinarios también se puede reclamar de vicios formales que acarreen la nulidad procesal de ciertas resoluciones judiciales.

7.1.4 Características generales del recurso de casación en la forma.

1. Se interpone ante el tribunal que pronunció la respectiva resolución y se concede para ante el que debe conocer de él, que normalmente será el tribunal superior jerárquico inmediato. Tanto en la casación en la forma como en el fondo se usan con mucha propiedad los términos de tribunal a quo y ad quem, entendiendo que es tribunal a quo el que pronuncia la resolución que se impugna y tribunal ad quem el que conoce y falla el recurso de casación en la forma.

2. Es un recurso de derecho estricto, en lo cual nuestra jurisprudencia ha sido muy reiterativa. Significa que las causales de casación en la forma están enumeradas taxativamente por la ley, y el recurso debe enmarcarse precisamente en alguna -- o varias -- de dichas causales.

Y además significa que la interposición de este recurso es solemne, en la medida que el respectivo escrito debe cumplir necesariamente con determinados requisitos formales, que si faltan se traducen en que el recurso es desechado: se lo declara inadmisibile.

Estos requisitos formales consisten en señalar el vicio que se invoca, la ley que concede el recurso por el vicio invocado y el patrocinio específico de un abogado para el recurso de casación en la forma, sin perjuicio del patrocinio genérico en la causa, en todo caso puede ser el mismo abogado de la causa.

3. Se interpone para resguardar intereses de carácter privado, es decir, en beneficio de quien se siente agraviado con la respectiva resolución.

Pero hay que reconocer que en virtud de la interposición de este recurso se puede obtener un beneficio de carácter general, que mira efectivamente al recto ejercicio de la actividad jurisdiccional.

Esto, porque en el fondo del fondo, por vía de casación se está diciendo del incumplimiento de presupuestos procesales y, en consecuencia, este recurso mira al valor superior del debido proceso. Pero, en todo caso, éste se cumple cuando el recurrente invoca su interés particular.

4. No constituye instancia. En virtud de ella la causa no es revisada desde el punto de vista fáctico o del conflicto jurídico, sino se revisa la resolución en función del cumplimiento o incumplimiento de requisitos formales o de trámites esenciales en el respectivo procedimiento. No hay revisión de hecho y derecho.

La importancia de que este recurso no sea instancia es:

a) la sentencia que se pronuncia sobre una casación no es a su vez apelable, porque no se está pronunciando en primera instancia, sino que lo hace sobre el recurso, que no constituye grado jurisdiccional; y

b) la sentencia que falla la casación en la forma no es definitiva, interlocutoria, auto ni decreto, sino lo que se llama "sentencia sui generis": la sentencia de casación.

No es sentencia definitiva porque ésta pone fin a la instancia, resolviendo el asunto controvertido, y, reiteremos, la casación no es instancia; no es interlocutoria porque no resuelve un incidente ni se pronuncia sobre un trámite. Mucho menos es un auto o un decreto.

7.2 Resoluciones contra las que procede este recurso.

Conforme al art. 766 incs 1º y 2º del CPC, la casación en la forma procede:

1) Contra sentencias definitivas de cualquier instancia, es decir, primera, segunda o única. En consecuencia, este recurso es eventualmente compatible con el de apelación, porque si procede contra una sentencia de primera instancia, significa que ella es también recurrible por vía de apelación. O sea, pueden convivir respecto de una sentencia de primera instancia los recursos de casación en la forma y apelación. Veremos después que hoy el legislador exige que si se intentan ambos recursos, se los deduzca simultáneamente y en una misma petición.

Cuando se dice de casación en la forma, se dice de nulidad. Cuando se dice de apelación se dice de validez del fallo, pero de error en la decisión. En consecuencia, técnicamente son incompatibles porque si yo digo de apelación reconozco validez, pero si digo de casación niego la validez, porque alego nulidad. El legislador subraya esta clara contradicción entendiendo que el recurso de apelación es subsidiario de la casación, o sea, que el tribunal sólo se pronunciará sobre la apelación si desestima el recurso de casación.

Además, que proceda contra sentencias de cualquier instancia nos dice también que el recurso de casación en la forma es eventualmente compatible con el recurso de casación en el fondo, el que se puede interponer respecto de sentencias definitivas inapelables dictadas por una corte de apelaciones.

Aquí hay nuevamente una antinomia substancial entre ambos recursos porque, cuando se dice de casación en la forma se alega nulidad de la sentencia por vicios formales; pero cuando se dice de casación en el fondo, se reconoce validez formal a la sentencia pero se alega su nulidad substancial por infracción de ley decisoria.

En consecuencia, lo mismo que con la apelación, cuando se interponen casación en la forma y en el fondo, se hace conjuntamente y en un mismo escrito, y debe entenderse que el recurso de casación en el fondo es subsidiario de la casación en la forma.

Insistiendo en que la casación en la forma cabe contra toda sentencia definitiva, sin importar su instancia, es relativamente frecuente ver recursos de casación en la forma contra sentencias de única instancia, como sucede hoy respecto de una serie de resoluciones dictadas por las cortes de apelaciones en los llamados "recursos de reclamación". Así, una cantidad de leyes especiales, vg, la del Banco

Central, la de la Superintendencia de Valores y Seguros, la de Municipalidades, conceden recursos de reclamación ante las respectivas cortes de apelaciones, que los fallan en única instancia. Contra estos fallos, la casación en la forma procede, es admisible.

Asimismo, el recurso de casación en la forma cabe en toda clase de juicios o procedimientos, siempre que se trate de sentencias definitivas (o de otras categorías que ya señalaremos), salvo que expresamente la ley haya vedado el recurso. Un caso típico de prohibición de este recurso es el inc. 2º del art. 766: no cabe respecto de juicios que se refieran a la constitución de juntas electorales ni a reclamaciones de avalúos que se practican con arreglo a la ley de impuesto territorial.

Son casos excepcionales a la regla general, que es la admisibilidad de este recurso en toda clase de juicios.

Cuando la casación en la forma no es admisible en un determinado juicio, la jurisprudencia ha declarado, sin embargo, que sí procede la casación de oficio, porque lo inhibido es sólo el recurso, y no esta segunda posibilidad.

Además, en ciertos procedimientos especiales, aun cuando sea admisible la casación en la forma la ley limita las causales por las cuales se puede recurrir. Es decir, son cosas distintas su admisibilidad genérica y su eventual inadmisibilidad específica.

2) Las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. Es decir, este recurso no es admisible contra toda clase de interlocutorias, sino sólo respecto de las interlocutorias que cumplen estas particularidades. Por ejemplo, la sentencia que declara el abandono del procedimiento; la que acepta el desistimiento de la demanda; la que declara la prescripción de una apelación deducida contra la sentencia definitiva; la que declara la deserción del recurso de apelación respecto de una sentencia definitiva; la que rechaza el recurso de hecho deducido contra la sentencia definitiva.

3) Las sentencias interlocutorias que, aunque no pongan término al juicio ni hagan imposible su continuación, **hayan sido dictadas en segunda instancia sin previo emplazamiento de las partes o sin fijar día para la vista de la causa.** Se trata de dos situaciones distintas. Hay que tener presente que se trata de interlocutorias dictadas en segunda instancia, no durante ésta. La diferencia, recordemos, es que las interlocutorias dictadas en segunda instancia lo son en virtud de un recurso de apelación; mientras que durante la segunda instancia se dictan en única instancia y en cuenta.

Primer caso: dictadas sin previo emplazamiento de la parte agraviada. Se refiere al agraviado en función del recurso de apelación, que puede ser tanto demandante como demandado. En consecuencia, significa sin previo emplazamiento del apelante.

Sabemos que emplazamiento significa notificación por el estado de la resolución que concede el recurso de apelación más un plazo para comparecer ante la segunda instancia, que en este caso es de quinto día contado desde el certificado de ingreso.

O sea, si la interlocutoria se dicta en segunda instancia, sin que se haya notificado la resolución que concedió el recurso, o sin esperar un plazo para la comparecencia, esta sentencia siendo interlocutoria y a pesar de no poner término al juicio ni impedir su continuación, es casable en la forma.

Segundo caso: interlocutoria dictada en segunda instancia que, aunque no ponga término al juicio ni haga imposible su continuación, lo haya sido sin señalar día para la vista de la causa. Es un caso muy particular porque no toda sentencia interlocutoria que deba dictarse en segunda instancia debe ir precedida necesariamente de vista de la causa. La regla general teórica es que las interlocutorias en segunda instancia se resuelven en cuenta, es decir, sin previa vista de la causa. Y sólo se resolverán previa vista de la causa si alguna de las partes pide oportunamente alegatos.

Entonces hay que concordar esta vertiente de casación en la forma con la modificación según la cual la regla general teórica es que las interlocutorias en segunda instancia se vean sólo en cuenta.

7.3 Causales de casación en la forma.

Destaquemos en primer término que la enumeración es taxativa. La taxatividad de estas causales arranca del inc. 1º del art. 768 del CPC: "El recurso de casación en la forma) ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes". Precisamente, es decir, sólo, necesariamente, exclusivamente.

Digamos en primer término que las ocho primeras causales del art. 768 se refieren a vicios formales de la sentencia y sólo una, la del Nº 9º, a vicios en el procedimiento en el cual se dictó la sentencia que se impugna. En todo caso se impugna la resolución: en los ocho primeros por vicios propios; en el último, por vicios en el procedimiento en el cual se la dictó.

7.3.1 Causales de impugnación por vicios formales de la sentencia misma.

Nº 1 En haber sido la sentencia por un tribunal incompetente o integrado en contravención a lo dispuesto por la ley.

Se trata de dos situaciones perfectamente distintas: que el tribunal sea incompetente o que haya sido integrado contraviniendo lo dispuesto por la ley.

a) La primera situación -- incompetencia -- abarca tanto a los tribunales unipersonales como colegiados, en tanto la segunda sólo es aplicable a estos últimos, porque las reglas de integración se refieren a ellos.

En cuanto a la incompetencia, en la medida en que la ley no distingue puede ser tanto absoluta (en relación con la jerarquía del tribunal, determinada por el fuero, la materia y la cuantía) como relativa, determinada por el territorio.

Ha surgido la duda de si esta causal de casación en la forma puede también invocarse cuando se dice de falta de jurisdicción.

Por ejemplo, se designa a un árbitro para resolver un conflicto, pero en su sentencia se excede del encargo y se pronuncia sobre cuestiones distintas. Su sentencia sería viciosa por salirse de su ámbito jurisdiccional.

O bien, un órgano no jurisdiccional se atribuye jurisdicción y en tal calidad pretende dictar una resolución jurisdiccional.

La respuesta es Sí, porque si bien es cierto que los conceptos de jurisdicción y competencia son distintos, están en relación de género a especie, respectivamente. Por ende, cuando falta jurisdicción también, consecuencialmente, falta competencia. Por ello se ha concluido que la falta de jurisdicción es también reclamable invocando esta causal.

b) La segunda situación de esta causal: tribunal integrado contraviniendo lo dispuesto por la ley.

Recordemos al respecto que hay normas de integración de los tribunales colegiados, tanto ordinarios (cortes de Apelaciones, Corte Suprema) como especiales (Corte Marcial, Corte Naval, Comisión Resolutiva Antimonopolios, Tribunal de Marcas y Patentes, etc.). Se trata de mecanismos que determinan el número de miembros que forman cada uno de éstos. En las cortes de Apelaciones se sortea, el 1º de marzo de cada año, la composición de cada sala, con todos sus integrantes (en la Suprema es una regla especial) y se fija la composición ordinaria de cada tribunal.

Y sabemos que a falta de un ministro titular o por inhabilidad suya, se requerirá integrar la sala con personal extraordinario, que se llama especialmente (de otras salas, el fiscal de la respectiva corte cuando puede integrarla, los abogados integrantes según una fórmula determinada).

Si el tribunal ha sido debidamente integrado para conocer la respectiva causa y dicta sentencia, es también causal de casación en la forma. Pero esta disposición hay que concordarla con el inc. final del art. 769, en cuanto a que la errónea integración debe ser reclamada por la respectiva parte o su abogado o procurador antes de verse la causa, entendiéndose que si no lo hace en tiempo, precluye su posibilidad de recurrir de casación en la forma por este motivo.

Después veremos que en general las causales de casación en la forma deben ser reclamadas, pero ésta debe serlo específicamente antes de la vista de la causa.

Nº 2 En haber sido pronunciada por un juez, o con la concurrencia de un juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente.

Esta causal se refiere tanto a tribunales unipersonales como colegiados ("por un juez" = tribunal unipersonal; "con la concurrencia de un juez" = tribunal colegiado).

Este juez debe estar, 1) o legalmente implicado, o 2) estar pendiente o 3) declarada a su respecto una causal de recusación.

Tratándose de implicancias, que es el compromiso más grave que tiene el juzgador, ni siquiera es necesario que haya sido reclamada, sino sólo que la causal exista, porque la implicancia y su causal debe ser declarada de oficio por el tribunal e importa tal grado de compromiso y manifiesta pérdida de imparcialidad que el juez que falla afectándole causal de implicancia comete el delito de prevaricación. Y a consecuencia de esto, es posteriormente declarada la nulidad del fallo por la vía de casación en la forma.

Por ejemplo: respecto de un ministro de corte de Apelaciones concurre la causal de implicancia de ser hermano de doble conjunción de uno de los litigantes, supongamos el demandante, quien gana el juicio por 2 a 1, pero el voto en contra es el de su hermano. ¿Puede decir de casación en la forma la parte perjudicosa? La respuesta es sí: por la sola circunstancia de concurrir al fallo este implicado, aun cuando su opinión fue distinta, la parte perjudicosa tiene este derecho. Si bien es cierto el implicado no concurrió al acuerdo, sí lo hizo al pronunciamiento.

En cambio, respecto de la causal de recusación, que importa un compromiso más tenue entre el juez y las partes en conflicto, no tan sólo se requiere que exista sino que debe estar reclamada o ya resuelta acogiéndola. Es obvio que si está resuelta rechazándola, dejó de concurrir.

Nº 3 En haber sido acordada en los tribunales colegiados por menor número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley o con la concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de la causa, y viceversa.

Sólo se refiere a sentencias de tribunales colegiados. Distinguimos cuatro casos.

a) La primera situación que se contempla es que la sentencia esté acordada por menor número de votos. Según el art. 168 del CPC, los autos, las sentencias interlocutorias y las definitivas deben ser dictados por los tribunales colegiados concurriendo al menos tres de sus miembros. Sólo los decretos pueden ser dictados por uno de sus miembros.

La expresión "acordada por menor número de votos" hay que entenderla a la luz de los Arts. 72 y 103 del COT, en virtud de los cuales una sentencia está acordada cuando a su respecto concurre la mayoría absoluta entendida respecto de al menos un fundamento de cada una de las decisiones. Esta causal dice que si la sentencia ha sido acordada por una mayoría inferior a la absoluta es casable en la forma.

Así, en las cortes de apelaciones, en que la regla general es la composición de tres ministros por sala, la mayoría absoluta es que dos de ellos concurren al acuerdo. Algunas cortes tienen salas de cuatro ministros, caso en que para la mayoría absoluta en el acuerdo deben concurrir tres. Y en la Suprema, en que de ordinario las salas funcionan con cinco ministros, el acuerdo de mayoría absoluta lo dan tres.

b) El segundo caso de este numeral es la sentencia pronunciada por un menor número de jueces. En este caso el tribunal respectivo tenía una integración numérica menor que la exigida por la ley. Por ejemplo, una sala de la corte de apelaciones sesionaba con dos miembros o una de la suprema con

cuatro. En este caso, la sentencia también es viciosa, aun cuando los que hayan concurrido al acuerdo hayan sido suficientes.

Por ejemplo, si la sala estaba compuesta por cuatro de cinco miembros y todos concurrieron unánimemente al acuerdo, se ha alcanzado la mayoría para el acuerdo, pero no para el pronunciamiento. Acuerdo y pronunciamiento son dos cosas distintas.

c) La sentencia fue pronunciada por jueces que no asistieron a la vista de la causa. Aunque se hayan llenado las mayorías necesarias para el acuerdo, este hecho la hace viciosa.

d) Que haya sido pronunciada sin la concurrencia de un juez que asistió a la vista de la causa. Es la situación inversa de la anterior. De acuerdo a nuestra legislación, no es requisito de validez que todos los jueces que concurrieron a la vista y al acuerdo firmen el fallo.

Se puede certificar la ausencia si se deja testimonio que concurrió a la vista y al acuerdo. Pero en estos casos la ley persigue que todos los jueces que concurrieron a la vista lo hagan al pronunciamiento, y que si algún juez no concurrió a la vista, no puede tampoco concurrir al pronunciamiento.

Esta causal del Nº 3 del art. 768 es de muy rara ocurrencia, porque hay una mecánica en que el relator deja testimonio de la integración de la sala, el número y la identidad de los jueces que concurrieron a cada una de las oportunidades.

Nº 4 En haber sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley.

Esta causal tiene enorme importancia y es aplicable tanto a tribunales unipersonales como pluripersonales o colegiados. La ultra petita tiene en nuestra legislación dos aspectos perfectamente distinguibles: dar el tribunal más de lo pedido o extenderse a puntos no sometidos a su decisión. Doctrinariamente, a la primera se la llama ultra petita propiamente tal, y a la segunda extra petita, pero nuestro legislador se refiere como un todo a la ultra petita.

a) **"Otorgar más allá de lo debido"**. Sabemos que en materia procesal civil los términos del conflicto están dados por las respectivas pretensiones y contrapretensiones de las partes, que tienen la virtud de enmarcar el actuar del tribunal. Si éste excede el marco y da más allá de lo debido, se está pronunciando fuera de los límites del conflicto. Y en estricto derecho, en realidad se pronuncia fuera de su competencia, que está determinada por las pretensiones y contrapretensiones.

Ejemplos: i) en un juicio reivindicatorio el demandante pide que, en definitiva y a consecuencia de serle reconocida su calidad de propietario no poseedor, se ordene que le sea devuelto el fundo "La Estrella", limitando su pretensión a él. El tribunal le estaría dando más de lo pedido si ordena además la restitución de sus aguas, que no fueron reivindicadas por el demandante. ii) se demanda indemnización de perjuicios por \$ 100 millones "o la cantidad que Su Señoría determine" y el tribunal recogiendo esta

forma en que se le da competencia ordena que sean \$ 150 millones. También hay ultra petita. iii) se pide condenar al pago de determinada cantidad más intereses. El tribunal hace mal si accede al pago de la suma más reajustes, si estos no fueron pedidos.

b) "Extenderse a puntos no sometidos". Significa resolver cuestiones que no le han sido planteadas. Por ejemplo si se demanda resolución del contrato el juez no puede declararlo relativamente nulo al mismo tiempo.

Peticiones sometidas por las partes a decisión del tribunal. Recordemos que al estudiar las reglas comunes a todo procedimiento veíamos que en las presentaciones judiciales, hay propiamente una parte petitoria. Hay una forma más o menos ritualística, en que la parte final de la respectiva aseveración es seguida por la frase "por tanto", a continuación de la cual se señalan concretamente las peticiones sometidas a decisión del tribunal.

Se recomienda que al demandar o al contestar una demanda y pedir una tacha, este extremo debe ser particularmente examinado y cuidarse de plantearlo correctamente, porque es aquí donde se señala qué es lo que se pretende y enmarca la posibilidad de decisión del tribunal, porque si se excede de este planteamiento puede precisamente caer en ultrapetita.

Esta parte petitoria va, normalmente, al final del respectivo escrito. Pero cuando se trata de recursos procesales, es necesario que la parte petitoria esté también perfectamente clara, porque, vg, cuando se apela una sentencia de primera instancia, es el apelante quien determina la competencia del tribunal de segunda. Y si la corte va más allá de lo planteado por el apelante, también puede caer en el vicio de ultra petita. O sea, ésta debe ser examinada no tan sólo en función de los escritos fundamentales del respectivo juicio, sino también en función de los escritos de apelación o de los recursos correspondientes, que, insistamos, delimitan la competencia de segunda instancia.



Casos

La ultrapetita en sus dos aspectos, decíamos, guarda relación estrecha con la causal de incompetencia del tribunal, porque lo que las partes no le han planteado, o que éste no pueda revisar de oficio, queda fuera de su órbita. En consecuencia, la causal de ultrapetita es en sí misma una posible expresión de incompetencia del tribunal.

Expresamente el N° 4 del art. 768 señala que la ultra petita es sin perjuicio, o sea, no alcanza, a la facultad del tribunal de hacer las declaraciones oficiosas que la ley le impone (obliga) o permite (faculta).

Por ejemplo: según el art. 1683 del CCv, el juez puede y debe declarar la nulidad absoluta del acto o contrato cuando aparece de manifiesto. Si la declara oficiosamente, aunque no se le haya pedido y concurren circunstancias legitimantes, no hay nulidad procesal. O si el tribunal declara su incompetencia absoluta en la sentencia, aunque no haya sido pedida, no hay nulidad procesal ya que la ley se lo impone.

Esta norma debe entenderse concordada con el art. 160 del CPC, que también señala el ámbito del posible pronunciamiento del tribunal en el sentido que "las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso, y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio".-

Cuestiones anexas: es importante dilucidar algunas cuestiones en función de la posible causal de ultrapetita.

a) La primera es el raciocinio jurídico: hay que concluir que el juez no queda ligado por los planteamientos o raciocinios jurídicos de las partes. Un juez especialmente docto, imaginativo o que quiere lucirse en definitiva y redacta una sentencia reflejo de su versación jurídica no cae en causal de ultrapetita. El juez es soberano para señalar toda clase de razones adicionales o complementarias que fundamenten su respectiva decisión.

b) Cuando la calificación jurídica del tribunal es distinta de la que han hecho las partes. Por ejemplo, si yo demando para que se restituyan determinados bienes, invocando mi calidad de fideicomisario, ¿puede acceder el tribunal, pero aceptando mi calidad no de fideicomisario, sino de usufructuario? O bien pido restitución de un bien en mi calidad de comodante y el tribunal accede pero por estimar que yo soy depositante. En definitiva, cuando el tribunal accede al beneficio jurídico invocado pero haciendo una calificación jurídica distinta de la invocada por la parte. La respuesta es que esta calificación jurídica puede ser distinta, en tanto el beneficio jurídico que se concede sea el que efectivamente reclama el actor.

c) Respecto de la decisión del asunto controvertido, es decir, para determinar si hay o no ultrapetita, hay que tener en cuenta también que en nuestra tradición jurídica existen los denominados "considerandos resolutivos": en la estructura del fallo no tan sólo en la parte propiamente resolutive es en donde se ve la resolución del fallador, sino también en estos considerandos que, como su nombre lo indica, van resolviendo puntos que en definitiva serán acogidas, o bien pueden no serlo, en la parte decisoria del fallo. Por ende, para determinar si una sentencia cae o no en el vicio de ultrapetita hay que ver tanto la parte resolutoria como, eventualmente, los considerandos resolutivos que pueda contener.

d) Se ha planteado si el tribunal puede condenar en costas si no hay petición en tal sentido en los escritos fundamentales (demanda, contestación). Algunos fallos han señalado que ello es posible, porque es una forma de sanción que pueden aplicar oficiosamente. Es dudoso, pero es la tradición de la jurisprudencia sobre el punto.

Por último, agrega que a diferencia de lo que ocurre en la legislación anglosajona, en nuestra legislación no existe la llamada "indemnización sancionatoria", es decir, el tribunal no puede dar, por concepto de daño moral, por ejemplo, más de lo pedido en la demanda.

Nº 5 En haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170.

El art. 170 del CPC contiene los requisitos de la sentencia definitiva, sea ésta de primera, segunda o única instancia, con la salvedad que si se trata de una sentencia definitiva de segunda instancia, y la de primera contiene los requisitos, basta que la de segunda se remita a ésta. Como este art. 170 contiene los requisitos sólo de la sentencia definitiva, no es posible recurrir de casación en la forma por esta causal respecto de la sentencia interlocutoria, cuya omisión de requisitos formales no es reclamable por casación en la forma.

El Nº 5 del art. 768 debe ser concordado, además del art. 170, con el auto acordado de la Corte Suprema, de 1920, sobre forma de las sentencias (en apéndice del CPC), que amplía substancialmente el contenido del art. 170.

Sin embargo, para los efectos de casación en la forma, basta remitirse al art. 170. No es necesario señalar los numerales del auto acordado que posiblemente se han infringido o quebrantado en la sentencia recurrida.

Hay que tener presente que cuando se recurre de casación en la forma por omisión de los requisitos del art. 170, en el recurso hay que hacer referencia, tanto a este numerando 5º del art. 768 como al numerando específico del art. 170 que se alega quebrantado. Así, vg, si la sentencia no tiene las consideraciones de hecho y de derecho necesarias, el fundamento del recurso debe ser el Nº 5 del art. 768 en relación con el Nº 4 del art. 170. O sea, hay que invocar ambas disposiciones en conjunto, porque ellas enmarcan precisamente la causal específica del recurso.

Esta causal del 768 Nº 5, en relación con el art. 170 del CPC, es quizás la causal más recurrida, porque uno de los mayores reclamos contra la sentencia que se casa en la forma es la indebida ponderación de la prueba. Se reclama invocando el Nº 5 del art. 768 y el Nº 4 del art. 170 que contiene las consideraciones de hecho y de derecho, porque es en las consideraciones de hecho en donde el juzgador debe examinar individual y conjuntamente la prueba rendida.

Y si se ha omitido este examen individual y conjunto, la sentencia es claramente viciosa. No se trata de reprochar la calidad de los considerandos, sino sólo la omisión de la necesaria ponderación.

En este aspecto, de falta de requisitos de la sentencia, hay una cuestión importante que debe ser destacada. La sentencia debe ser consecuencia de una concatenación lógica lo más perfecta posible, de modo que un considerando sea el antecedente lógico del siguiente y así sucesivamente.

En no pocas ocasiones, los fallos contienen considerandos contradictorios, tanto respecto de aspectos de hecho como de derecho, porque en la vida real muchas veces los fallos no son producto de una sola

sino de varias manos, que en momentos y con criterios distintos, dicen en un considerando lo que en el siguiente se niega.

La jurisprudencia ha reiterado que cuando los considerandos son contradictorios se destruyen entre sí y en consecuencia, al fallo le pueden faltar los considerandos necesarios, que es lo mismo que si no tuviese parte considerativa. Así es casable en la forma.

Nº 6 En haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado oportunamente en el juicio.

Esta causal de casación en la forma, a diferencia de la anterior, se puede referir tanto a una sentencia definitiva como a una interlocutoria, siempre que la excepción de cosa juzgada se haya invocado en el respectivo juicio. En la medida que medie la triple identidad entre dos sentencias, y la primera esté firme o ejecutoriada, la segunda es viciosa si decide una cuestión distinta de la decidida en primera.

El antecedente que se invoca para decir de este vicio puede ser una sentencia definitiva anterior, o una interlocutoria anterior. No olvidemos que la interlocutoria de primera clase produce también el efecto de cosa juzgada.

O sea, si la sentencia posterior, sea definitiva o interlocutoria, desconoce una anterior, sea también definitiva o interlocutoria, cae también en este vicio.

Asimismo, la sentencia anterior puede haber sido dictada en otro juicio como en el mismo. Ejemplo clásico: el auto de prueba -- sentencia interlocutoria de segunda clase -- que señala los hechos materia de prueba. La sentencia definitiva dice que en la medida que no probó un hecho indicado por ella, y que no estaba en el auto de prueba, se rechaza su pretensión. Se dice en esta sentencia de vicio o infracción por haber sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada: el auto de prueba. Si la sentencia exigió probar extremos distintos, claramente contradecía a la interlocutoria dictada por el mismo tribunal.

Es requisito sine qua non para alegar esta causal que precisamente se haya invocado la excepción de cosa juzgada. Hay que tener presente que esta excepción tiene un tratamiento muy particular: se puede invocar como dilatoria y como anómala. El legislador abre un amplio espectro para reclamar de la cosa juzgada, pero siempre que se haya invocado como excepción en el respectivo juicio.

Tiene importancia al concordarlo con el art. 810 Nº 4 del CPC, que señala entre las causales del recurso de revisión que la sentencia cuya revisión se pretende haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta no se haya reclamado en el juicio.

O sea, tenemos aquí dos visiones perfectamente distintas:

a) para que opere la causal de casación en la forma de haber sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, la excepción de cosa juzgada debe haber sido invocada en el juicio.

b) en tanto, para que pueda prosperar el recurso de revisión invocando cosa juzgada, en el segundo juicio no se la puede haber invocado.

Esto es del todo lógico, porque si la causal no se invocó en el juicio, nunca se puede decir de sentencia viciosa, porque el juez no tenía cómo precaver el error en que, eventualmente, pudiera haber incurrido.

Pero en función de la autoridad de cosa juzgada, siempre aquella sentencia será susceptible de revisión.

Nº 7 En contener decisiones contradictorias.

Debemos concordar esta causal con el art. 170 Nº 6 del CPC, que exige entre los requisitos de la sentencia definitiva, que resuelva todas las acciones y excepciones que se han opuesto, con la sola exclusión de las que sean incompatibles con las resueltas.

La resolución de todas las acciones y excepciones con este alcance, debe ser un todo congruente, armónico. Sería inaceptable que una sentencia cayera en contradicción respecto de sus decisiones, porque desde el punto de vista lógico si ella se contradice en cuanto a su parte decisoria, estas decisiones contradictorias se destruyen recíprocamente, y al hacerlo, a la sentencia le falta la decisión del asunto controvertido, que es su objetivo esencial.

Nuevamente digamos que hay posibles considerandos decisorios, que podrían entrar en contradicción con la parte resolutive misma de la sentencia, y en consecuencia producirse esta antinomia que destruye recíprocamente estos dos elementos y deja a la sentencia sin la correspondiente decisión.

Es decir, no tan sólo para ver si existe decisión del asunto controvertido hay que ver la parte decisoria misma, sino hay que verla en relación con posibles considerandos de carácter decisorio.

Nº 8 En haber sido dada en apelación legalmente declarada desierta, prescrita o desistida.

Se refiere tanto a la sentencia definitiva como a la interlocutoria y dice relación con la competencia del tribunal de alzada, que sólo la tiene en función del recurso de apelación. Si éste ha sido declarado prescrito, desierto o se lo ha tenido por desistido, el tribunal de alzada no tiene competencia y su sentencia será viciosa, pudiendo ser anulada específicamente por dicha causal.

Hay nuevamente un problema de competencia: se abre la del tribunal de alzada por el recurso de apelación; en consecuencia, si éste no subsiste, la competencia y todo lo que resuelva el tribunal de alzada después de terminada su competencia, es manifiestamente vicioso y anulable por esta causal. Se aplica tanto a la sentencia definitiva como a la interlocutoria.

7.3.2 Causal referida a vicios en el procedimiento en que se dictó el fallo

Es la del número 9 del art. 768.

Nº 9 En haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad.

En general las normas de procedimiento fijan rituales solemnes, por la necesidad de llenar determinadas exigencias formales, pero el legislador no quiso caer en excesos. Por ello distinguió en los procedimientos entre trámites esenciales y no esenciales y sólo castiga con la posibilidad de casación en la forma de la sentencia dictada en un juicio en que se hayan omitido trámites declarados esenciales, es decir, que miran a presupuestos procesales de gran jerarquía.

En otras palabras, no cualquier trámite omitido acarrea la nulidad del respectivo procedimiento, sino que en función de la casación, debe ser un trámite que mire a la esencia de los presupuestos procesales que se pretende resguardar.

Pero no tan sólo aquí se permite la anulación del fallo cuando se han omitido trámites esenciales en el respectivo procedimiento, sino también se permite la casación cuando se ha omitido un requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad.

Al usar el término "expresamente", el legislador quiere decir que no todo vicio o defecto acarrea nulidad, sino que la ley debe indicar precisamente que el defecto o la omisión de que se trata acarrea, específicamente, la nulidad.

De los muy pocos casos citados sobre el particular si es que no el único, tenemos el art. 61 inc. final del CPC, que señala que la omisión de la firma en una actuación judicial del ministro de fe que debe dar testimonio de ella, es esencial para la validez de la actuación.

Este numeral contiene dos vertientes para recurrir de casación en la forma: 1) haberse omitido un trámite esencial ó 2) haberse omitido uno cuya falta haya sido precisamente castigada con nulidad por el legislador.

Para facilitar la aplicación de este numerando 9º del art. 768, el legislador ha señalado los trámites esenciales en primera, única y segunda instancia en los juicios de mayor o menor cuantía y en juicios especiales, los trámites esenciales ante arbitradores y los trámites esenciales en juicios de mínima cuantía; por ello, tenemos que concordar este numeral 9º con las respectivas normas.

A. Primera vertiente de casación en la forma:: omisión de trámites esenciales.

I. Trámites esenciales en primera o única instancia en juicios de mayor o menor cuantía y en juicios especiales: art. 795 del CPC.

Este art. señala que, en general, son trámites o diligencias esenciales en dichos juicios. Sus siete numerandos miran, en general, a presupuestos o principios procesales fundamentales.

1º) El emplazamiento de las partes en la forma prescrita por la ley.

Este trámite mira esencialmente al principio de la bilateralidad de la audiencia, es decir, la posibilidad de ser debidamente llamado a presencia del tribunal para hacer valer sus alegaciones, ya que es presupuesto procesal fundamental el debido emplazamiento de las partes. La forma del emplazamiento dependerá, obvio, del respectivo procedimiento.

Es interesante observar que el debido emplazamiento, que nos parece tan esencial, no existe en los llamados "procedimientos monitorios", en los cuales primero se produce la ejecución o el cumplimiento de lo resuelto, abriéndose luego una estrecha posibilidad de controversia.

En nuestra legislación existen, vg, la liquidación de las acciones dadas en prenda a un banco, los juicios hipotecarios especiales en favor de instituciones financieras. Los recurrentes han dicho que estos dos procedimientos debieran entenderse derogados en virtud del principio del racional procedimiento, establecido por la actual Constitución. Sin embargo, la Corte Suprema, en un fallo redactado por el ministro Marcos Libedinsky resolvió lo contrario, es decir, la subsistencia de los procedimientos monitorios no obstante la norma constitucional y el Nº 1 del art. 795 del CPC.

2º) El llamado a las partes a conciliación, en los casos en que corresponda conforme a la ley.

La reforma de septiembre de 1994 al art. 262 del CPC, recordemos, introdujo la conciliación como trámite esencial, terminada la discusión, en todo juicio civil en que es admisible la transacción, salvo en aquellos en que por específico mandato judicial no proceda, como en los juicios en que se discute el estado civil de las personas.

3º) El recibimiento de la causa a prueba cuando proceda con arreglo a la ley.

Conforme al art. 318 del CPC, habiendo hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, debe recibirse la causa a prueba, salvo que las partes pidan lo contrario, de común acuerdo.

4º) La práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir indefensión.

Dentro de este numerando se envuelven tres requisitos sucesivos:

a) que alguna de las partes solicite en tiempo y forma, es decir, en la oportunidad procesal que la ley contempla, la práctica de alguna diligencia probatoria. De acuerdo a la naturaleza del medio probatorio, es distinta la oportunidad para solicitar la práctica de diligencias probatorias, si bien la regla general es que se plantee necesariamente durante el probatorio, pero sabemos que en algunos casos puede hacerse antes, y en otros, después; b) que el tribunal deniegue esta solicitud y c) que de esta denegatoria se derive una situación de indefensión para la parte afectada, es decir, que quedan frustradas algunas posibilidades de defensa.

5º) La agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto de aquella contra la cual se presentan.

Fue reformado en 1989. Originalmente se exigían sólo agregación y citación, pero dada la naturaleza del documento, hay apercibimientos distintos al hecho de ser acompañados, como el del instrumento

privado: tenérselo por reconocido si no es objetado dentro de sexto día cuando se pretende que emana de la parte contraria, o las copias simples, que se tienen por acompañados como instrumentos públicos si no son objetados en cierto plazo.

La reforma amplió el ámbito de aplicación de este numerando al hacer referencia al apercibimiento que corresponda. Para que el trámite sea considerado esencial, debe tratarse de agregación de instrumentos presentados oportunamente, es decir, en el momento que corresponda según la norma procedimental respectiva. Normalmente con citación, regla general del acompañamiento de documentos, pero también bajo el apercibimiento legal que corresponda, el que -- lo mismo que la citación -- siempre son en relación con la parte contra la cual se pretende que tenga valor probatorio.

La prueba instrumental tiene en nuestro sistema una particular jerarquía y muchas veces es una prueba preconstituida, es decir, preexistente al conflicto en que se invoca. Para que la prueba instrumental conserve su "pureza" intrínseca se requiere dar oportunidad a la contraparte para observarla (nulidad, falta de integridad, falta de autenticidad, insinceridad). En otros procedimientos, donde se reducen los trámites esenciales, se conserva el Nº 5 del art. 795, reiterando la importancia que da el legislador a la oportunidad que se concede a la parte contra la que se hace valer un documento para que lo pueda observar de acuerdo a las vías que consulta nuestro ordenamiento.

6º) La citación para alguna diligencia de prueba.

Esta norma debe concordarse con el art. 324, que señala que toda diligencia probatoria debe practicarse previo decreto del tribunal que conoce de la causa, notificado a las partes.

El término "citación" tiene varios significados en nuestro ordenamiento. En este caso no es la orden de comparecer a la diligencia probatoria, como en el caso de la citación a los testigos o al inculpado; tampoco es medida de aseguramiento -- la más leve -- respecto del inculpado o procesado.

En este caso, citación es poner en conocimiento de la parte que se está realizando, o se va a realizar, una diligencia probatoria.

Por ejemplo, si una parte solicita la práctica de un peritaje, o absolución de posiciones, o cualquier otro medio, el tribunal proveerá "como se pide con citación", es decir, reconoce a la contraparte la oportunidad para oponerse a la práctica de esta diligencia.

La citación es, en este caso, la notificación por el estado diario de la resolución que ordena la práctica de una diligencia probatoria, y la concesión de un plazo fatal de tres días para que la parte contraria se oponga a la respectiva diligencia.

Esto dice estrecha relación con lo ya explicado sobre las actuaciones procesales o judiciales, que en ciertos casos se ordenan con citación, que tiene el mismo sentido y alcance que en este caso.

7º) La citación para oír sentencia definitiva, salvo que la ley no establezca este trámite.

Recordemos que la citación para oír sentencia tiene la virtud de cerrar el debate, y a partir de ese instante dejan de ser posibles la discusión, la prueba misma y las observaciones a la prueba rendida. En nuestro sistema, antes de ciertas modificaciones la citación para oír sentencia estaba contemplada básicamente para el Juicio ordinario. Hoy, en cambio, se ha ampliado su ámbito y es trámite necesario

en la mayoría de los procedimientos, tal como dice esta norma, salvo que la ley no lo establezca. Hay que concordarla con los Arts. 432 y 433 del CPC, referidos precisamente a este trámite.

II Trámites esenciales ante arbitradores.

El art. 796 señala una norma particular cuando el respectivo juicio llevado en primera o única instancia, y sea de menor o mayor cuantía, se realiza ante árbitros arbitradores, es decir, quienes tramitan conforme a las normas señaladas por las partes en el acto constitutivo del compromiso o subsidiariamente con arreglo a las normas mínimas del CPC y que fallan aplicando su prudencia y la equidad.

Como es lógico, el legislador del CPC disminuye los trámites esenciales tratándose de estos juicios. Las partes pueden determinar los trámites esenciales en el procedimiento fijado por ellas, pero a falta de esta fijación sólo tienen el carácter de tal los señalados en los N°s 1º y 5º del art. 795; esto es, el debido emplazamiento en la forma prescrita por la ley y la agregación de documentos y la citación u oportunidad para observarlos. Nuevamente de esta norma se destaca claramente la enorme importancia que reconoce el legislador a la prueba instrumental, al dar a la contraparte esta posibilidad para impugnar.

III Trámites esenciales en segunda instancia en juicios de mayor o menor cuantía y en juicios especiales (art. 800 CPC)

En general -- dice este artículo -- son trámites o diligencias esenciales en la segunda instancia de los juicios de mayor o de menor cuantía y en los juicios especiales los señalados en sus cinco numerales.

1º) El emplazamiento de las partes, hecho antes de que el superior conozca del recurso.

Se refiere al recurso de apelación, porque es la única llave de la segunda instancia. El emplazamiento para segunda instancia es la notificación por el estado diario de la resolución que la concede y el plazo para comparecer, que se cuenta desde el certificado de ingreso, que es de cinco días fatales más tabla. Si no se ha producido este emplazamiento, la sentencia dictada en segunda instancia ha sido dictada en un procedimiento vicioso.

2º) La agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto de aquélla contra la cual se presentan.

Vale lo dicho respecto de los trámites esenciales en primera instancia: agregación de instrumentos con citación por regla general, o bajo el apercibimiento que corresponda a la naturaleza del instrumento.

3º) La citación para oír sentencia definitiva.

Ya sabemos que en primera o única instancia la citación para oír sentencia es un trámite simple, que se traduce en una resolución que dice nada más eso: "cítase a las partes a oír sentencia", que se les notifica por el estado diario.

Pero en segunda instancia, este trámite es complejo, compuesto por una serie de sucesivas actuaciones. Se inicia con el decreto "autos en relación", sigue con el ingreso de la causa al rol general

de las causas en estado de tabla, la publicación de las tablas y su sorteo entre las distintas salas, el día de la vista de la causa y la vista misma compuesta por la relación y los eventuales alegatos.

Este trámite complejo sólo procede cuando la causa se resuelve previa vista, es decir, cuando se ordenan autos en relación, y no en cuenta. Es decir, cuando la ley ordena que se actúe previa vista de la causa.

4º) La fijación de la causa en tabla para su vista en los tribunales colegiados, en la forma establecida en el art. 163.

Este numeral es claramente redundante, porque si la fijación de la causa en tabla para ser vista es parte de la citación para oír sentencia, el legislador no requería señalar un numerando especial.

5º) Los indicados en los números 3º, 4º y 6º del art. 795, en caso de haberse aplicado lo dispuesto en el art. 207.

Se trata de reglas referidas a la prueba (recibimiento de la causa a prueba, práctica de diligencias probatorias cuya omisión pudiera producir indefensión y la citación para una diligencia de prueba.

El art. 800 se remite íntegramente al 795 en la materia, pero con una calificación: en los casos de haberse aplicado lo dispuesto en el art. 207.

Recordemos que la recepción de la causa a prueba en segunda instancia es muy excepcional, y sólo procede en los casos del art. 207. Es decir, si es del caso aplicar este artículo y se recibe la causa a prueba, son trámites esenciales los ya indicados.

IV Trámites esenciales en juicios de mínima cuantía.

Art. 789: En estos juicios sólo se considerarán diligencias o trámites esenciales, el emplazamiento del demandado en la forma prescrita por la ley para que conteste la demanda, el acta en que deben consignarse las peticiones de las partes y el llamado a conciliación, y el emplazamiento de las mismas para que ocurran ante el tribunal de segunda instancia a seguir el recurso de apelación, cuando se haya interpuesto y proceda.

B. Segunda vertiente de casación en la forma: omisión de un trámite sancionada expresamente por la ley con nulidad.

La ley da carácter muy excepcional a esta situación, al punto que el único caso citado en que expresamente la nulidad es la sanción por una determinada omisión es el art. 61 inc. final del CPC: tratándose de actuaciones donde concurren las partes, la autorización del funcionario a quien corresponda dar fe o certificar el acto es esencial para la validez de la actuación.

7.3.2 Causales de casación en la forma en juicios establecidos en leyes especiales.

El inc., antepenúltimo del art. 768 no se refiere a causales de casación en la forma en juicios especiales, sino de juicios establecidos en leyes especiales.

Los juicios especiales son todos los distintos al matriz, el Juicio ordinario. Por ejemplo, el juicio ejecutivo, el juicio sumario, los interdictos posesorios, los juicios del contrato de arrendamiento, todos los cuales están en el CPC. A ellos se aplica lo ya estudiado.

En cambio, la excepción que estamos estudiando, se refiere a juicios establecidos en leyes especiales. A su respecto, la regla general es que también es procedente la casación en la forma, salvo excepción expresa. Pero este recurso de casación en la forma tiene menor número de causales que la casación en la forma del Juicio ordinario y de los juicios especiales.

Este inc., antepenúltimo del art. 768 se remite, en primer término, al inc. 2º del art. 766, que dispone que como regla general la casación en la forma procede respecto de las sentencias dictadas en juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, salvo que se trate de juicios referidos a la constitución de juntas electorales y a las reclamaciones de avalúos practicados conforme a la Ley de Impuesto Territorial.

Respecto de sentencias dictadas en juicios regidos por leyes especiales en que procede la casación en la forma -- la mayoría -- las causales de ésta son más restringidas que respecto de las sentencias dictadas en juicios ordinarios o en los juicios especiales regidos por el CPC. En consecuencia, sólo vale invocar casación en la forma en estos casos basada en los números 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º y 8º del art. 768, y en el número 5º sólo cuando se omitió en la sentencia la decisión del asunto controvertido.

Pero las demás causales del art. 170 del CPC no son reclamables en estos juicios, así como tampoco es aplicable el Nº 9º del art. 768, ya que en ellos no existen trámites esenciales.

La razón de esta norma es que en forma creciente se han ido estableciendo procedimientos en leyes especiales, v.g., reclamos contra resoluciones del Banco Central, de la Superintendencia de Valores y Seguros, de alcaldes o concejos municipales, del Código Sanitario, Minero, etc.

La importancia de esta norma es que uno de los "caballos de batalla" más recurridos en el recurso de casación en la forma es la omisión en la sentencia de los requisitos del art. 170. Y precisamente esta causal no es admisible en los procedimientos establecidos en leyes especiales.

Para calificar cuándo se trata de una ley especial, el criterio de la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido, preferentemente, de calificar como tales incluso ciertos códigos, y por ende los procedimientos en ellos regulados. Ha estimado, vg, que los códigos minero, sanitario y tributario son leyes especiales, y respecto de los procedimientos que ellos regulan se permite una casación en la forma restringida.

7.4 Limitaciones al recurso de casación en la forma.

7.4.1 Concepto

"Son ciertas cortapisas que ha establecido la ley para desestimar el recurso, no obstante concurrir la respectiva causal y haber sido interpuesto en tiempo y forma".

El legislador señala que no obstante concurrir la causal, que el recurso se haya interpuesto en tiempo y forma y exista el agravio para el recurrente, en el doble sentido de ser agravante la resolución y el vicio que se invoca, el juez que debe fallar la casación en la forma puede desestimarla. Es un forado gigantesco, porque en definitiva queda entregado a criterio del juzgador el



rechazar el recurso, no obstante existir la causal y el agravio y haberse interpuesto el recurso en tiempo y forma.

7.4.2 Justificación.

Para algunos es insólito que existan estas cortapisas respecto de un recurso tan importante, que mira precisamente a la corrección del procedimiento y a presupuestos procesales fundamentales.

Las razones de ser de esta limitación son: 1) economía procesal: hay ciertos motivos que en definitiva llevan al legislador a elegir siempre el camino procesalmente menos dispendioso. Por ello, podrá desestimar la casación en la forma si hay otra vía menos gravosa para solucionar el vicio y 2) la buena fe procesal: el principio de la nulidad procesal debe ser del todo coincidente con aquélla, por lo que no es admisible que el recurrente se guarde una posible causal de nulidad para hacerla valer sólo si la decisión en definitiva le desfavorece. Por esto, la ley exige explicitar las causales de nulidad procesal para que sean oportunamente corregidas y sanciona gravemente en función de la casación en la forma, la reserva indebida de esta causal con la finalidad antedicha. Además 3) el proceso es un medio, no un fin en sí mismo.

Si la finalidad perseguida se ha alcanzado en forma debida, no será necesario recurrir a la vía extrema de la anulación del fallo, no obstante que el vicio efectivamente haya ocurrido y se haya reclamado de él interponiendo el recurso en tiempo y forma.

7.4.3 Estudio de las limitaciones.

Estas limitaciones son cuatro: la necesaria preparación del recurso de casación en la forma, que el agravio sea reparable por una vía menos onerosa que la invalidación del fallo, que el vicio no haya influido substancialmente en lo dispositivo del fallo y que tratándose de falta de decisión del asunto controvertido se ordene completarlo en vez de casarlo en la forma.

A. Necesidad de preparar el recurso de casación en la forma. El inc. 1º del art. 769 da el concepto de "preparar" este recurso. Es un aspecto importante, porque la falta de preparación del recurso de casación en la forma es causal de que gran cantidad de ellos sean desestimados. La necesidad de preparación del recurso mira a su admisibilidad; es decir, su falta debe llevar aparejada su declaración de inadmisibilidad: el tribunal no se pronuncia sobre la causal invocada sino declara que al no haber sido preparado, el recurso es inadmisibile.

El reclamo de que se trata debe ser planteado por el agraviado, es decir, el que es hoy recurrente ayer tuvo que ser necesariamente reclamante. En otras palabras, el reclamo formulado por la contraparte no sirve de antecedente de preparación para el propio recurrente. Por ejemplo, si no se recibió la causa a prueba y el demandante reclamó de ello, el demandado no puede, al ir de casación, invocar la reclamación del demandante, sino que debe ser reclamo propio. Es indispensable que quien entabla el recurso haya reclamado de la falta.

La reclamación debe ser oportuna, para que se entienda preparación eficaz. Es decir, el reclamo debe hacerse en el momento en que la falta se produce, de acuerdo con los plazos y momentos señalados por el legislador del CPC. Además debe reclamarse en todos los grados, es decir, agotando los recursos procesales para que la falta respectiva sea reparada.

Ejemplo 1) El demandado advierte que el tribunal es incompetente y recordemos que la incompetencia del tribunal es causal de casación en la forma. En función de la preparación, la primera oportunidad para reclamar de la incompetencia en el Juicio ordinario es mediante la excepción dilatoria de incompetencia. Se tramita y en definitiva se desecha en primera instancia. Si el demandado no apela de esta resolución no se entiende preparado el recurso de casación porque no se agotó en todos los grados. Pero si se apeló y la corte de Apelaciones confirmó la sentencia, ya se ha cumplido con el requerimiento de preparación, y cuando se dicte sentencia de primera instancia, si el demandado es vencido podrá recurrir de casación en la forma en contra de ella, porque ya preparó la casación reclamando del vicio de incompetencia oportunamente.

2) La sentencia de primera instancia claramente contiene el vicio de falta de ponderación de la prueba, enmarcable en el Nº 4 del art. 170 en relación con el Nº 5 del art. 768. Se apela de esta circunstancia y la sentencia de segunda confirma el fallo de primera. ¿Cabe casación en la forma contra esta sentencia de segunda instancia, que hizo suyo el vicio de falta de ponderación de la prueba, diciendo de falta de ponderación de la prueba rendida? La sentencia de primera instancia es apelable y recurrible de casación en la forma. En este caso no se reclamó del vicio por casación en la forma; en consecuencia no se puede casar en la forma la sentencia de segunda, porque previamente se debió recurrir de casación en la forma de la sentencia de primera. Siempre hay que ver si se puede recurrir de casación en la forma respecto de una sentencia de primera instancia, además de apelar (apelación en subsidio).

Si no se recurre de casación pudiendo hacerse, y la sentencia de segunda puramente confirma la de primera, es inadmisibles la casación en la forma contra aquélla, por falta de preparación. O sea, tratándose de la casación, el propio recurso de casación en la forma es una vía de preparación.

3) El tribunal de primera instancia decretó pura y simplemente "agregúese a los autos" con respecto a un instrumento, sin otorgar citación, pero en su sentencia pondera dicho instrumento, para efectos de la prueba, en contra del recurrente. La sentencia de segunda hace suyo el fallo de primera. El recurso de casación en la forma contra la sentencia de primera instancia, para ser admisible, debió haberse preparado deduciendo reposición con apelación en subsidio contra la resolución que ordenó la agregación a los autos.

Cuando el legislador dice "oportunamente y en todos los grados" se refiere a los recursos en contra de la resolución en que queda de manifiesto o se discutió una infracción. Se ha planteado si cuando se habla en todos los grados es necesario recurrir por la vía del recurso ordinario o por el procedimiento extraordinario, y se ha concluido que basta con agotar los recursos ordinarios, porque grado

jurisdiccional va de la mano con instancia, la que a su vez va unida con el recurso de apelación. O sea, basta con agotar los recursos respectivos hasta la apelación inclusive.

Sin embargo, esta necesidad de preparar el recurso de casación en la forma reclamando oportunamente y en todos los grados, tiene excepciones. O sea, en ciertas condiciones y circunstancias no es necesario formular el reclamo, y aun cuando no se lo formule es posible recurrir de casación en la forma. Estas excepciones son:

1. Art. 769 inc. 2º: cuando la ley no admite recurso alguno contra la resolución en que se haya cometido la falta. Es obvio, porque si la ley no permite forma alguna de reclamo, no puede exigirlo para que se entienda preparada la casación en la forma.

2. Art. 769 inc. 2º: cuando la falta haya tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se trata de casar. Si la falta no es anterior a la sentencia recurrida, sino que se ha cometido precisamente al pronunciarla, es obvio que no se necesita haber reclamado con anterioridad. Es imposible además, porque la falta sólo se produjo en la sentencia misma.

3. Art. 769 inc. 2º: cuando la falta ha llegado a conocimiento de la parte después de pronunciada la sentencia. Es también obvio que el recurrente no pudo reclamar de ella antes. Por ejemplo., en el respectivo procedimiento no se citó a las partes a oír sentencia en forma oportuna, y omitiéndose este trámite esencial se pronunció sentencia. Las partes saben de esto sólo en ese momento. La ley, por tanto, no puede exigir un reclamo oportuno, porque el recurrente sólo tomó conocimiento de él después de dictada la resolución en contra de la cual se recurre.

4. Art. 769 inc. 3º: cuando se recurre contra sentencia de segunda instancia por las causales 4ª, 6ª y 7ª del art. 768. La sentencia de primera instancia contiene ciertos vicios de casación. La regla general es que si no se reclama contra ella por vía de casación en la forma, no se puede reclamar contra la sentencia de segunda instancia que haga suyos los vicios. O sea, como hemos visto, para entender preparada la casación en la forma contra la sentencia de segunda instancia, la regla muy general es haber reclamado de los vicios que contenía la sentencia de primera.

Pero la ley exime de esta necesidad y permite derechamente al recurrente dirigirse de casación en la forma contra la sentencia de segunda instancia invocando tres causales, dada su enorme entidad:

- Ultrapetita (Nº 4), dictarse contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada (Nº 6) o por decisiones contradictorias (Nº 7).
- El vicio de ultrapetita es, en el fondo, una expresión de incompetencia absoluta, porque el juez va más allá de los límites de la contienda.
- El vicio de cosa juzgada ataca el fundamento mismo de la actividad jurisdiccional, en la medida que pretende rever lo ya definitivamente resuelto.
- Y el vicio de decisiones contradictorias es la negación de la actividad jurisdiccional, porque en la medida en que ellas se destruyen recíprocamente equivalen a no decidir.

Por último, digamos que si el vicio es el del N° 1 del art. 768, es decir, incompetencia o integración contraria a la ley, en caso de integración el abogado de la parte debe reclamar antes de la vista de la causa, como lo manda el inc., final del art. 769.

B. Reparación del agravio por una vía menos onerosa.

Contemplada en el inc., penúltimo del art. 768: *"No obstante lo dispuesto en este artículo, el tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma, si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo"*.

Es posible desestimar la casación en la forma si el vicio es reparable por una vía menos onerosa que la anulación del fallo. En la concepción tradicional de la casación en la forma regía el principio del reenvío, consistente en que producida la anulación por esta vía, los autos volvían al tribunal a quo para que dictase un nuevo fallo o reparase el vicio.

Esto causaba una gran dilación procesal, porque anular el fallo era desperdiciar un gran esfuerzo procesal, además del tiempo de los litigantes. Se daba el absurdo de procesos anulados tras 15 años de desarrollo porque la Suprema ordenaba notificar válidamente la demanda. Para evitar estos casos, el legislador permitió la posibilidad de corrección por vía menos onerosa.

Por ejemplo, ante una sentencia de primera instancia que no pondera debidamente la prueba se recurre de casación en la forma y apelación.

La corte desecha la primera porque ella ponderará debidamente la prueba en la sentencia de segunda instancia, corrigiendo por vía de apelación el vicio reclamado.

Otro caso, más de laboratorio porque en la realidad se da pocas veces, por no decir nunca: se dice de casación en la forma y en el fondo contra sentencia de segunda instancia. La Suprema reconoce vicios susceptibles de casación en la forma, pero repara el fallo acogiendo la casación en el fondo, que no importa reenvío porque es la propia corte de casación la que lo falla.

C. Que el vicio no haya influido substancialmente en lo dispositivo del fallo.

Este tercer límite del recurso de casación en la forma aparece en el art. 768 inc., penúltimo.

Significa que no obstante existir este vicio, la decisión de la sentencia recurrida, es ajustada a derecho y que aun sin haberse cometido un vicio, esta decisión no habría variado substancialmente.

Por ejemplo, se acompaña cierto documento emanado de un tercero, pero el tribunal no lo tuvo acompañado con citación. El que presentó el documento reclama de este vicio, con lo que prepara el recurso, y luego reclama de la sentencia. La corte de casación, al conocer la casación en la forma, puede decir que este vicio no tiene influencia substancial porque el documento no agregado con la debida

citación carece del peso probatorio del caso para causar un agravio substancial. O sea, de cualquier modo el fallo habría sido el mismo.

O bien, si la ponderación de la prueba no fue del todo completa, bien podría ser que tampoco influya substancialmente en lo dispositivo del fallo, porque aun exhaustiva y completa la ponderación, la decisión habría sido la misma.

En suma, esta disposición contempla dos cosas: que el vicio no sólo sea reparable por vía de anulación o que no haya influido substancialmente en lo dispositivo del fallo.

D. La falta de decisión del asunto controvertido.

Está contemplado en el Nº 5 del art. 768 en relación con el 170 Nº 6, ambos del CPC, como causal del recurso de casación. De acuerdo con el 170 Nº 6, la decisión del asunto controvertido se refiere a todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el respectivo juicio, salvo las incompatibles con las resueltas.

Si ocurre este vicio, el tribunal que está conociendo de la casación en la forma tiene la alternativa de: 1) casar la sentencia en la forma, y en este caso concreto debe ordenar que se vuelva a conocer del asunto en primera instancia o en la instancia correspondiente por el tribunal no inhabilitado pertinente ó 2) que los autos vuelvan a primera instancia para que el propio juez que dictó el fallo lo complete, o sea, no necesariamente casa la sentencia.

Por ejemplo, al juez de primera instancia se le olvidó fallar una excepción. La corte no necesariamente casa el fallo, sino que ordena que vuelva el expediente a primera instancia, para que el juez se pronuncie sobre la excepción omitida.

Como regla muy general, la corte no puede fallar la excepción o la acción que el juez de primera instancia no falló, porque si lo hiciera estaría fallando no en segunda, sino en única instancia.

Recordemos que el tribunal de segunda instancia, como regla general no puede avocarse a lo ventilado y no fallado en primera, salvo que la falta de decisión sea debida a ser incompatible con el fallo.

Asimismo, sabemos que a título excepcional, en el procedimiento sumario el tribunal de segunda instancia puede fallar en única lo ventilado y no resuelto en primera no por incompatibilidad, sino por simple omisión. O sea, si en un juicio sumario el tribunal de primera instancia no falló una excepción por simple omisión, el de segunda instancia puede derechamente fallar en única la excepción no resuelta.

En suma, el tribunal de casación no necesariamente casa, sino que puede ordenar "devuélvase" y excepcionalmente, tratándose de un juicio sumario, puede completar él mismo el fallo, resolviendo en única instancia (Arts. 768 inc. final y 692 respecto del J Sumario, ambos del CPC)

7.5 Interposición del recurso de casación en la forma.

1. Se interpone ante el tribunal a quo (aquél que dictó la resolución recurrida) para ser resuelta por el tribunal ad quem, que normalmente es el superior jerárquico inmediato. Lo señala, de acuerdo con las normas de competencia, el COT.
2. Lo interpone la parte agraviada, en cuanto a que la resolución recurrida le sea perjudicial y el vicio específico que se invoque le haya producido perjuicio, es decir, signifique un menoscabo real o potencial a la parte que interpone en juicio (art. 771 CPC).

7.6 Plazo y forma de interponerlo (Arts. 770 y 808)

Hay que distinguir según si se interpone contra sentencia de segunda o única instancia o contra sentencia de primera instancia.

Lo curioso es que en general asimilamos la sentencia de primera con la de única instancia, quedando la de segunda en otro plano. En este caso es al revés: se asimila la sentencia de segunda con la de única instancia, según se desprende de los artículos citados.

7.6.1 Contra sentencia de segunda o única instancia Arts. 770 inc 1º y 808.

Según el 770 inc. 1º, el recurso de casación se debe interponer en los 15 días siguientes a la fecha de notificación de la sentencia contra la cual se recurre, sin perjuicio de lo que dice el art. 770 inc. 2º, que se refiere a la sentencia de primera instancia. En consecuencia, el 770 inc. 1º se refiere sólo a la sentencia de segunda y a la de única instancia.

El art. 808 nos dice que si contra una sentencia se deduce también casación en el fondo (se entiende que además de la casación en la forma), ambos recursos deben ser interpuestos conjuntamente y en un mismo escrito y serán vistos y fallados en una misma oportunidad. En tal evento, el recurso de casación en el fondo se entiende lógicamente subsidiario del de casación en la forma, porque el primero de ellos parte del supuesto de la validez formal del fallo, al que se ataca por nulidad substancial.

El escrito será: en lo principal deduce recurso de casación en la forma, en el primer otrosí deduce recurso de casación en el fondo.

Obviamente, si se acoge la casación en la forma se tiene por no interpuesta la casación en el fondo.

7.6.2 Contra sentencia de primera instancia.

El art. 770 inc 2º dispone que en tal caso, la casación en la forma se interpone en el plazo para deducir recurso de apelación y conjuntamente con éste, si también se quiere deducir recurso de alzada.

En consecuencia, no hay un solo plazo para deducir casación en la forma contra sentencia de primera instancia porque dependerá si es sentencia definitiva o interlocutoria.

Si es posible casar en la forma una **sentencia interlocutoria**, es decir, cuando pone término al juicio o hace imposible su continuación, o si excepcionalmente se vio en segunda instancia sin previa vista de la causa, etc., el plazo es de cinco días conjuntamente con la apelación si se quiere deducir ésta.

Si se quiere casar una sentencia definitiva de primera instancia el plazo es de 10 días, y debe deducirse conjuntamente con el recurso de apelación, si se quiere intentar ésta.

En ambos casos, la apelación se entiende interpuesta como subsidiaria de la casación en la forma, porque aquélla parte del supuesto de una sentencia válida, en tanto ésta afirma la nulidad de la respectiva sentencia. O sea, en materia de casación en la forma, el inc. 2º del art. 770 se remite al recurso de apelación, y como éste tiene un plazo variable de interposición, según la naturaleza de la resolución apelada, se entiende que el plazo de la casación es variable.

Es necesario destacar que este plazo no se aumenta de acuerdo con la tabla de emplazamiento, porque se presenta ante el tribunal a quo. Parece obvio, pero la legislación anterior sí daba el aumento según la distancia entre el tribunal a quo y el ad quem.

Como ya se ha dicho, la casación en la forma se interpone ante el tribunal a quo, y en este recurso se deben plantear las peticiones concretas relacionadas con la casación. Estas peticiones son: que se tenga por interpuesto el recurso; que se lo conceda para ante el tribunal ad quem a fin de que éste haga lugar al recurso, anule el fallo y devuelva los autos al tribunal que dictó la resolución para que el juez no inhabilitado que corresponda proceda como sea el caso.

7.7 Consecuencias del fallo de casación.

Éste puede acoger o desechar el recurso de casación.

Si lo desecha, pura y simplemente dirá esto, y declarará explícita o implícitamente que la resolución recurrida es válida.

Pero si lo acoge, pueden pasar tres cosas:

1) que tratándose de ciertas causales, el propio tribunal de casación dicte sentencia de reemplazo, salvando en ella los vicios por los cuales fue acogido el recurso. Veremos que es una situación teóricamente excepcional pero se ha convertido en la práctica en la regla general.

2) que el tribunal de casación, acogiendo la casación en la forma, anule el fallo y ordene que vuelva al nivel del tribunal a quo para que el juez no inhabilitado que corresponda dicte nuevo fallo. Esta institución se conoce como reenvío.

3) que el tribunal de casación acoja el recurso, anule la sentencia recurrida y ordene que vuelvan los autos a una situación anterior al vicio por el cual se acogió el recurso. Es decir, no tan sólo se anula la

sentencia recurrida, sino además las actuaciones anteriores, si el vicio que se invoca es anterior a la sentencia.

Por ejemplo, el vicio es la falta de citación para una diligencia de prueba, que es trámite esencial. No sólo se anula la sentencia recurrida, sino además todo lo obrado y se retrotrae la causa a que válidamente se cite a la parte correspondiente para la práctica de la diligencia en cuestión.

La importancia de estas tres conductas posibles del tribunal al acoger el recurso de casación es que determinan cómo se lo debe plantear. Es decir, al plantearlo, las peticiones concretas sometidas a decisión del tribunal de casación se relacionan a lo que se pide en él y en función con la causal invocada. Así, se puede pedir que se acoja el recurso y se dicte sentencia de reemplazo, o se lo acoja y se vuelva al tribunal a quo para que se dicte nueva sentencia por el tribunal no inhabilitado que corresponda. O bien, que se acoja el recurso, se anule la sentencia y la causa se retrotraiga al estado que signifique subsanar el vicio que fundamentó el recurso.

En suma, las peticiones concretas contenidas en el recurso de casación en la forma dicen relación con la causal invocada y lo que se pretende a través de la anulación. Porque no todas las casaciones tienen el mismo desenlace, como acabamos de ver.

7.8 Requisitos formales del escrito de casación en la forma.

Es formal y solemne. Sus menciones son las siguientes:

1. Expresamente el vicio o defecto que se invoca.
2. La ley que concede el recurso por el vicio invocado.
3. Designar abogado patrocinante del recurso, que debe ser un abogado habilitado que no sea procurador del número.

Así aparece en el Nº 2, incs. 2º y 3º, del art. 772 del CPC, cuya primera parte alude a los requisitos de la casación en el fondo.

Ejemplo: Si la causal que se invoca es ultrapetita, se plantea así: vengo a recurrir de casación en la forma invocando el vicio de ultrapetita que consistió en (se relata). Luego se dice que la ley que concede el recurso por el vicio que se invoca es, en este caso, el Nº 4 del art. 768 del CPC. Y al final, en un otrosí, "Sírvasse Us., tener presente que patrocina el presente recurso de casación en la forma el abogado habilitado don xxx, domiciliado en tal parte, quien firma en señal de aceptación".

Si el vicio que se pretende cometido en la sentencia recurrida es la falta de regulación de la prueba, se invoca como vicio de casación en la forma no contener las consideraciones necesarias en cuanto a los hechos de la causa (se explica por qué se afirma esto). La ley que concede el recurso por el vicio que se invoca es, en este caso, el Nº 5 del art. 768 (requisitos de la sentencia) en relación con el Nº 4 del art. 170, ambos del CPC, que indica que la sentencia definitiva debe contener las consideraciones de hecho y de derecho. O sea, al invocar esta causal -- el Nº 5 del art. 768 -- hay además una remisión al art. 170.

Hay que ser cuidadoso al interponer el recurso de casación tiene una importante sanción legal, en el inciso primero del art. 774: "Interpuesto el recurso (de casación), no puede hacerse en él variación de ningún género". O sea, el error queda definitivamente asentado, y no se acepta variación de ningún género. La norma agrega que aun si en el progreso del recurso se descubre alguna nueva causa en que este recurso haya podido fundarse, la sentencia recaerá únicamente en las alegadas en tiempo y forma.

Interpuesta la casación en la forma, hay dos tramitaciones sucesivas: ante el tribunal a quo (ante el que se interpuso el recurso) y ante el tribunal ad quem, es decir, el que debe conocerlo.

En ambos momentos se examina la admisibilidad del recurso, pero este examen de admisibilidad es menos exhaustivo ante el tribunal a quo y más exhaustivo ante el ad quem. En otras palabras, el tribunal a quo mira sólo algunos aspectos relacionados con la admisibilidad; el ad quem mira todos los aspectos relacionados con ella.

7.9 Tramitación ante el tribunal a quo (arts. 776 a 778)

El tribunal a quo examina la admisibilidad sólo en dos aspectos:

1) si el recurso fue presentado en tiempo y

2) si tiene designado abogado patrocinante.

Por lo tanto, no observa si la resolución es o no recurrible ni si se cumplieron los requisitos formales. La admisibilidad ante el tribunal a quo se resuelve en cuenta.

Si el tribunal a quo estima admisible la casación en la forma, lo declara expresamente y ordena la confección de fotocopias o compulsas según sea el caso, conservándolas en su poder para cumplir el fallo recurrido en su caso, y elevando los autos originales.

Por eso la remisión del inc. 2º del art. 776 al art. 197 del CPC, que se refiere a las fotocopias o compulsas respecto de la apelación.

O sea, el tribunal a quo procede igual que el de apelación: concede el recurso e indica las piezas que deben ser fotocopias o compulsadas, para conservarlas, y ordena elevar los autos originales. También en este caso rige el inc. 2º del art. 197, en cuanto a que el recurrente debe depositar el dinero suficiente para confeccionar las fotocopias o compulsas. Jurisprudencia reiterada ha declarado que si no se hace el depósito correspondiente, se entiende desierto el recurso de casación en la forma, es decir, se aplica íntegramente el art. 197.

Esto, pese a una duda interpretativa derivada de la remisión del art. 776 al inc. 2º del art. 197, y la sanción está en el inc. 3º de éste. Para algunos autores al no haber remisión al inc. 3º, esta sanción no se

aplicaba. Pero la Corte Suprema resolvió que si hay incumplimiento de la carga procesal, se sanciona según el inc. 3º del art. 197.

Sin embargo, si la casación en la forma se interpone conjuntamente con la apelación, y ésta debe ser concedida en ambos efectos, no se ordena la confección de fotocopias, ni hay tampoco obligación de depósito (art. 776 inc. final).

Tratándose de casación en la forma es también carga procesal del requirente franquear la remisión del expediente, es decir, pagar los costos del correo. En suma, entregar al secretario del tribunal las estampillas necesarias para enviar el expediente. Y si no se entrega el franqueo, a petición de parte se le puede requerir para que lo haga, bajo apercibimiento de tenerse por no interpuesto el recurso.

Esta carga procesal no existe respecto de la apelación, pero sí, curiosamente, respecto de la casación en la forma. La razón es que nuestro sistema judicial acepta como principio general la doble instancia, la facilita, y la llave de ésta, como ya se ha insistido, es la apelación. La casación, en cambio, es un recurso excepcional y de derecho estricto.

Ahora, si el tribunal a quo declara inadmisibile el recurso de casación en la forma por una o dos de las causales ya indicadas, lo hace sin más trámite. Contra el fallo del tribunal a quo en este sentido, sólo cabe recurso de reposición que debe fundarse en error de hecho y deducirse dentro de tercero día. La resolución que resuelve la reposición es, a su vez, inapelable (art. 778).

7.10 Tramitación ante el tribunal ad quem (arts. 779 y 781)

El art. 779 se remite, a su vez, a otras normas de la apelación.

En primer lugar, elevados los autos al tribunal ad quem, el recurrente tiene un plazo de cinco días para comparecer ante él, aumentables en tres días si el tribunal a quo está fuera de la comuna de asiento y además de acuerdo a la tabla de emplazamiento si está fuera del territorio jurisdiccional del tribunal ad quem.

Este plazo es fatal, de modo que si no comparece en él, se entiende desierto el recurso de casación en la forma. Así debe entenderse la remisión al art. 200 del CPC.

El recurrido se refiere la remisión al art. 202 del CPC. Es decir, no tiene un plazo fatal para comparecer, pero si no lo hace se le entiende rebelde por el solo ministerio de la ley, le afectan las resoluciones por el solo hecho de dictarse y si quiere comparecer, deberá hacerlo por abogado habilitado o procurador del número.

Ingresados los autos al tribunal ad quem, éste examina la admisibilidad en cuenta, pero en toda su extensión. Es decir, además de los extremos que analiza el tribunal a quo, el ad quem revisa si se cumplen los requisitos formales de la casación en la forma.

Si estima admisible este recurso, dicta autos en relación.

Si por el contrario lo estima inadmisibile, así lo declara. Contra esta resolución cabe reposición dentro de tercero día (incs 1º, 2º y 4º del art. 781).

La declaración de admisibilidad, en consecuencia autos en relación, tiene una pequeña salvedad en el inc. 3º del art. 781: si el tribunal ad quem estima inadmisibile el recurso, puede sin embargo ordenar traer los autos en relación si advierte que hay un posible vicio de casación en la forma que pueda declarar de oficio.

Es importante precisar que la declaración de admisibilidad que realiza el tribunal ad quem no produce cosa juzgada ni es necesariamente vinculante. Así, al fallar el recurso mismo, la corte puede declararlo inadmisibile en todo o en parte.

Ordenados que sean los autos en relación se procede de acuerdo a las reglas generales de la apelación: rol general de causas en estado de tabla, tablas, sorteo de estas, fijación de día para la vista de la causa.

7.11 Reglas especiales de la vista de la causa (art. 783)

En primer lugar, se remite a las reglas generales de la apelación, pero señala que en el recurso de casación en la forma, sin embargo los alegatos de cada abogado podrán durar hasta una hora, prorrogable por otro tanto. Además faculta a las partes para, hasta antes de verse el recurso, consignar por escrito y con la firma de un abogado no procurador del número, las observaciones que estimen convenientes.

Este artículo contiene además una regla que se aplica en general a las vistas ante la Suprema: sin perjuicio de las reglas particulares de la casación, los alegatos ante la Suprema que no tengan fijada una duración especial, sólo podrán extenderse por media hora.

7.11.1 Plazo para fallar.

El art. 806 señala el plazo del tribunal ad quem para fallar el recurso: veinte días desde el término de la vista.

7.11.2 Posible prueba en el recurso de casación en la forma.

No se trata de prueba del conflicto mismo, sino de la prueba respecto de la causal. Es decir, el legislador imaginó que era posible que de acuerdo con la naturaleza de la causal, fuese efectivamente necesario rendir prueba.

Es una situación muy especial, porque lo normal es que los hechos de la causal consten del proceso. Pero por excepción podría ser que estos hechos no aparezcan en él. Por ejemplo., una causal de impugnancia puede no constar en el proceso.

Consciente de esta situación excepcional, hay dos disposiciones referidas a la posible prueba en la casación en la forma: los Arts. 807 inc. final y 799.

El inc. final del art. 807 se remite al 799, por lo que basta analizar este último: cuando la causa alegada necesite de prueba, el tribunal abrirá para rendirla un término prudencial que no exceda de 30 días.

Para rendir prueba testimonial, por ejemplo, se aplican las reglas de incidentes: lista de testigos en primeros dos días de un término probatorio de ocho ampliable hasta un máximo de 30. Es decir, este plazo es asimilable al de incidentes.

Y, más importante, la casación no es la cuestión principal, sino técnicamente hablando una cuestión accesoria, por lo que se le aplican las reglas de los incidentes.

7.12 Sentencia o resolución que falla el recurso de casación en la forma.

Puede tener distintas características.

1. Si desecha el recurso: pura y simplemente así lo declara después de los correspondientes raciocinios y explícita o implícitamente declara que la resolución recurrida es válida.

2. Si acoge el recurso: la regla general teórica es aplicar el principio del reenvío. O sea, vuelve a nivel de tribunal a quo, sea para que éste dicte un nuevo fallo por juez no inhabilitado que corresponda, o realice las diligencias necesarias a partir de la actuación que se estimó viciosa.

Esta materia está regulada en el art. 786, el que razona respecto de la sentencia que acoge el recurso, y señala como regla general teórica que se anula la sentencia y se devuelven los autos al tribunal a quo, sea para que a nivel de éste, el juez no inhabilitado que corresponda dicte nueva sentencia o se hagan los trámites necesarios para subsanar el vicio, si se ordenó retrotraer la causa a un estado anterior (reenvío).

Pero esta regla general teórica tiene varias calificadas excepciones, en virtud de las cuales el tribunal que casa en la forma no reenvía, sino que casa la sentencia y él mismo dicta sentencia de reemplazo subsanando los vicios de que adolecía la sentencia casada. Esta nueva sentencia, como es obvio, ocupa el lugar de la sentencia que se anuló.

7.13 Sentencia de reemplazo.

El tribunal dicta sentencia de reemplazo en las siguientes causales del art. 768 N°s

- 4: ultrapetita;
- 5: requisitos de la sentencia;
- 6: cosa juzgada y
- 7: decisiones contradictorias.

Cuando casa y dicta sentencia de reemplazo, el tribunal de casación efectúa en un solo momento dos actos procesales distintos: 1) dicta la sentencia de casación, acogiendo el recurso y 2) dicta la sentencia de reemplazo. Por costumbre ambas sentencias tienen cuerpo propio: ambas tendrán fecha, consideraciones y juego completo de firmas.

Técnicamente hablando, la sentencia de reemplazo tiene las mismas características de la sentencia casada. Es decir, será interlocutoria si la sentencia casada lo era o definitiva si la sentencia casada lo era.

Un error sistemático cometido por el legislador en esta norma es que la sentencia de reemplazo se pronuncia sobre el fondo de la cuestión debatida, pero la vista de la causa se refiere sólo a los recursos de casación. Imaginemos que se trate de una sentencia definitiva de segunda instancia. Es casada y la Corte Suprema dicta sentencia de reemplazo, que resuelve el asunto controvertido.

Pero cuando se alega ante la Suprema esta casación en la forma, el alegato sólo versa sobre la casación, no sobre el fondo del asunto. Y resulta entonces el absurdo de que el tribunal que dicta la sentencia de reemplazo no ha oído alegaciones sobre el fondo del asunto.

Hay claramente una falta de sistema, porque el CPC debió haber dicho que cuando la vista de la causa se refiere a un recurso de casación que, de prosperar permitiría sentencia de reemplazo, los alegatos puedan también extenderse al fondo del asunto.

Esta regla, de la posibilidad de sentencia de reemplazo en virtud de las causales ya anotadas es también aplicable a la casación de oficio (art. 776). O sea, cuando se casa de oficio por cualquiera de estas causales, se aplica también el criterio de la sentencia de reemplazo, no del reenvío.

En cuanto a la estructura de la resolución que resuelve la casación es la de una sentencia definitiva, aun cuando técnicamente no lo es porque ni pone término a la instancia ni resuelve el asunto controvertido. Tiene, en consecuencia, una parte expositiva, una considerativa y una resolutive, que declara si la acoge o desecha.

Asimismo, dijimos que la sentencia de reemplazo tiene la misma forma de la sentencia reemplazada. O sea, si la sentencia reemplazada es una sentencia definitiva, la de reemplazo lo será también. Si la sentencia reemplazada es una interlocutoria -- en los casos en que procede la casación en la forma en contra de ella -- tendrá la forma de tal.

Es también frecuente que la sentencia de reemplazo se remita o tenga por reproducidas ciertas consideraciones del fallo de casación, porque es posible que la sentencia de reemplazo tenga en vista las mismas razones que tuvo la corte para casar la respectiva resolución.

El fallo de reemplazo se dicta en el mismo acto, pero separadamente. Cada una tiene su propia estructura y termina con la firma de los jueces que concurrieron a su dictación, además de la autorización del respectivo secretario.

7.14 Casación en la forma y cumplimiento de la resolución recurrida (art. 773)

Cuando se deduce este recurso, la regla general es que se ordena sacar fotocopias o compulsas, que quedan en el tribunal a quo, o al que conoció del asunto en primera o en única instancia, para efectos de su cumplimiento. Esta regla sólo tiene una calificada excepción cuando se deducen conjuntamente casación en la forma y apelación y este último deba ser concedido en ambos efectos. En tal evento, no tiene razón de ser el ordenar compulsas. Se ordena elevar los autos originales y queda en suspenso el cumplimiento del fallo, no a consecuencia de la casación en la forma, sino del recurso de apelación concedido en ambos efectos.

La regla general es que la interposición de la casación en la forma no suspende el cumplimiento de la resolución recurrida. Es decir, esta resolución puede ser claramente cumplida no obstante haberse interpuesto casación en la forma en contra suya.

El legislador mira con cierta desconfianza al recurrente de casación en la forma, pues muchas veces ve en este recurso extraordinario un ánimo fundamentalmente dilatorio. Por esta razón ordena no suspender el cumplimiento de la sentencia atacada con este recurso (regla general).

a) Excepción genérica en el art. 773: debe suspenderse el cumplimiento de la ejecución de la sentencia cuando haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. O sea, no cabe cumplir la sentencia impugnada si de cumplirse se haría imposible, a su vez, cumplir con lo que se resuelva al fallar la casación.

En esta materia el legislador dio dos ejemplos no apropiados de sentencias que no se deben cumplir estando pendiente la resolución de la casación: la sentencia que declara la nulidad del matrimonio y la sentencia que permite el matrimonio de un menor de edad.

La sentencia que declara la nulidad del matrimonio es declarativa y se cumple por la simple inscripción en el Registro Civil, de modo que es posible que si prospera la casación y se anula el fallo, se pueda cancelar la inscripción que se practicó en virtud de la sentencia. El caso del matrimonio del menor es también una sentencia declarativa en que se deja testimonio de la autorización en el acta respectiva. Lo que resulta irreversible es el acto posterior: el nuevo matrimonio de quien se vio favorecido por la sentencia que acogió la nulidad del anterior, o el matrimonio del menor. Pero no es el cumplimiento del fallo, sino un acto jurídico distinto, separado.

b) Excepción específica. Consiste en que la parte vencida, es decir, el recurrente, puede pedir que no se cumpla la resolución recurrida en tanto la parte vencedora no rinda fianza suficiente. Y esta fianza tiene por objeto asegurar que el cumplimiento que se efectúe de la resolución recurrida podrá ser retrotraído en caso que ella sea anulada.

Por ejemplo: la sentencia ordena el pago de una determinada cantidad de dinero. Se recurre contra ella de casación en la forma. Hay dineros retenidos. El recurrente puede pedir que no se entregue el dinero retenido, es decir, que no se cumpla la sentencia recurrida, en tanto el ganancioso no rinda fianza de restituir el dinero que se va a girar en su beneficio.

El art. 772 exige, al efecto, que se rinda fianza de resultas. Significa que de prosperar el recurso y anularse la sentencia, la situación se podrá retrotraer a la situación inmediatamente anterior al cumplimiento.

Pero se requiere fianza de resultas. Es decir, la ley está exigiendo que un tercero ajeno al juicio, caucione con su patrimonio esta eventual restitución. Esta fianza debe entenderse en relación con las normas pertinentes del CCv, de manera que el fiador debe acreditar, tal como lo indica la ley civil, su correspondiente solvencia para asegurar esta retracción a la situación anterior al cumplimiento del fallo. El tribunal fija el monto de su constitución, y la fianza se constituye ante el tribunal a quo, el que otorga la correspondiente acta de fianza en el libro especial que se lleva en su secretaría.

Constituida la fianza a satisfacción del tribunal a quo, es posible cumplir la resolución impugnada. Sin embargo, este derecho del recurrente pericioso de exigir fianza de resultas, no le asiste cuando la sentencia impugnada ha sido pronunciada en juicio ejecutivo, en interdicto posesorio, en juicio de desahucio o de alimentos, y siempre que el recurrente sea la parte demandada en los respectivos juicios. O sea, en esta clase de juicios el demandante sí puede pedir que no se cumpla la sentencia en tanto no se rinda fianza de resultas, pero el demandado no tiene este derecho.

En los juicios ejecutivos es una expresión más de la desconfianza del legislador hacia el ejecutado. La naturaleza de este juicio, el título, ponen al demandado en situación de sospecha.

En los juicios posesorios es importante la rapidez en la tramitación, de modo que la eventual suspensión en el cumplimiento de la sentencia es contraria a este principio de urgencia y rapidez.

En los juicios de alimentos, porque las pensiones deben ser pagadas oportunamente, ya que miran a la subsistencia del beneficiario.

En cuanto a los juicios de desahucio, digamos que parece curioso que la ley hable de estos y no del género "juicios especiales del contrato de arrendamiento", al cual ellos pertenecen. Estas normas además tienen hoy poca aplicación, porque hay un procedimiento global para los juicios de arrendamiento de inmuebles.

La razón es que esta norma está copiada de la ley española de enjuiciamiento civil, la cual da el nombre genérico de "juicios de desahucio" a todos los juicios especiales del contrato de arrendamiento. En virtud de este origen, nuestros tribunales entienden que cuando el legislador se refiere a los juicios de desahucio alude en general a todos los juicios especiales del contrato de arrendamiento.

En cuanto al momento y forma de ejercitar este derecho es al deducir su recurso, ni antes ni después. Curiosamente, no lo hace en el mismo escrito en que deduce el recurso, sino en uno separado, el que se cose o agrega al cuaderno de copias o compulsas y el tribunal a quo resuelve el monto de la fianza que fija y ordena su debida constitución. Es el tribunal a quo el que debe resolver todos los puntos que se puedan suscitar en torno a esta cuestión (vg, aumento, disminución, subsistencia), lo que hace de plano, es decir, en única instancia y sin posibilidad de apelación. O sea, no da tramitación incidental.

7.15 Extinción del recurso de casación en la forma.

Forma normal: obviamente es la sentencia que falla este recurso, sea acogiéndolo o denegándolo. Contra esta sentencia no cabe recurso alguno: se dicta de una vez y para siempre, pero sin perjuicio de poder recurrir, eventualmente, en contra de la sentencia que dicte el propio tribunal ad quem. Por ejemplo, si se recurre de casación en la forma y de apelación en contra de una sentencia de primera instancia, la sentencia de casación que dicta la corte de apelaciones no es a su vez recurrible. Pero la sentencia que pronuncia la corte en la apelación sí es recurrible, y atacándola se pueden renovar los argumentos que se hicieron valer respecto de la casación. Porque el haber recurrido de casación contra la sentencia de primera instancia es forma necesaria de preparar el recurso, lo que abre la posibilidad de recurrir de casación en la forma en contra de la sentencia de que se dicte, conociendo de la apelación. Hasta antes de una reforma, desechado el recurso de casación en la forma necesariamente se condenaba en costas al recurrente. Así lo señalaba el derogado art. 787. Ahora se aplican las reglas generales, es decir, el tribunal podrá o no condenar en costas según estime si el vencido tuvo o no fundamento plausible para litigar.

Formas anómalas: son muy similares a las de la apelación.

1. En primer lugar el **desistimiento**: al igual que en la apelación, no requiere poder especial (la renuncia sí requiere este poder).

2. La **deserción** procede por:

a) falta de depósito para la confección de las copias respectivas, lo mismo que respecto de la apelación (art. 776). Se entiende que no entregar los dineros respectivos para este propósito, conlleva la sanción de deserción. El plazo es de quinto día y se aplica por la específica remisión al art. 197. Hubo una pequeña duda interpretativa porque es el inc final del art. 197 el que contempla la sanción de deserción por no entrega del depósito, pero el art. 776 se remite al inc. 2º del 197. Algunos tribunales vacilaron en aplicar este apercibimiento, dada la remisión mal hecha, pero se ha entendido que si existe un plazo y es fatal por la remisión al 197, debe conllevar la misma sanción de éste, pese a la deficiente remisión.

b) El no franquear la remisión de los autos (art. 777): es una causal propia de deserción de la casación en la forma, no respecto de la apelación, ya que en ésta no existe la carga de franquear la remisión, a diferencia de la casación. Esto, porque la regla general en nuestra legislación es la doble instancia; o sea, se facilita la posibilidad de la apelación. Pero tratándose de un recurso de casación, que es excepcional, no tiene por qué establecerse el mismo principio. Por ello, el no franqueo, es decir, cuando se apercibe al recurrente para que haga frente a los desembolsos correspondientes y no lo hace en el plazo que fija el tribunal a quo, la consecuencia es la posible deserción del recurso. O sea, si el recurrente no franquea la remisión del proceso, puede pedirse al tribunal que se le requiera para ello, bajo apercibimiento de declararse no interpuesto el recurso.

c) De acuerdo al art. 779, hay también deserción de este recurso cuando el recurrente no se hace parte ante el tribunal ad quem. (Art. 779 remitido a los Arts. 200, 201, 202 y 211).

Pero la causal de deserción del recurso de apelación de no contener peticiones concretas, por expresa disposición del inc. 2º del art. 779 no es causal de deserción del recurso de casación. Esto nació de una reforma, pero no tiene explicación. Eso sí, es obvio que es parte fundamental del escrito contener las peticiones concretas en función de la causal que se invoca.

3. **La prescripción**: respecto de la casación en la forma rigen los mismos principios de la prescripción de la apelación, como forma anómala de extinción de este recurso. Se hace la misma distinción del art. 211 en cuanto al plazo de esta prescripción: si la casación en la forma se interpone en contra de sentencia definitiva es de tres meses y si se interpone en contra de sentencia interlocutoria es de un mes.

Tema 8: La Casación en la Forma de Oficio.

Se encuentra regulada en el art. 775 y significa que el tribunal que sería el llamado a conocer del recurso de casación en la forma contra una sentencia, no obstante no haberse recurrido de casación, o haberse recurrido en virtud de un recurso inadmisibile, o conociendo de la cuestión por la vía de otro recurso, o incluso por vía de consulta, pueda casar de oficio.

En este caso, el tribunal actúa como si realmente se hubiere deducido casación en la forma. Y dependiendo de la causal por la cual casa de oficio, o dicta sentencia de reemplazo el mismo, o aplica el mecanismo del reenvío y en tal evento, podrá también señalar a qué estado vuelve la causa después de haber casado de oficio.

Respecto de la facultad de casar de oficio, no rigen las limitaciones estudiadas a propósito del recurso de casación. Es decir, cuando el tribunal casa de oficio, no es necesario que haya mediado preparación; es más, puede no haber preparación alguna y el tribunal hace uso de la facultad de casar de oficio.

Más aun, no se requiere agravio, ni genérico ni específico, como se exige para el recurso. Basta que el tribunal estime que concurre una determinada causal para que de oficio pueda anular el fallo o incluso otras actuaciones anteriores a él.



Sin embargo, el tribunal también puede, cuando el vicio es la falta de decisión del asunto controvertido, ordenar que vuelva al tribunal a quo para que complete.

Pero el legislador señala una exigencia: cuando el tribunal que va a casar de oficio piensa ejercitar esta facultad y la causa se está viendo previa vista, llama a los abogados que han asistido a ésta a alegar sobre el posible vicio de casación que ella advierte, el cual les indica precisamente.

8.1 Dudas doctrinarias sobre la casación en la forma de oficio.

1. ¿Es casable en la forma de oficio una sentencia no recurrible de casación en la forma?

La cuestión se plantea fundamentalmente respecto de sentencias que se dictan en ciertos procedimientos fijados en leyes especiales, que dicen que las resoluciones no son susceptibles de recurso de casación.

¿Significa esto que también queda vedada a su respecto la casación en la forma de oficio?

El criterio reiterado de nuestra jurisprudencia es que el hecho de vedarse o limitarse el recurso de casación no significa que se limita o veda la facultad de proceder de oficio. O sea, aun cuando la ley no franquea el recurso de casación en la forma contra determinadas resoluciones, el tribunal siempre puede casar en la forma de oficio.

2. En virtud de normas legales especiales, ciertas causales de casación en la forma no se pueden invocar respecto de determinadas resoluciones.

Por ejemplo, cuando se trata de sentencias dictadas en juicios regidos por leyes especiales, las causales de casación en la forma están muy restringidas. Esta restricción para efectos del recurso, ¿es también aplicable a la casación de oficio?

Por ejemplo, respecto de sentencias dictadas en juicios regidos por leyes especiales no se puede recurrir de casación en la forma por no haberse agregado los documentos con citación.

Nuevamente la jurisprudencia, dando una interpretación extensiva, admite que la corte case de oficio por una causal que si fuese de recurso, no sería admisible.

Además hay reglas especiales para la casación en la forma en los juicios de mínima cuantía (Arts. 788 a 794).

Tema 9: El Recurso de Casación en el Fondo.

9.1 Concepto.



"Es un recurso extraordinario que se concede a la parte agraviada, en contra de determinadas resoluciones judiciales, para obtener su anulación cuando han sido dictadas con infracción de ley, siempre que dicha infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo del fallo".

Previo al análisis de este concepto, digamos que la reforma de 1995 que modificó todo el párrafo de la casación en el CPC, hace necesario concordar los Arts. 772 y 767 parte final. Esta última habla expresamente de la infracción de ley, mientras que el 772 se refiere a errores de derecho en que se haya incurrido en la dictación del fallo, como causal de este recurso.

Si bien es cierto que la expresión "errores de derecho" es más amplia que "infracción de ley", porque sabemos que el derecho va más allá que la ley, nuestra jurisprudencia ha estimado que el error de derecho que se invoca como legitimante en un recurso de casación en el fondo, siempre y necesariamente debe traducirse en infracción de ley.

O sea, para los efectos de la casación en el fondo ha establecido una relación de sinonimia entre "error de derecho" e "infracción de ley", pese a que, como decimos, la primera de las expresiones tiene jurídicamente un sentido más amplio.

9.2 Elementos característicos del concepto.

1. La casación en el fondo es un recurso procesal. Pero en virtud del art. 785 inc. final es también permitida la casación en el fondo de oficio.

2. Es un recurso extraordinario, lo que se desprende de dos circunstancias: 1) sólo cabe respecto de ciertas resoluciones judiciales taxativamente enumeradas y 2) no cabe frente a un posible agravio genérico, sino que específicamente éste debe encuadrarse dentro de la única causal que acepta o legitima la casación en el fondo, es decir, infracción de ley con influencia substancial en lo dispositivo del fallo.

3. Debe ser interpuesto por parte agraviada. Lo mismo que en la casación en la forma, el término "parte agraviada" tiene dos sentidos: 1) que la resolución recurrida sea precisamente perjudicial, o contraria a los derechos del recurrente y 2) que la infracción de ley que se invoca con influencia substancial sea ella misma agravante o perjudicial al recurrente y sólo a él, no a la contraparte.

4. Persigue que se anule la resolución recurrida. Vimos que hay recursos que buscan que la resolución se modifique (apelación, v.g.) y otros que pretenden que se la anule (casaciones).

Si prospera la casación en el fondo, la sentencia recurrida desaparece del mundo del derecho y es reemplazada por la que dicta en el mismo acto el tribunal de casación. O sea, acogido que sea el recurso, el tribunal de casación necesariamente dicta la sentencia de reemplazo, a reglón seguido pero separadamente y con un nuevo juego de firmas. Ésta pasa a ocupar jurídicamente el lugar de la anulada.

9.3 Casación en el fondo y nulidad.

La nulidad que se persigue obtener con la casación en el fondo es substancial, en tanto que con la casación en la forma se busca una nulidad formal. En síntesis, esto significa que la infracción que legitima la casación en la forma es una infracción de leyes ordenatorio litis, es decir, leyes que regulan el procedimiento, ya sea en cuanto al procedimiento mismo, ya en lo referente a los requisitos de la sentencia; en tanto que las leyes cuya infracción determina el recurso de casación en el fondo son las llamadas decisorio litis, es decir, las leyes aplicables precisamente al conflicto, y que conforme a su recta aplicación debieron servir para solucionarlo.

Sin embargo, esta es una diferencia sólo general, un criterio orientador pero no absoluto, porque a título excepcional, cuando se trata de ciertas resoluciones judiciales se puede también recurrir de casación en el fondo por leyes ordenatorio litis, como ocurre, vg, si se recurre de casación en el fondo contra la interlocutoria que declara abandonado el procedimiento.

Las normas que, en definitiva, dictan los parámetros sobre el abandono del procedimiento, son de carácter procesal y en consecuencia, intrínsecamente son normas ordenatorio litis. Sin embargo, a título excepcional en el ejemplo propuesto pueden servir de base a una casación en el fondo.

Lo que sí es cierto, y se analizará en detalle al tratar los límites de la casación en el fondo, es que ésta no puede fundamentarse en infracciones legales que pudiesen ser constitutivas de casación en la forma.

Dicho en otros términos, lo que es constitutivo de posible vicio de casación en la forma, no es invocable por vía de casación en el fondo.

9.4 Causal genérica de la casación en el fondo civil.

Infracción de ley con influencia en lo sustancial del fallo.

1. Es la infracción de ley -- hoy entiéndase también error de derecho, como ya se explicó -- con influencia substancial en lo dispositivo del fallo. Dejemos pendiente por ahora la explicación del término "infracción de ley", que será analizado en particular. Digamos por ahora que deben examinarse dos grandes temas: qué es ley para efectos del recurso de casación en el fondo y cómo se la puede infringir a este respecto.

2. El segundo elemento, es decir, "influencia substancial en lo dispositivo del fallo": significa que el legislador exige que la infracción de ley denunciada sea efectivamente substancial en lo dispositivo del fallo. O sea, si no se hubiese infringido la ley en la manera como se plantea, la decisión del asunto habría sido distinta.

Dicho en otras palabras, aunque la ley se infrinja de manera violenta y flagrante, no da pie a un recurso de casación en el fondo si dicha transgresión no trae necesariamente aparejada una decisión que habría sido distinta sin esa infracción. Es decir, debe haber una relación indisoluble, de causa-efecto entre la infracción que se denuncia y la parte decisoria del respectivo fallo.

3. Este recurso debe interponerse, lo mismo que el de casación en la forma, ante el tribunal que dicta la resolución contra la cual se recurre, y para ser conocido precisa y necesariamente por la Corte Suprema.

El tribunal a quo en la casación en el fondo es una corte de apelaciones o un tribunal arbitral de derecho de segunda instancia conociendo materias propias de una corte de apelaciones.

El tribunal ad quem es, necesariamente, la Corte Suprema, único tribunal competente para conocer de este recurso, quien conoce en sala.

4. Además la casación en el fondo es un recurso de derecho estricto, y así, es formal y solemne en cuanto a que debe interponerse de determinada manera. Una vez interpuesto no admite modificaciones de ninguna especie y debe encuadrarse específicamente en la causal genérica de infracción de ley o error de derecho con influencia substancial en lo dispositivo del fallo.

5. El recurso de casación en el fondo no constituye instancia. Así lo ha dicho hasta la saciedad la Corte Suprema, desde la instauración de este recurso. Y no la constituye porque se limita a examinar, frente a hechos establecidos por los jueces de las instancias, si en relación con estos hechos se ha aplicado correctamente el derecho o no.

Algunos tratadistas haciendo gala de elegancia verbal han dicho que se trata de "un diálogo entre la sentencia de los jueces de la instancia y la ley". Pero la verdad es que una de las fundamentales

limitaciones del recurso de casación en el fondo la constituyen los hechos de la causa, que se establecen inamoviblemente por los jueces de las instancias, que para efectos de este recurso se llaman "jueces del fondo". El tribunal de casación sólo examina si en relación con ellos y en función del conflicto hay o no el quebrantamiento de ley o el error de derecho que se alega.

Pero hay que hacer notar que este es el principio básico y general; sin embargo, una cosa son los hechos de la causa y otra su establecimiento. Pues puede ocurrir que al dar por establecidos los hechos de la causa se haya cometido error de derecho. En tal evento, los hechos propiamente no son revisados, sino que sólo lo es su establecimiento, y por esta vía indirecta u oblicua el tribunal de casación puede decir que un hecho que aparece como establecido en realidad no lo está. Y así, se puede casar la sentencia y llegarse a una conclusión totalmente opuesta.

Pero téngase presente que el pilar esencial de la casación en el fondo es que ella parte de los hechos establecidos por los jueces del fondo, y salvo una situación excepcional que será vista, los hechos son inamovibles para el tribunal de casación.

9.5 Origen histórico de la casación en el fondo.

Es creación del genio jurídico francés, que fue modelando todo un sistema que a fines del siglo 18º se traduce en el recurso de casación en el fondo, o recurso de casación.



Casación viene del francés **casser**, que significa **romper, destruir y por extensión, anular. Con esta expresión, entonces, se quiere decir que lo que se pretende, jurídicamente, es romper, destruir, por extensión anular, la resolución judicial que se está impugnando.**

Este recurso se inscribe de lleno en la evolución histórica francesa en el enfrentamiento entre los monarcas y las pretensiones regionales de mayor autonomía o libertad, que se afincaban en los parlamentos, institución de antigua data en Francia y que no eran lugares donde se legislaba sino donde se resolvían conflictos, es decir, tribunales regionales.

Paulatinamente fueron adquiriendo mayor autonomía y pretendieron dictar normas de carácter general.

La lucha entre la monarquía y la unidad del país se centra entre los reyes y estos parlamentos. Montesquieu fue miembro de uno de ellos, y su gran versación jurídica nace de aquí. Los reyes franceses, ante esta demanda de mayor autonomía de los parlamentos, primero se arrogaron la facultad de revisar y eventualmente modificar las sentencias dictadas por éstos. Como esta labor les significaría dedicación exclusiva al tema, dictaron una norma que dispuso que se entendieran ineficaces las sentencias de los parlamentos contrarias a las normas reales.

O sea, se consagró que la labor legislativa sólo tocaba al monarca y en la medida en que el parlamento invada esta esfera, la sentencia respectiva es nula.

El paso siguiente arranca de las famosas Ordenanzas de Blois y consiste en que el rey conforma un consejo al que encarga examinar si las sentencias dictadas por los parlamentos se ajustan o no a las normas emanadas de la potestad reguladora del monarca, y le da facultades, cuando se reclama ante él, de anular la resolución del respectivo parlamento que infringe la norma legal.

Bajo el reinado de San Luis, rey de Francia (1226-1270) tenemos pues el origen o germen de este órgano colegiado llamado tribunal o corte de casación, antecedente para la creación de la casación en el fondo como institución por parte de la Convención Nacional de la Revolución Francesa.

Sin embargo, la filosofía jurídica es totalmente distinta, aunque se usa la misma estructura creada por este divorcio entre la monarquía y el deseo de autonomía de las regiones. Este recurso, en su nueva formulación que es la que perdura hasta hoy, se inscribe de lleno en las ideas de la Revolución Francesa inspiradas en la igualdad jurídica de los seres humanos, como respuesta al Antiguo Régimen.

Para afirmar la igualdad del ser humano es paso esencial asegurar su igualdad frente a la ley, es decir, la ley es una, única y común para todos. En consecuencia la ley debe ser uniformemente interpretada y aquí está la clave de la visión de la casación en el fondo por parte de la Convención Nacional Francesa. A este efecto se crea un organismo llamado a dar la recta inteligencia de la ley: la Corte de Casación. En sus orígenes estuvo conformada por un gran número de magistrados. Con el tiempo se ha dividido en salas para atender las necesidades jurídicas en forma adecuada.

De esta explicación deducimos el gran contenido social del recurso de casación en el fondo, porque a través suyo se pretende lograr la gran finalidad de la interpretación uniforme y la igualdad ante la ley. Pero este sentido social se logra a través del ejercicio del interés individual. O sea, el interés individual, que impugna una resolución judicial por serle agravante, se traduce en definitiva en la decisión jurisprudencial que señala el recto sentido y alcance de la ley.

Esta voluntad de uniformidad se ha ido haciendo patente en nuestro ordenamiento, y aun cuando el recurso de casación en el fondo es conocido por salas de la Corte Suprema, éstas se han dividido por especialidades, precisamente para evitar interpretaciones encontradas respecto de una misma cuestión. El legislador ha dado un paso más y señalado que si se recurre de casación en el fondo, y se señala que sobre el tema ha habido sentencias contradictorias en cuanto a fijar el debido alcance de la ley, el recurrente puede pedir que el recurso sea conocido y resuelto por el tribunal en pleno, para lograr así fijar el sentido jurisprudencial exacto.

La estructura de la casación fue recogida en el CPC napoleónico, desde el cual pasó a los cuerpos legales influidos por él, entre ellos el código español de enjuiciamiento civil, desde el cual fue recogido por nuestro ordenamiento.

9.6 Resoluciones susceptibles de casación en el fondo (art. 767)

1. Cabe en primer lugar y como regla muy general en contra de sentencias definitivas, es decir, aquellas que ponen término a la instancia resolviendo el asunto controvertido.

2. Excepcionalmente cabe contra sentencias interlocutorias pero sólo si ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, por ejemplo, la que declara el abandono del procedimiento, la que acepta el desistimiento de la demanda, la que falla un recurso de hecho interpuesto contra la resolución que denegó la apelación de una definitiva (si el recurso de hecho es desechado, queda a firme la definitiva). O sea, hay que ver en cada caso y según las circunstancias si la interlocutoria de que se trata pone término al juicio o hace imposible su continuación.

Advertencia: la sentencia que declara el abandono del procedimiento es recurrible de casación en el fondo, pero la sentencia que lo desecha no es casable en el fondo porque no pone término al juicio ni impide su continuación.

Ya advertimos que contra las sentencias casables en el fondo no debe proceder recurso de apelación, ya que a diferencia de la casación en la forma, en que la apelación es subsidiaria de ésta, la casación en el fondo jamás concurre con la apelación.

Si una resolución o sentencia es apelable no es casable en el fondo. Pero el recurso de casación en el fondo sí puede concurrir con el de casación en la forma, y en tal evento, lógicamente se lo entiende subsidiario de éste, ya que la casación en el fondo acepta la validez formal del fallo, pero dice de su nulidad substancial.

Cuando la sentencia recurrida es inapelable, no necesariamente significa que sea una sentencia de segunda instancia, ya que también puede ser de única. Por ejemplo, una resolución de corte de apelaciones que conoce reclamo deducido contra dictamen de la Superintendencia de Valores y Seguros es resolución de única instancia casable en el fondo porque no es apelable.

Ya hemos dicho también que el tribunal a quo en este recurso es la corte de apelaciones, cuya sentencia puede ser de segunda o única instancia, y el tribunal arbitral de derecho que conoce en segunda instancia materias propias de una corte de apelaciones, y cuya sentencia, necesariamente, debe ser dictada en segunda instancia.

El tribunal arbitral debe ser necesariamente de derecho, porque los arbitradores fallan según la equidad y su prudencia. Como la resolución de un árbitro de derecho no es apelable, es por tanto casable en el fondo. Si la sentencia emana de árbitros mixtos, como la ley los estima una especie del género "árbitro de derecho", hay que concluir que contra la sentencia de este árbitro procede también casación en el fondo, independiente del origen de su designación. Salvo, claro está, que en el compromiso arbitral las partes hayan renunciado a recurrir a la casación.

En ningún caso procede casación en el fondo contra la sentencia dictada por un juez de letras.

9.7 Cómo se puede producir la infracción de ley.

No está expresamente regulada por el legislador. Tiene dos grandes vertientes, de acuerdo a la elaboración doctrinaria y jurisprudencial: en cuanto a su inteligencia o comprensión y en cuanto a su aplicación.

1. En cuanto a su inteligencia o comprensión:

Podemos estar en dos casos distintos:

a) si se trata de una ley clara: se vulnera su inteligencia cuando se desconoce su tenor literal, es decir, el juez leyó "no" donde decía "sí".

b) si se trata de una ley obscura se puede vulnerar su inteligencia en cuanto a su interpretación. Sabemos que la ley clara no necesita ser interpretada, ya que no se puede desatender su tenor literal, su sentido, a pretexto de consultar su espíritu, como dice el CCv

Pero tratándose de una ley obscura, es necesario precisamente interpretarla, y la interpretación en nuestro sistema está regulada por las normas de hermenéutica legal del CCv (Arts. 19 y ss). Hubo una larga discusión doctrinaria sobre si estas normas eran unas en subsidio de otras o debían aplicarse conjuntamente. Hace medio siglo se sostenía que estas reglas se aplicaban unas en subsidio de otras. Hoy, en cambio, la doctrina dominante dice que estas normas de interpretación se aplican conjugadamente.

Esta materia es importante, porque cuando se dice de "errónea interpretación de la ley" no tan sólo se debe dar por infringida la norma substancial que se afirma vulnerada, sino también la norma de interpretación que no se aplicó.

Por ejemplo, se afirma que una ley se interpretó mal, o que el término técnico usado por una ley no se interpretó conforme a éste sino al sentido vulgar de la palabra.

Por ejemplo, "doy por infringido el art. 8º de la ley de comercio exterior que habla del término FOB porque no se le dio a éste su sentido técnico, infringiendo así el art. 21 del CCv, que obliga a darle a las normas el sentido técnico de la ciencia o arte respectivo, por regla general.

2. En cuanto a su aplicación:

Aquí también se deben ver dos aspectos: preterición y falsa aplicación.

a) preterición: significa no aplicar una norma a la situación concreta de conflicto cuando esa norma era aplicable. Ejemplo: respecto de la regulación de la sociedad conyugal, se establece que todos los bienes adquiridos a título oneroso le pertenecen. El juez deja de aplicar esta norma y dice que los bienes adquiridos a título oneroso son del respectivo cónyuge que los adquirió.

b) falsa aplicación: consiste en aplicar al conflicto una norma que no era aplicable dada la naturaleza de éste. Ejemplo: aplicar una norma de excepción a una situación regulada por la regla general. En el caso de la sociedad conyugal, el juez declara que la mujer tiene patrimonio reservado por el solo hecho de

tener un título profesional, con lo cual está aplicando una norma que no corresponde aplicar, porque el patrimonio reservado requiere además un trabajo separado del cónyuge.

Hay varios posibles "pecados mortales" respecto de la casación en el fondo: 1) dar por infringida cuanta norma se me ocurra, con lo que este recurso se convierte en un verdadero mamotreto; por ejemplo, dar por infringidas 50 ó 60 disposiciones distintas; 2) por el contrario, ser demasiado escueto y no invocar como infringidas ciertas normas que precisamente deben tenerse por tales; ó 3) dar por infringidos, vg, "el art. 84 y siguientes del CCv". Esta forma de plantear el recurso conlleva su muerte inmediata e irremediable, porque al señalar la ley no se puede disparar a la bandada, sino indicar en forma precisa y determinada cuál es la norma que se da por infringida.

En este sentido hay que tener cuidado porque dentro de un mismo artículo puede haber distintas normas. Y así, deberá precisarse si se da por infringido el inc. 1º, 2º etc.

Por lo tanto, hay que cuidarse de caer en ambos extremos y señalar todas las normas que se vinculan a la cuestión y dicen relación con el conflicto mismo y su forma de resolverlo.

9.8 Concepto de ley para efectos de la casación en el fondo.

Como ya hemos dicho, para este recurso se requiere infracción de ley con influencia substancial en lo dispositivo del fallo, término que ha sido ampliado por el art. 772 respecto del ámbito del art. 767, al hablar de "error de derecho". Pero en general, el criterio es que este error de derecho debe traducirse precisamente en infracción de ley.

Ley se entiende:

1. En primer lugar lo que el CCv define en su art. 1º. O sea, si una norma jurídica emana de la expresión confluyente de los poderes legisladores y ha sido aprobada y debidamente publicada, es ley para efectos de este recurso. Puede ser una ley permanente o transitoria, incluso un artículo transitorio de una ley, y, naturalmente, que sea aplicable al conflicto del que se trata.

2. Los tratados internacionales ratificados por la República, promulgados por el presidente y publicados en el diario oficial. Sin embargo, hay una norma legal que permite que ciertos tratados internacionales, a diferencia de la ley, entren en vigencia sin necesidad de ser publicados en el diario oficial, bastando que queden archivados en determinadas colecciones del ministerio de RREE y del Congreso.

3. La Costumbre: en nuestro ordenamiento nunca es fuente del derecho cuando es contra ley. Sólo lo es cuando la ley se remite a ella expresamente (civil) o en silencio de la ley (mercantil).

Entre otros casos en que la ley civil se remite a la costumbre, dándole fuerza legal. Por ejemplo, en el mandato respecto de los honorarios del mandatario a falta de acuerdo de las partes. También en materia de pesos y medidas.

En materia mercantil la costumbre tiene mayor fuerza probatoria.

Ahora bien, la infracción de la costumbre civil cuando la ley se remite a ella, o de la costumbre mercantil en el silencio de la ley, puede considerarse infracción de ley y legitimaría la casación en el fondo.

Pero son cosas distintas la costumbre y la prueba de ésta. Partimos de la base que la costumbre se da por establecida en virtud de la prueba anterior o cuando el juez la declara conocida por él -- facultad del juez mercantil --. Pero en este caso sólo sería causal de casación en el fondo, por parangonarse a la infracción de ley, cuando se trata de una costumbre reconocida como tal en la respectiva sentencia.

4. La legislación extranjera: la jurisprudencia estima que puede invocarse como infracción de ley, en la medida en que la ley nacional se remita a ella. O sea, si la legislación nacional ordena que una determinada situación sea regulada por la ley extranjera, ésta se entiende incorporada a nuestro ordenamiento, y en consecuencia su infracción se asimila a la infracción de la ley chilena.

Un ejemplo, es la norma del CCv que ordena que la sucesión se regula por la ley del último domicilio del causante. Así, si una persona murió en Alemania y dejó bienes y herederos en Chile, la regla general es que su sucesión se rija por la ley alemana. Y en consecuencia, el desconocerla o quebrantarla en este caso, da pie a la casación de fondo.

5. El contrato: sabemos que al contrato legalmente celebrado se incorpora la legislación vigente al momento de hacerlo, pero también se puede incorporar otras legislaciones. Pero en tal caso, la ley extranjera no pasa a ser norma legal, sino contractual.

El art. 1545 del CCv establece que el contrato es ley para las partes contratantes. En consecuencia, si en un juicio un conflicto se ha resuelto quebrantando la normativa que arranca del contrato, debería entenderse en principio que en él se ha quebrantado la ley.

Pero nuestra jurisprudencia ha sido contraria a esta tesis, y ha estimado que cuando el legislador dijo en el art. 1545 que el contrato es "ley para los contratantes" sólo usó una expresión retórica y no substantiva, para subrayar la fuerza vinculante del contrato. Pero no fue su voluntad elevarlo al nivel de las normas legales.

Si su origen arranca de la voluntad del legislador en cuanto a la aplicación e interpretación uniforme de la norma legal, el pretender que la infracción contractual pueda servir de base para decir de casación en el fondo no se condice con este principio.

6. El DFL y el DL: el DFL sólo es reconocido constitucionalmente en la Carta de 1980. Pero la costumbre jurídica había consagrado la existencia de estos, que nacían de ley delegatoria que permitía al Presidente de la República abordar en ellos materias propias de ley.

La Carta de 1980 reconoce los DFL, pero en un ámbito restringido, ya que hay materias que no pueden ser materia de él. En virtud de esta homologación entre ley y DFL, la jurisprudencia uniforme y reiterada de la Corte Suprema señala que la infracción del DFL puede también dar pie a recurrir de casación en el fondo.

Frente a los DL si bien se ha estimado que son formalmente inconstitucionales, se les ha aceptado con vigencia y vigor de ley. Este criterio se ha mantenido y aun ratificado, porque el congreso a contar de

1990 ha modificado muchos DL, con lo cual los ha reconocido y ratificado su vigencia como voluntad legislativa.

En consecuencia, la jurisprudencia ha estimado que las violaciones de los DL también dan mérito a recurrir de casación en el fondo.

7. La Constitución: creciente importancia en función de la protección de los derechos individuales, garantizados por los llamados "recursos de carácter constitucional": protección, amparo, amparo



económico, inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Hay cuestiones no directamente reguladas por la ley, sino por la Constitución. Podemos imaginar que hay conflictos de relevancia jurídica cuya normativa sea la Carta fundamental y no la ley. Surge aquí la pregunta: **¿la infracción de la Constitución es infracción de ley para efectos de la casación en el fondo?**

Claramente la respuesta es sí. La infracción de normas constitucionales da pie a recurrir de casación en el fondo.

8. El Decreto Supremo, Reglamento u Ordenanza: la eventual infracción a estas normas, que nacen como consecuencia de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, ¿ Sobre el particular cabe recoger la distinción que hace hoy el sector público entre potestad reglamentaria autónoma y subordinada.

Esta última emana de una ley preexistente, respecto de la cual el decreto la reglamenta o complementa (ejemplo., reglamento de la ley eléctrica), mientras que la potestad autónoma emana de la norma constitucional que permite al presidente de la República dictar normas sobre materias no objeto de ley. Los ius publicistas estiman que el ámbito real de aplicación de esta facultad es muy estrecho, ya que es difícil encontrar alguna materia que pueda quedar fuera del ámbito legislativo y ser objeto de esta potestad autónoma, en teoría al menos existe y cabe preguntarse cómo juega en función de la casación en el fondo.

Respecto de los decretos supremos, la jurisprudencia unánime y reiterada es que aunque tengan la forma de reglamentos u ordenanzas, su infracción no da mérito a un recurso de casación en el fondo. Es decir, aunque el concepto ley es amplio en esta perspectiva, no lo es tanto para incluir al decreto supremo.

Si bien es cierto que esta jurisprudencia se ha referido a la potestad reglamentaria subordinada, las razones dadas respecto de aquélla son, a su juicio, aplicables a ésta.

Con todo, hay ciertas ordenanzas que son leyes, es decir, hay que ir más a la calificación jurídica respectiva que a la nomenclatura que se usa para identificarlas. Por ejemplo, la ordenanza general de aduanas, la ordenanza general de construcciones.

9. La doctrina legal: aunque es fuente del derecho, claramente su eventual infracción no da pie a recurrir de casación en el fondo.

En Chile, como en la mayoría del mundo, la doctrina legal es una fuente supletoria del derecho, si bien muy importante, pero sin fuerza vinculante, a diferencia del Derecho Romano con la llamada "ley de

citas". Es opinable lo que ocurre cuando el legislador se remite a la doctrina como fuente del derecho, en especial en materia de derecho internacional. Estimamos que dada la estrictez de nuestra jurisprudencia, un recurso de casación en el fondo basado en esta causal sería declarado inadmisibile. Pero es materia altamente opinable.

Más aún si la Corte Suprema ha dicho que las normas del Código de Bustamante constituyen respecto de los países no vinculados a él, "claros y decantados principios" del derecho internacional, al aplicarlas a la solución de algunos conflictos.

Reiteremos que **"influencia substancial"** en lo dispositivo del fallo significa que debe haber una relación de causa-efecto indisoluble entre el error que se denuncia y la decisión del respectivo tribunal. O sea, si se ha cometido un error de derecho que no se refleja en la decisión misma, como no tiene influencia substancial en lo dispositivo del fallo no es invocable como causal de casación en el fondo.

Tiene que haber claramente un ejercicio de carácter intelectual: qué pasa en la parte dispositiva del fallo si se suprime in mente el error de derecho. Esto es importante porque en el escrito en que se deduce la casación en el fondo hay que señalar cómo influye la infracción de ley.

9.9 Limitaciones a la casación en el fondo.

1. No puede invocar como causal la infracción de una norma que dé a su vez pábulo para invocar casación en la forma. O sea, si la norma que se pretende infringida es de aquellas que permiten recurrir de casación en la forma, el recurso de casación en el fondo es inadmisibile.

Esto tiene una razón lógica elemental: la casación en el fondo acepta la validez formal de la sentencia recurrida y sólo la ataca por razones de nulidad substancial. Es claro que si se asienta un recurso de casación en el fondo en causales que ameritarían una casación en la forma, se está diciendo de nulidad formal del fallo, no de nulidad substancial.

Al respecto insistamos en la distinción doctrinaria entre las leyes ordenatorio litis, que miran a la ritualidad en la marcha de los respectivos juicios, y las leyes decisorio litis, que miran precisamente a la solución del conflicto del que se trata.

Algunos, basándose en esta distinción y tomando pie en la clara limitación ya explicada han dicho que la casación en el fondo no puede fundarse en leyes ordenatorio litis, sino que precisamente debe basarse en leyes decisorio litis. Estimamos que esta afirmación es gravemente inexacta, porque la distinción entre leyes ordenatorio y decisorio litis no es absolutamente tajante, sino que hay zonas grises en que es dudosa la calificación de una ley en una u otra categoría. Por ejemplo, las normas sobre el peso de la prueba. Puede argumentarse extensamente en favor de una u otra categoría porque es un campo altamente opinable. O la norma que enumera los medios de prueba, por citar algunos ejemplos.

Además hay que tener presente que el recurso de casación en el fondo se puede deducir contra interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. Y cuando se dice de casación en el fondo contra esta categoría de resoluciones, muchas veces se fundamenta el recurso en normas procesales, que con este criterio deberían calificarse como ordenatorio litis. Por ejemplo, si

incurriendo en error de derecho, se computó indebidamente un plazo para declarar el abandono del procedimiento, se dice de infracción de norma procesal. Pero en el caso de que se trate, esta infracción puede ser fundamento suficiente para una casación en el fondo.

2. Los hechos de la causa: como regla muy general, son función exclusiva y excluyente del juez de la instancia o del fondo. Es decir, si un hecho está o no establecido, o cuáles son los hechos que se han establecido, es una materia intangible para el tribunal de casación, por regla general.

Así, vg, si yo digo que Juan le entregó a Pedro un millón de pesos en una sentencia de segunda instancia, como regla muy general la corte de casación no puede revisar esa afirmación fáctica, sino que debe partir de ella y ver si se produce la infracción de ley que es alegada

Esta intangibilidad de los hechos de la causa para el tribunal de casación es justamente lo que permite afirmar con gran fuerza que la casación en el fondo no constituye tercera instancia, porque estos hechos quedan fuera de su posible censura.

Y la instancia, como grado jurisdiccional que es, permite el pronunciamiento tanto respecto de los hechos del conflicto como del derecho aplicable.

Con respecto a esta materia, tengamos presente el art. 807 del CPC, que señala que en el recurso de casación en el fondo los hechos ya están señalados en la sentencia recurrida, y este tribunal, por ende, no puede admitir prueba alguna que tienda a modificar los hechos ya establecidos, ni ordenar probanza alguna como medida para mejor resolver. Téngase presente además que respecto de la casación en la forma la norma es distinta, ya que se puede abrir un término de prueba, si bien sólo referido a la causal invocada y no al conflicto mismo. Tratándose de casación en el fondo no es admisible prueba alguna.

Pero hay que hacer algunas precisiones sobre el punto: son dos cuestiones distintas el hecho establecido y su calificación jurídica.

Es decir, si la sentencia dice que efectivamente Juan entregó a Pedro 10 millones de pesos, como regla muy general este hecho no cae bajo la posible censura del tribunal de casación.

Pero si la sentencia recurrida dice que esos 10 millones fueron entregados a título de pago, la corte de casación, calificando el hecho, puede decir que se los entregó a título de préstamo, porque la calificación jurídica del hecho cae de lleno en las potestades del tribunal de casación.

Por otro lado, también caen de lleno en las potestades de éste las posibles consecuencias jurídicas del hecho establecido, pese a que este mismo le es, en gran medida, intangible.

9.9.1 Hecho establecido y establecimiento del hecho.

Hay que hilar más fino y hacer una distinción entre el hecho establecido y el establecimiento del hecho.

La jurisprudencia ha dicho que el hecho establecido es intangible al tribunal de casación, salvo que se haya cometido error de derecho en su establecimiento. Es decir, si el hecho se ha establecido observando las leyes reguladoras respectivas, es intangible al tribunal de casación. Pero si ha sido establecido infringiendo las leyes reguladoras de la prueba, puede ser revisado por el tribunal de casación en cuanto a si efectivamente se lo puede dar por establecido.

9.9.2 Las leyes reguladoras de la prueba.

Recordemos que el fenómeno probatorio se refiere a un cúmulo de situaciones, que sucesivamente son: el peso de la prueba, cuáles son los medios de prueba, cuáles son los medios admisibles en el caso concreto, el valor de estos medios y la forma de producir la prueba.

a) Claramente la forma de producir la prueba no da pie a la casación en el fondo, porque cae de lleno en la primera limitación: la infracción a este respecto es causal de casación en la forma.

b) En tanto, la alteración del peso de la prueba es claramente causal de casación en el fondo. Por ejemplo, si una sentencia declara que no se da lugar a la demanda porque el hecho debía probarlo el demandante, cuando en realidad debía probarlo el demandado, claramente es casable en el fondo si efectivamente se cargó con el peso de la prueba a quien no correspondía.

c) En cuanto a la admisión de los medios de prueba, sea por admitirse en la sentencia recurrida uno que la ley no contemplaba, o rechazarse otro que la ley sí contemplaba expresamente y se da por acreditado un hecho a causa de este error, la corte puede admitir y eventualmente acoger la casación en el fondo. En este caso el hecho no se ha establecido porque hubo error de derecho en su establecimiento.

Ejemplo: en su sentencia el juez dice que es de conocimiento del tribunal que al celebrar el contrato, don Juan Pérez estaba claramente en falencia y se la da por establecida como hecho de la causa. Contra este fallo se recurre de casación en el fondo, dando por infringidas la norma civil y la procesal que enumeran los medios de prueba, porque dentro de ellas no está el conocimiento privado del juzgador, que es el medio al que recurre el juzgador, en este ejemplo, para dar por establecido el hecho. La corte de casación acogerá el recurso y dar por no establecida la falencia en la época señalada por el fallo recurrido.

d) En cuanto al valor probatorio.

Ejemplo: la Corte Suprema en primer término rechazó de plano un recurso y luego lo admitió en virtud de una reposición. En el juicio, el vendedor pretendía probar lesión enorme del comprador en la compraventa de un departamento y declarar su nulidad relativa. Para acreditar que el comprador había pagado menos de la mitad del justiprecio, el demandante (vendedor) acompañó una serie de escrituras públicas de otras compraventas del mismo edificio, con las que se pretendió acreditar los precios efectivamente pagados. La Corte de Apelaciones dijo que estas escrituras eran presunciones sobre el

precio de mercado de los respectivos inmuebles, dando por acreditada la lesión enorme. Se recurrió de casación en el fondo, alegando que según las normas del CCv, la presunción debe basarse en hechos probados, no en otras circunstancias. Los instrumentos públicos respecto de terceros no hacen fe respecto de la verdad de las declaraciones, según el CCv. En consecuencia, lo dicho en esas escrituras en cuanto al precio pagado en cada compraventa no es hecho establecido ni puede darse por hechos ciertos. En consecuencia, no se puede construir una presunción sobre su base. La Suprema finalmente aceptó el raciocinio y dijo que no se miraba a la valoración de la presunción sino en cuanto a la forma de construirla y en este sentido se estaban violando las leyes reguladoras para darla por establecida.

9.10 Plazo y forma del recurso de casación en el fondo.

El plazo es de 15 días y se cuenta desde la notificación de la resolución o sentencia contra la cual se recurre, sin perjuicio del art. 791, norma muy especial sobre la casación en el fondo en juicios de mínima cuantía.

Si se deduce casación en la forma en contra de la misma resolución, se deben intentar conjuntamente (Arts. 770 incs 1º y 2º y 808).

9.11 Interposición conjunta de ambas casaciones.

La norma señala claramente que acogida la casación en la forma se tiene por no deducida la casación en el fondo. En consecuencia, este último recurso es subsidiario del primero, porque como ya se ha dicho, parte de la validez formal de la sentencia recurrida y afirma su nulidad substancial. (En lo principal deduce casación en la forma, en el primer otrosí casación en el fondo, en el segundo otrosí designar patrocinio de ambos recursos).

Ambos recursos tienen estructuras distintas por lo que deben ir perfectamente separados. Debe designarse patrocinio para ambos recursos, y el patrocinante debe firmar en señal de aceptación.

9.12 Requisitos del escrito de casación en el fondo.

Distinguimos en él tres requisitos substanciales y uno formal (art. 772).

1. Requisitos substanciales:

- Indicar la ley o leyes que se dan por infringidas o el error de derecho en que se ha incurrido.
- Señalar cómo se ha producido la infracción.
- Señalar de qué manera esa infracción influye substancialmente en lo dispositivo del fallo.

2. Requisito formal:

- Designar abogado patrocinante del recurso que no sea procurador del número.

9.12.1 Requisitos substanciales

1. Indicar **la ley o leyes que se dan por infringidas o el error de derecho en que se ha incurrido**. Error de derecho: es un capítulo corto y se limita a señalar las normas que el recurrente pretende quebrantadas. Hay que señalar todas las normas que directamente se vinculan al conflicto del que se trata y cuyo quebrantamiento motivó su resolución distinta de la que correspondía correctamente. No caer en

superabundancia ni en extrema parquedad. Evitar extremos pero ser precisos. Muchas veces ocurre que la corte desestima un recurso que da por infringida una norma y no la otra que también era necesario citar.

Nuevamente la advertencia: jamás se dice, por ejemplo, "doy por infringido el art. 1698 y siguientes del CCv". Tal recurso es rechazado de plano.

Adicionalmente, digamos que muchas veces no basta remitirse al número del artículo, sino al inc., subinciso, numeral dentro del número, etc. Por ejemplo, el art. 17 de la espantosa Ley de la Renta, que por sí solo podría ser un código. O sea, un recurso de casación que dé por infringido el art. 17 de la Ley de la Renta.

2. Cómo se produjo la infracción: si bien es cierto la Suprema ha ido abriendo un poco la mano en esta materia, no siendo excesivamente exigente, hay que recordar al plantear este capítulo cuáles son las formas de infracción de la ley, que pueden ser en cuanto a su inteligencia y aplicación. Recordemos que al dar por infringida una norma de interpretación, hay que hacer además expresa mención de la ley de hermenéutica infringida. Hay que decir que la norma tal se aplicó a esta situación sin ser aplicable. Dar las razones jurídicas para sustentarla. Nuevamente precisión sin extenderse desmesuradamente.

Por ejemplo, alegar que el sentenciador aplicó las normas del patrimonio reservado de la mujer casada del art. 150 del CCv a un juicio al que no era aplicable porque ella no ejercía actividad separada de su marido.

3. Cómo esta infracción influye en el fallo: en este punto normalmente "mueren" los novatos. No es correcto decir: si no se hubiese aplicado esta norma, cometiendo el error de derecho indicado, la sentencia habría declarado lo contrario y en consecuencia, es evidente que de no haberse cometido este error, la resolución habría sido diametralmente opuesta.

Lo correcto es reconstruir la cadena lógica completa: si no se hubiese quebrantado -- o aplicado -- la norma tal en la forma denunciada, primero se habría tenido que cumplir tal cosa y esta conclusión habría conllevado la siguiente y ésta la siguiente, y en consecuencia el fallo debió haber declarado esto y no aquello.

En suma, hay un ejercicio intelectual en que se reconstruye la exacta decisión de no haberse producido este quebrantamiento.

9.12.2 Requisito formal.

Designar abogado patrocinante del recurso: no es lo mismo del abogado patrocinante de la causa. Pueden ser la misma persona, pero no basta con la designación genérica del patrocinante de la causa.

9.13 Tramitación del recurso de casación en el fondo.

1. Ante el tribunal a quo: es idéntica a la tramitación de la casación en la forma (Arts. 776 y 778). El tribunal a quo sólo puede examinar si el recurso se ha interpuesto en tiempo y ha sido patrocinado por abogado habilitado. Las demás circunstancias las examina el tribunal ad quem.

También es carga del recurrente pagar el franqueo, conforme al art. 777, obviamente si los asientos del tribunal a quo y ad quem son distintos.

El franqueo se paga sólo si la contraparte lo pide y el tribunal le ordena hacerlo en cierto plazo, bajo apercibimiento de tener por no interpuesto el recurso.

2. Ante el tribunal ad quem: que en este caso, sabemos, es la Suprema.

Llegados los autos a ésta, al igual que en la apelación se estampa un certificado de ingreso, que determina el plazo a partir del cual las partes se pueden hacer presentes en la tramitación del recurso. La Suprema examina en cuenta la admisibilidad del recurso (Arts. 782 y 781), es decir, si ha sido interpuesto en tiempo y forma. Este examen en cuenta lo hace la misma sala de la Suprema que debe conocer la casación en el fondo.

La resolución que rechaza la admisibilidad del recurso puede ser objeto de reposición (art. 781), la cual debe ser fundada e interponerse dentro de 3º día.

Cuando se trata de casación en el fondo, el art. 780 permite que la parte, dentro del plazo que tiene para comparecer, solicite que el recurso no sea fallado por la sala respectiva sino por el tribunal en pleno. Puede ejercer esta facultad cuando la Suprema ha tenido doctrinas contradictorias respecto de la cuestión de derecho que se somete a conocimiento del tribunal.

El tribunal se pronuncia sobre esta petición cuando examina en cuenta su admisibilidad, y en tal evento puede dar lugar a ella o denegarla y de esta resolución también se puede pedir reposición dentro de 3º día.

Téngase presente que en la Suprema, si el recurso se estima inadmisibile, se declara así por resolución someramente fundada; pero si se estima admisible, la resolución es sólo "autos en relación". Es decir, no hay una declaración expresa de admisibilidad sino que implícitamente ésta arranca de dicho decreto. La declaración de admisibilidad que se declara en cuenta es sin perjuicio de lo que se resuelva al conocer del recurso, porque incluso conociéndolo, es decir, entrando en su fondo, todavía la Suprema puede declararlo inadmisibile. O sea, la resolución que declara implícitamente la admisibilidad mediante el decreto autos en relación no vincula a la propia corte cuando conoce del fondo del asunto.

El art. 782 incs 2º y 3º contempló una facultad de la cual la Corte Suprema antes no estaba revestida: en el examen en cuenta, es decir, al pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación en el fondo, puede rechazarlo de plano aunque sea admisible, si estima por unanimidad que adolece de manifiesta falta de fundamento.

Esta resolución debe ser al menos someramente fundada y es reponible dentro de 3º día.

Es decir, hay un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que emana sólo de la cuenta y que se traduce en el rechazo de un recurso admisible. Como ya advertimos, el legislador tuvo la precaución de indicar que debe ser por fallo unánime, pero es una enorme facultad que se da a la Suprema para, por esta vía, empezar a desestimar recursos de casación en el fondo. Puede ser fuente de injusticias.

Ahora bien, no obstante estimarse inadmisibile el recurso, en todo caso la Suprema puede ordenar traer los autos en relación si estima que puede concurrir una posible causal de casación, sea en la forma o en el fondo. Respecto de la casación en la forma, ya dijimos que el tribunal puede casar en la forma, por cualquier vía que llegue a su conocimiento un determinado asunto.

Una de las formas por las cuales puede llegar a su conocimiento es por la interposición de un recurso de casación en el fondo. Por ejemplo, un recurso de casación en el fondo es manifiestamente inadmisibile, pero en este examen preliminar el tribunal advierte que hay una clara causal de casación en la forma que no fue objeto de recurso. En tal caso, puede, pese a declarar inadmisibile el recurso de casación en el fondo, ordenar traer los autos respecto de la casación en la forma, para ejercitar la facultad de casar de oficio. Así se desprende del art. 781 inc 3º.

9.14 Vista de la causa y duración de los alegatos.

Se remite a las normas de la apelación, pero aumentando substancialmente el plazo de que disponen los abogados para hacer sus alegatos: una hora en la casación en la forma y dos en la casación en el fondo. En los demás asuntos de que conozca la Suprema, las alegaciones sólo podrán durar media hora. Así, vg, materias de tanta trascendencia como un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, donde las materias debatidas son de gran envergadura, esta limitación es una seria cortapisa.

Agreguemos que el art. 805 permite a cada parte presentar, hasta antes de la vista de la causa, informes en derecho que son escritos y aun pueden presentarse impresos. Para efectos de estos informes no se pueden retirar los autos de la secretaría, y en la vista no se pueden hacer alegaciones ajenas ni leer piezas o autos, salvo autorización expresa del tribunal.

9.15 Fallo del recurso.

El inc. final del art. 805 señala un plazo de 40 días, meramente referencial, para el fallo del recurso. No es usual que los tribunales lo observen.

Por último, recordemos que si se deducen conjuntamente casación en la forma y en el fondo contra una misma sentencia, se tramitarán conjuntamente y se resolverán en un mismo fallo. Se resuelve primero la casación en la forma, y se la acoge se tiene por no interpuesta la casación en el fondo. Sólo si se rechaza la casación en la forma se entra al análisis de la casación en el fondo.

Acogidas, sea la casación en la forma o en el fondo, se dicta la sentencia de reemplazo correspondiente.

9.16 Naturaleza jurídica de la sentencia de casación

No es una sentencia definitiva; tampoco es interlocutoria. Se llama genéricamente "sentencia de casación".

El art. 785 señala que cuando se acoge la casación en el fondo se dicta, acto continuo y sin nueva vista, la sentencia de reemplazo, en la cual se reproducen de la sentencia de primera instancia o de la de casación los considerandos que se estime necesarios.

9.17 Casación en el fondo y cumplimiento de la sentencia recurrida.

Se aplican las mismas disposiciones estudiadas a propósito de la casación en la forma.

9.18 Extinción de la casación en el fondo.

También nos remitimos íntegramente a lo señalado respecto de la casación en la forma, porque las causales de extinción de ambas casaciones son idénticas, con las formas normales y anormales de extinción.

Tema 10: Casación en el Fondo de Oficio.

En virtud de la reforma general a la casación, de 1995, se estableció la posibilidad de la casación en el fondo de oficio, que sólo procede cuando se declara inadmisibile el recurso de casación por defectos en su formalización. Esta facultad está en el art. 785 inc. 2º y antes era imaginable que la Suprema pudiera casar de oficio en el fondo.

El art. 785 la restringe porque le establece varias cortapisas que limitan substancialmente el ámbito de esta facultad.

Estas limitaciones son las siguientes:

1. La Corte Suprema sólo puede ejercer esta facultad cuando está conociendo de un recurso de casación en el fondo.
2. La Corte Suprema debe estimar que el recurso es inadmisibile por defectos en su formalización. Recordemos que el escrito de formalización es particularmente exigente. Si se han cometido errores a su respecto, no obstante declarar inadmisibile este recurso, la Suprema puede casar en el fondo de oficio.
3. Al hacerlo, debe señalar las razones por las cuales estima del caso hacer uso de esta facultad, y luego dictará por separado la correspondiente sentencia de reemplazo.

Por último, digamos que lo mismo que ocurre con la apelación en materia civil, el recurso de casación en el fondo es un recurso personal, es decir, que no tiene efectos sino en relación con los recurrentes y recurridos. Es decir, si contra una determinada sentencia, cuando son varias las partes que litigan en un mismo juicio, recurren de casación unos pero otros no, la suerte de la casación en el fondo sólo afecta a recurrentes y recurridos. Si alguna de las partes no recurrió, queda fuera del alcance o consecuencias de la respectiva casación.

Tema 11: Recurso de Revisión.

11.1 Concepto.

Es un recurso extraordinario cuya finalidad es que la Corte Suprema revea sentencias definitivas, firmes o ejecutoriadas, en los casos expresamente autorizados por la ley.

11.2 Naturaleza jurídica.

En primer lugar hay que despejar la incógnita de si es propiamente un recurso. Hemos señalado en varias ocasiones que recurso procesal es una manera de impugnar resoluciones judiciales, las cuales en ciertos casos adquieren la fuerza de cosa juzgada, con lo cual pasan a tener dos características propias y consubstanciales a ella: inmutabilidad e inimpugnabilidad.

Surge la duda de cómo plantear una impugnación respecto de una resolución que es, por esencia, inimpugnable, en la medida que se encuentra firme o ejecutoriada.

Esta dicotomía entre el concepto de la cosa juzgada y la existencia del recurso de revisión ha llevado a muchos a sostener que desde el punto de vista estrictamente doctrinario no estamos frente a un recurso, sino frente a una acción procesal, la que se dirige en contra de una sentencia aparentemente firme o ejecutoriada.

Se dice que es una sentencia "aparentemente" firme o ejecutoriada porque, como veremos al examinar las causales de revisión, la mayoría de ellas son para reclamar del fraude. En consecuencia, quien recurre de revisión está diciendo de sentencia obtenida en forma fraudulenta.

Y la doctrina ha acuñado el término "cosa juzgada fraudulenta", que es la negación de la cosa juzgada por ser el resultado de un montaje malicioso.

En consecuencia, se ha dicho que el recurso de revisión no es un desconocimiento al principio de la cosa juzgada, sino un homenaje a éste, porque en verdad no hay cosa juzgada si ella es fraudulenta.

Respecto de la segunda posible causal de revisión, el haberse dictado la sentencia que se pretende revisar contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, el recurrente sostiene que la segunda sentencia es sólo aparentemente basada en autoridad de cosa juzgada, porque hay que darle primacía a la primera sentencia que sí está auténticamente asentada en cosa juzgada.

De esta manera concluimos que, en el fondo, el recurso de revisión no constituye excepción al principio de la cosa juzgada, porque por una parte se dice de fraudulencia en su consecución y no hay cosa juzgada con fraude, y por la otra se dice de preeminencia de la cosa juzgada de una sentencia ya dictada por sobre una posterior que pretende tener también el carácter de cosa juzgada.

11.3 Características de este recurso.

- 1.** Es extraordinario. Primero, porque sólo cabe respecto de determinadas resoluciones judiciales, y en segundo lugar porque tiene causales específicas de interposición. No basta invocar agravio genérico.
- 2.** Es de competencia exclusiva de la Corte Suprema. Sólo puede ser planteado ante ella y conocido por ella, la cual lo conoce en sala, no en pleno, conforme a las normas del COT.
- 3.** Sólo cabe contra sentencias definitivas aparentemente firmes o ejecutoriadas. Aun cuando el texto no es del todo claro, se ha concluido que no cabe respecto de sentencias interlocutorias.
- 4.** Debe interponerse respecto de sentencias definitivas que aparezcan como firmes o ejecutoriadas. O sea, no cabe contra sentencias definitivas en relación con las cuales sea posible interponer otros recursos procesales.
- 5.** Como ya decíamos, deben invocarse causales específicas, es decir, en los casos expresamente señalados por la ley.

Volvemos sobre la naturaleza jurídica del recurso de revisión. Algunos han dicho que al impugnar una resolución judicial se trataría efectivamente de un recurso, ya que esta es la finalidad esencial de éstos. Pero hay una observación: en sentido estricto, los recursos procesales sólo caben respecto de resoluciones que no estén firmes o ejecutoriadas, ya que este carácter acarrea su inmutabilidad e inimpugnabilidad. Entonces, la revisión no sería un recurso, ya que cabe precisamente contra sentencia firme o ejecutoriada, ya que la inmutabilidad e inimpugnabilidad son de la esencia de este efecto.

En esta perspectiva, se ha creído ver en este recurso de revisión más bien una acción procesal de revisión.

11.4 Revisión y cosa juzgada.

Respecto a otro tema también esbozado, en cuanto a si el recurso de revisión es o no excepción al principio de la cosa juzgada, digamos que se trata de una materia de gran importancia doctrinaria, para cuya acertada resolución la propia ley nos da ciertos caminos.

Si vemos las causales del recurso de revisión, tres de ellas se refieren a situaciones en las cuales la sentencia firme que se ataca ha sido objeto de una maquinación fraudulenta, o sea, que sólo producto de un montaje, de un despliegue doloso, ha sido posible obtener esta sentencia en apariencia firme o ejecutoriada.

El principio doctrinario es que el fraude corrompe todo. O sea, si una sentencia ha sido obtenida en forma fraudulenta, la cosa juzgada que de ella emana no es propiamente tal. En esta perspectiva, algunos tratadistas -- entre ellos Hugo Pereira -- han hablado de "cosa juzgada fraudulenta" para referirse a esta situación. Y, por ende, le han negado todo valor y eficacia.

De esta manera llegamos a la interesante y paradójica consecuencia de que, si efectivamente el recurso de revisión trata de poner atajo a la cosa juzgada fraudulenta, en el fondo es un homenaje a la cosa juzgada y no propiamente una excepción o quebrantamiento de este principio.

Observemos someramente por ahora la última causal de revisión: haber sido dictada la sentencia cuya revisión se pretende contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, si esta cosa juzgada no se ha invocado en el respectivo juicio. Adelantemos que hay una clara diferencia entre este caso y la causal de casación en la forma por cosa juzgada, porque en esta última se exige precisamente que se la haya invocado en juicio. La causal de revisión por cosa juzgada, en cambio, exige exactamente lo contrario: que no se la haya invocado en juicio.

El legislador parte de la hipótesis implícita de que hubo una primera sentencia firme o ejecutoriada que produjo cosa juzgada y una segunda sentencia, pretendidamente firme o ejecutoriada, de la cual se quiere también derivar este efecto, pero es una sentencia contraria a la ley.

Se plantea entonces si esta segunda sentencia puede ser atacada porque él la desconoció la cosa juzgada de la primera, y el legislador la responde afirmativamente porque, en la medida que va contra una anterior que producía cosa juzgada, en el fondo también es una cosa juzgada aparente, falsa.

Nuevamente por esta vía concluimos que en esta perspectiva, el recurso de revisión es un homenaje a la cosa juzgada y no una excepción al principio, porque en la causal que estamos invocando se persigue el pleno reconocimiento de la cosa juzgada de la primera sentencia, en apariencia vulnerado por la segunda cuya revisión se propugna.

11.5 Revisión y sentencia definitiva.

El que este recurso sólo sea invocable respecto de sentencias definitivas se deriva del inc. final del art. 810 del CPC, que después de analizar las diversas causales de este recurso, señala: "El recurso de revisión no procede respecto de las sentencias pronunciadas por la Corte Suprema, conociendo en los recursos de casación o revisión".

Esta disposición quiere decir que, cuando la Suprema conoce de los recursos de casación o revisión, y emite a su respecto un fallo que los acoja o deniegue, o en el caso de la casación dictando, eventualmente, una sentencia de reemplazo, no cabe en contra de esas resoluciones.

Pero sí cabe contra resoluciones dictadas por cortes de apelaciones o tribunales de primera instancia.

Por ello, dada la jerarquía de este recurso, que sólo excluye las sentencias de la corte Suprema, se ha querido concluir que sólo cabe (el recurso de) revisión respecto de sentencias definitivas.

11.6 Casuística del recurso de revisión civil (art. 810)

El encabezado dice que "La Corte Suprema de Justicia podrá rever una sentencia firme en los casos siguientes" y tiene la curiosidad de usar la expresión "Corte Suprema de Justicia". Muy pocas normas le dan esta denominación más bien protocolar, limitándose a llamarla simplemente "Corte Suprema".

Además subraya este inc. que la sentencia objeto del recurso debe estar, precisamente, firme, es decir, ejecutoriada.

1º) Si se ha fundado en documentos declarados falsos por sentencia ejecutoria, dictada con posterioridad a la sentencia que se trata de rever.

En primer lugar, la causal no exige que la prueba documentaria sea la única, sino sólo requiere que ésta sea fundamento de la sentencia que se trata de rever. Como la norma señala muy claramente, estos documentos deben ser declarados falsos en sentencia posterior.

Esta sentencia posterior que declara la falsedad de tales documentos no necesariamente debe ser sentencia penal, sino que basta con que sea sentencia civil. Se llega a esta conclusión comparando este numeral con los demás del art. 810, en los cuales se exige que la sentencia que sirve de base a la revisión sea, precisamente, una sentencia criminal.

2º) Si pronunciada en virtud de prueba de testigos, han sido éstos condenados por falso testimonio dado especialmente en las declaraciones que sirvieron de único fundamento a la sentencia.

En este caso se requiere que la prueba testimonial haya sido el único antecedente en que se basó la sentencia que se quiere rever. Además se requiere que los testigos que declararon en el juicio al cabo del cual se dictó la sentencia recurrida, hayan sido posteriormente condenados por falso testimonio dado especialmente en estas declaraciones

Respecto de esta materia digamos que en forma clarísima se requiere un juicio penal, criminal, posterior, donde estos testigos hayan sido específicamente condenados por falso testimonio. Y esta

condena debe arrancar entre otros antecedentes, pero precisamente, de las declaraciones hechas en este juicio.

Tengamos presente que en nuestro ordenamiento jurídico hay figuras muy similares, como son en este caso falso testimonio y perjurio. Aquí sólo estamos en el primer caso, porque comete perjurio quien presta declaraciones falsas bajo juramento ante la autoridad, mientras que el falso testimonio lo comete el testigo deliberadamente mendaz en sus declaraciones.

3º) Si la sentencia firme se ha ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, cuya existencia haya sido declarada por sentencia de término.

Es una situación genérica, porque se refiere a "cualquier maquinación fraudulenta" que permitió obtener injustamente la sentencia cuya revisión se pretende. Se refiere por vía meramente ejemplar al cohecho y a la violencia.

El cohecho es indudablemente una figura penal, pero no todo cohecho es constitutivo de la figura penal. Sólo se refiere en nuestro C. Penal a los empleados públicos. Pero hay formas de soborno no referidas a ellos y que también pueden revestir, civilmente, la forma de cohecho o maquinación fraudulenta.

Surge la duda de si se requiere que el haber sobrevenido cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta debe estar declarado por sentencia criminal, o basta que hayan sido declaradas en un juicio civil.

Nuevamente deberíamos concluir que basta un juicio civil si comparamos esta causal con la segunda, que se refiere a la figura del falso testimonio.

4º) Si se ha pronunciado contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y que no se alegó en el juicio en que la sentencia firme recayó.

Hay una clara diferencia entre esta causal y la del 768 N° 6, sobre la casación en la forma civil, que es haber sido dictada la sentencia casada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado en el respectivo juicio.

En este caso concreto, la causal de revisión es exactamente opuesta: que la acción o excepción de cosa juzgada no se haya alegado en el juicio respectivo.

11.5 Plazo de interposición.

Conforme al art. 811, este plazo es de un año, contado desde la fecha de la última notificación de la sentencia objeto del recurso.

En consecuencia, es un plazo de año corrido, no se suspende ni interrumpe en los feriados civiles ni en el feriado judicial.

Pero lo interesante es que este plazo no se cuenta desde el momento en que quedó ejecutoriada, o aparentemente ejecutoriada, la resolución contra la cual se recurre, sino que desde la última notificación de esta resolución. Es un capricho, porque lo lógico es que si es un requisito del recurso su efectiva interposición contra sentencia firme o ejecutoriada, el plazo para interponerlo debería haberse

contado desde que se produce la ejecutoria. Pero el legislador, quizás para despejar cualquier duda, dispone que el plazo se cuente desde la última notificación de la resolución de la sentencia que se pretende rever.

El inc. 2º subraya que si se presenta el recurso pasado este plazo, será rechazado de plano. O sea, en tal caso la Suprema ni siquiera entra a revisar el fondo de la cuestión planteada. Es un plazo común, ya que corre para todos desde la última notificación a las partes.

En el fondo en este caso no hay propiamente un rechazo del recurso, sino una declaración de inadmisibilidad por extemporánea presentación.

Pero si al cabo de este año no se ha fallado el juicio posterior dirigido a comprobar la falsedad de los documentos, el perjurio de los testigos, el cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, sentencia que es prerequisite del recurso de revisión, bastará que éste se interponga dentro del año, haciéndose presente que el juicio respectivo está en marcha, y aún no se ha dictado la sentencia que sirva de necesario fundamento a este recurso. De esta forma el desarrollo futuro del recurso de revisión queda en suspenso hasta que se dicte la sentencia en el juicio previo. De no ser así, el recurso de revisión sería ilusorio.

11.6 Tramitación.

Se refieren a ella los Arts. 813 y 814.

Presentado el recurso, el tribunal ordena que se traigan a la vista todos los antecedentes del juicio en que recayó la sentencia impugnada y cita a las partes para que comparezcan en el término de emplazamiento. O sea, se da traslado a todos quienes figuran como partes en el juicio cuya sentencia se pretende rever. Tienen plena aplicación los principios del término de emplazamiento. Es decir, la Suprema ordena poner el recurso de revisión en conocimiento de todos quienes fueron partes en el juicio de que se trata, para que dentro del término de emplazamiento expresen lo que estimen conveniente.

Es interesante dilucidar si este emplazamiento se realiza respecto de las partes en el juicio como primera notificación, y en consecuencia personalmente, o debe considerarse como un incidente o un trámite dentro del mismo juicio y, en consecuencia, que sea bastante una notificación por cédula. Además hay que despejar si es necesario notificar a quienes fueron partes en el juicio cuya revisión se pretende, o si bien es suficiente notificar a sus apoderados.

La respuesta nace de la postura que se adopte ante el recurso de revisión. Si decimos que es sólo un recurso que incide en un juicio, basta una notificación por cédula a quienes fueron apoderados del respectivo juicio.

Pero si el recurso de revisión es considerado una acción distinta habrá que aplicar los principios generales de la acción procesal, y en consecuencia notificar personalmente y a las partes mismas que lo fueron en el juicio cuya revisión se pretende.

Producida la comparecencia y respuesta de las partes dentro del término de emplazamiento, el recurso de revisión se tramita conforme a las reglas de los incidentes. Es decir, no hay una nueva respuesta del recurrente, sino que el tribunal resuelve si cabe o no recibir la cuestión a prueba. Si resuelve afirmativamente, abre un breve término probatorio de ocho días, prorrogable hasta un máximo de 30 y con la lista de testigos presentada dentro de los dos primeros días.

Sin embargo, lo normal es que en el recurso de revisión no haya probatorio, porque todos los antecedentes debieran constar en el proceso que le sirve de prerequisite.

Tramitado este incidente, la corte Suprema ordena vista a su fiscal, quien debe evacuar una determinada vista o informe. Las normas de tramitación consuetudinaria señalan que este informe se tiene por agregado a los autos con citación, con lo que se da a las partes la posibilidad de observarlo si lo estiman pertinente (art. 813).

11.7 Cumplimiento o suspensión.

De la sentencia cuya revisión se pretende, el art. 814 señala como regla general que la interposición del recurso de revisión no suspende el cumplimiento de la resolución impugnada.

Pero el inc. 2º señala que a petición del recurrente y oído el Ministerio Público (Fiscal Judicial), en vista de las circunstancias el tribunal puede ordenar que se suspenda la ejecución de la sentencia.

Ello procederá además siempre que el recurrente rinda fianza bastante para satisfacer el valor de lo litigado y los perjuicios que se causen con la no ejecución de la sentencia, para el caso que el recurso sea, en definitiva, desestimado.

Esta suspensión tiene diferencias con la propia del recurso de casación: en ésta, como regla general, no se suspende el cumplimiento de la resolución salvo en el caso que, de ejecutarse la sentencia, sea imposible dar cumplimiento a lo resuelto en la casación, o bien cuando el recurrente rinde fianza de resultas. Pero esto no procede en la casación respecto de juicios de alimentos, posesorios y para el ejecutado en el juicio ejecutivo.

En materia de revisión, en cambio, el criterio es más elástico porque la suspensión de la resolución que se impugna puede ser planteada en cualquier momento y siempre queda a criterio del tribunal concederla o no, ya que no hay una casuística legal. Pero, si la concede, siempre el recurrente debe rendir fianza de resultas.



¿Qué ocurre con el primer juicio si el recurso de revisión prospera?

El art. 815 dice que si el tribunal así lo dictamina, anulará en todo o en parte la sentencia impugnada (en la casación la sentencia impugnada se anula totalmente).

El recurso de revisión, en cambio, puede afectar a toda la sentencia, o bien a una parte de ella.

Por ejemplo, la sentencia obtenida bajo falso testimonio tiene declaraciones a favor del demandante, logradas precisamente gracias a este falso testimonio, y en contra suya. La sentencia subsiste en cuanto rechazó su pretensión y sólo será anulada en la parte que accedió a su pretensión fundada en el falso testimonio.

Es decir, para determinar la suerte de la sentencia objeto de la revisión debe analizarse cuál es la magnitud de la causal acogida.

Otro ejemplo: se acoge la revisión por haber sido dictada la sentencia que se recurre contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada.

Pero puede ser que entre ambas haya sólo algunos puntos resueltos en forma idéntica, pero otros lo hayan sido de manera distinta. En tal caso subsistirá la segunda sentencia en todo lo no contrario con la primera. Entonces, la sentencia de revisión dirá que en la segunda sentencia se anulan las declaraciones A, B y C, porque fueron las que vulneraron la cosa juzgada de la primera. O sea, de acuerdo con la naturaleza y ámbito del recurso se anulará en todo o en parte la sentencia revisada.

La anulabilidad parcial de la sentencia está consagrada en el inc. 1º del art. 815

El inc. 2º de esta norma dice que en la misma sentencia en que se acoge la revisión, el tribuna declarará si debe o no seguirse nuevo juicio, declaración que dependerá de cuál sea la causal de revisión acogida. Si es, vg, la cosa juzgada, no deberá seguirse nuevo juicio. Pero si se ordena seguir nuevo juicio, el tribunal indicará también el estado en que queda el proceso para que se continúe el juicio respectivo, y remitirá el proceso para que sea conocido por el tribunal que en definitiva resulte competente, según las reglas generales.

El inc. final del art. 815, por último, señala que servirán de base al nuevo juicio las declaraciones hechas en el recurso de revisión, las que ya no podrán ser discutidas.

Es curioso que los hechos que señale la sentencia de revisión se tornen indiscutibles para la posterior sentencia que se pudiese dictar.

Por último, el art. 816 indica que si el recurso de revisión es rechazado, se condenará precisamente en costas al recurrente y se ordenará que se devuelvan al tribunal que corresponda los autos que se mandaron traer a la vista, para que si es el caso, se proceda a la correspondiente ejecución.

Finalmente, digamos que las revisiones en materia civil son extraordinariamente poco frecuentes, y en nuestra jurisprudencia no se registran más de cinco o seis casos en que haya prosperado este recurso.

Las causales de interposición son de tal manera restringida que las posibilidades de que prospere son remotas.

Tema 12: Recurso de Queja.

12.1 Fundamentos jurídico-doctrinarios.

Es un recurso de características muy especiales, y propio de la legislación nacional, al punto que no encuentra un exacto correlato en otras legislaciones.

1. Se basa en el principio jerárquico o piramidal de la organización del poder judicial, que conlleva la finalidad disciplinaria, en el sentido que en virtud de esta orgánica jerárquica o piramidal, los superiores jerárquicos están encargados de vigilar la buena conducta funcionaria de sus subalternos.

Esta "buena conducta funcionaria" puede traducirse tanto en el cumplimiento de las obligaciones que los jueces, como magistrados o funcionarios públicos tienen, como en la dictación de las respectivas resoluciones judiciales.

En otras palabras, la inconducta o mal comportamiento funcionario puede traducirse tanto en la forma como se desempeñe el juez como en que dicte resoluciones que revele un actuar abusivo o una falta a sus deberes propios.

Así, vg, si un juez vive perseguido por sus acreedores, o es un bebedor excesivo y se lo ve frecuentemente en estado de intemperancia en lugares públicos, protagoniza escándalos conyugales o lleva una vida licenciosa se ha estimado que de alguna manera estas formas de conducta de alguna manera alteran la jerarquía y desprestigian al poder judicial como un todo. De ahí que los superiores jerárquicos están llamados a corregir estas conductas.

2. Otra razón es que si el juez no cumple con sus horas de despacho o tiene un manifiesto retardo en su respectivo tribunal, también puede ser objeto de medidas disciplinarias.

Pero lo interesante y curioso es que el recurso de queja no pretende corregir inconductas en el desempeño funcionario propiamente tal, sino que pretende corregir resoluciones judiciales consecuencia de un actuar abusivo del respectivo tribunal.

12.2 Renuncia al recurso de queja.

La jurisprudencia se ha pronunciado en igual sentido cuando las partes renuncian a la posibilidad del recurso de queja. Ha dicho que esta renuncia es ineficaz, ya que se funda en normas de orden público, indisponibles para las partes. Así, si en una cláusula arbitral se ha renunciado a todos los recursos, y más aún expresamente al de queja, se la debe tener por no escrita.

Sin embargo, hay un ancho campo en el cual nuestra jurisprudencia ha señalado que no cabe el recurso de queja, pese a estar ante resoluciones que aparentemente emanan de órganos jurisdiccionales: las

llamadas "resoluciones domésticas", que arrancan de organizaciones sociales intermedias que contemplan también potestades disciplinarias respecto de sus integrantes.

Por ejemplo, los directorios de clubes sociales, consejos de las asociaciones gremiales, las directivas de los sindicatos, tienen potestades disciplinarias de gran jerarquía sobre sus adherentes y en virtud de ellas pueden sancionarlos. Otro caso es el tribunal de penas del fútbol profesional. Nuestra jurisprudencia ha sido consistente en sostener que estas jurisdicciones domésticas no quedan sometidas a la superintendencia correccional de la Corte Suprema.

Y así, por tanto, una resolución del consejo del colegio de abogados que sancione a un asociado, o de un sindicato o club social, no es recurrible por recurso de queja, sin perjuicio de lo cual hay cierta jurisprudencia que ha dicho que si estas resoluciones de jurisdicciones domésticas importan violación o quebrantamiento de las garantías constitucionales, son recurribles por la acción constitucional o recurso de protección.

12.3 Recurso de queja y queja.

El recurso de queja se intenta cuando la falta o abuso que se pretende cometido, lo ha sido en la dictación de una resolución judicial. Por esta vía se intenta la enmienda o la nulidad de la respectiva resolución judicial. Se plantea una falta o abuso de carácter disciplinario, pero cometido precisamente en la dictación de esa resolución. Se pretende que esta resolución abusiva sea, en definitiva, dejada sin efecto o modificada.

En la queja, en cambio, se pretende una falta o abuso en cualquier otro campo distinto de la dictación de una resolución judicial. Puede ser en el campo del comportamiento privado del respectivo procesado, o del comportamiento funcionario del magistrado u otro integrante del orden judicial. Por la vía de la queja se puede, vg, perseguir las responsabilidades funcionarias de los notarios, conservadores de bienes raíces, archiveros. Y también por esta vía se puede pretender dejar sin efecto el acto abusivo por el cual se reclama.

Por ejemplo, un conservador de bienes raíces indebidamente cancela una inscripción, o indebidamente practica una inscripción o una anotación cualquiera, por vía de queja se reclama de esta inconducta funcionaria y, al mismo tiempo, se pide al tribunal que ordene restablecer la inscripción cancelada, cancelar la realizada en forma indebida o dejar sin efecto la anotación de que se trata.

Por ejemplo, si un notario indebidamente autoriza una escritura pública o deja de hacerlo, o indebidamente autoriza un instrumento privado, protesta un documento o da una certificación, por vía de queja puede también pretenderse no tan sólo sancionarlo por su inconducta disciplinaria, sino además dejar sin efecto el acto en el cual ésta se materializó.

12.4 Recurso de queja propiamente tal.

Claramente, conforme al art. 545 del COT (modificado en febrero de 1995), se pretende corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional.

Hay que destacar dos aspectos importantes:

1. La falta o abuso del que se reclama debe ser de carácter grave; no una inconducta menor.
2. Esta inconducta debe haberse producido en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. No es lo mismo porque hay resoluciones judiciales no jurisdiccionales, como los decretos económicos de un tribunal o una resolución dictada en una gestión no contenciosa, que no es jurisdiccional, sino administrativa.

En estos casos no cabe recurso de queja.

Pero hay que advertir que el art. 545 restringió substancialmente las resoluciones susceptibles de recurso de queja, que ahora sólo procede cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación, o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la facultad de la Suprema de actuar de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias.

Del art. 545 inc. 1º se desprende que:

- 1) El recurso de queja sólo cabe contra sentencias definitivas y contra sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. Pueden ser sentencias definitivas de única o segunda instancia. Pero las interlocutorias deben, necesariamente, poner término al juicio o hacer imposible su continuación.
- 2) Además se requiere que estas resoluciones, las interlocutorias en su caso o la definitiva, no sean susceptibles de otro tipo de recursos, sean ordinarios o extraordinarios. O sea, si respecto de una sentencia definitiva de segunda instancia cabe recurso de casación en la forma y en el fondo, no cabe recurso de queja, porque la posibilidad de recursos jurisdiccionales, ordinarios o extraordinarios, hace precluir la posibilidad del recurso de queja.

Esta es una gigantesca limitación al recurso de queja, porque lo normal es que las resoluciones que ponen término al juicio o impiden su continuación, o la sentencia definitiva, sean recurribles por otra vía.

En consecuencia, siendo recurribles por otra vía, esta circunstancia hace improcedente al recurso de queja.

Esta es la gran modificación al recurso de queja introducida en 1995: aunque haya falta o abuso grave, si la respectiva resolución en la cual se habría cometido la falta o abuso es recurrible por vía ordinaria o extraordinaria, no cabe este recurso.

Pero este principio cardinal tiene tres excepciones:

a) La Corte Suprema siempre puede, actuando de oficio, ejercitar sus facultades disciplinarias y dejar sin efecto cualquier resolución judicial, aun cuando ella hubiese podido ser recurrida por vía ordinaria o extraordinaria. O sea, esta limitación del art. 545 sólo es aplicable al recurso de queja, pero no a la posibilidad de que la Corte Suprema y sólo ella, por la vía oficiosa, ejercitando motu proprio sus facultades deje sin efecto o enmiende las respectivas resoluciones.

b) Tampoco es aplicable respecto de las sentencias definitivas de primera o única instancia dictadas por árbitros arbitradores, las que, no obstante ser recurribles de casación en el fondo también son recurribles de queja. En este caso, el recurso de queja es conocido por la respectiva corte de apelaciones.

c) La jurisprudencia ha declarado también que contra la resolución de la respectiva corte de apelaciones que se pronuncia sobre un recurso de queja contra un árbitro arbitrador, cabe también recurso de queja, cuestión altamente discutible y opinable.

12.5 Contenido y límites de la resolución que acoge el recurso de queja (inc. 2º del art. 545).

Cuando un recurso de queja es desechado por el tribunal, la resolución puede ser telegráfica. Dirá "no habiendo falta o abuso grave susceptible de ser enmendado por la vía disciplinaria, se declara sin lugar el recurso de queja deducido a fojas tanto". O sea, una resolución tan escueta basta para echar por tierra las expectativas del litigante.

Pero cuando el recurso de queja prospera y el tribunal respectivo lo acoge, el art. 545 señala el contenido y límites de esta resolución:

1. En primer lugar, debe indicar precisa y determinadamente cuáles son las faltas o abusos que se reprochan al juez y que fueron cometidos en la resolución recurrida.

2. También debe indicar de qué manera se remedian las faltas o abusos cometidos. Por ejemplo, podrá decir "...en virtud de lo antes expuesto se deja sin efecto la resolución de fojas tanto, y en cambio se declara que se mantiene la resolución de primera instancia escrita a fojas tanto". O bien "...en virtud de lo expuesto, se enmienda la resolución tal sólo en cuanto se suprime la resolución cual de la respectiva resolución".

Es decir, la falta o abuso debe explicitarse en la resolución que acoge el recurso, y además indicar con precisión cuáles son las medidas concretas y específicas que adopta el tribunal para poner pronto remedio al mal que motiva el recurso de queja.

Este inc. 2º, reiterativo al máximo, señala que el recurso de queja no es el medio idóneo para modificar o dejar sin efecto resoluciones que podrían haber sido recurribles por otras vías, salvo que se trate de una sentencia de primera o única instancia dictada por un árbitro arbitrador.

El inc. final del art. 545 establece una cortapisa adicional muy importante y que es una razón suplementaria para estrechar este callejón en que se ha convertido el recurso de queja.

Señala que cuando se acoge un recurso de queja y se invalida o modifica una resolución jurisdiccional, necesaria y precisamente se deben aplicar medidas disciplinarias a los funcionarios que concurrieron a su dictación. Y como estas medidas son resorte del pleno, la respectiva sala de la corte de apelaciones en su caso, o de la corte suprema, debe enviar los antecedentes al pleno para que éste aplique las medidas disciplinarias correspondientes, que como mínimo debe ser amonestación privada.

La importancia es que, pese a ser la más tenue de las medidas disciplinarias de nuestro ordenamiento, de ella se deja testimonio en la hoja de vida funcionaria.

Y cuando se confeccionan las quinas para aspirar al tribunal supremo, se excluye de ellas a quienes han sido afectados por medida disciplinaria en un cierto lapso anterior. Por esta vía, entonces, se puede tronchar o entorpecer la carrera judicial de un funcionario.

En consecuencia, la corte suprema, o la de apelaciones en su caso, tienen mucho cuidado en acoger el recurso de queja, porque la falta o abuso debe ser de tal entidad que justifique afectar de esta manera a un funcionario judicial que puede ser muy meritorio.

Dice esta norma: "Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, sólo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y formas que establezca la ley orgánica constitucional respectiva".

De esta manera, el constituyente, en una disposición de 1997 se está remitiendo a su modificación al COT de 1995, y en virtud de esta remisión, se entiende que eleva a ley de rango constitucional al inc. final del art. 545 del COT, que establece la necesidad de aplicar medidas disciplinarias. O sea, por la remisión que hace el constituyente, en esta modificación al art. 79 de la Constitución, a la ley orgánica constitucional, se entiende que se remite a la ley de 1995.

Y esta ley de 1995 establecía la necesidad de aplicar medidas disciplinarias.

11.6 Tramitación del recurso de queja (arts. 548 y 549).

11.6.1 Plazo para interponer este recurso.

Cinco días hábiles. Si el legislador sólo hubiese dicho "cinco días", se habría entendido que eran días corridos, en la medida en que el plazo está fijado en el COT, y no en el CPC. Sabemos que la regla general es que los plazos de días sean corridos salvo que expresamente se indique lo contrario, como ocurre con los plazos del CPC.

Este plazo de cinco días hábiles se aumenta según la tabla de emplazamiento, de acuerdo con la distancia entre el tribunal que dictó la resolución contra la cual se recurre y el tribunal ante el cual se interpone el respectivo recurso. Pero este aumento no puede exceder de un total de 15 días hábiles para interponer el recurso.

El plazo se cuenta desde que se le notifica la resolución que motiva el recurso.

11.6.2 Quién puede interponer el recurso.

Al ser recurso procesal debe interponerlo la parte agraviada, sea personalmente, por mandatario judicial, por su abogado patrocinante o por procurador del número.

Pero el recurso debe estar precisamente patrocinado por abogado habilitado. Es otra cortapisa al recurso de queja.

11.6.3 Requisitos del escrito (548 inc. 3º)

1. Indicar nominativamente los jueces o funcionarios recurridos.

Ejemplo: "recurso de queja contra la resolución tal dictada por los ministros de la corte de apelaciones de Santiago señores Juan López y Juan González Zúñiga". Se indican los nombres de todos los que concurrieron a la dictación del fallo recurrido.

2. Individualizar el proceso en el cual se dictó la resolución que motiva el recurso. El recurso se presenta directamente ante el tribunal que conoce de él, pero el expediente está en otro tribunal cualquiera.

3. Se transcribe, o se acompaña copia si se trata de una sentencia definitiva o interlocutoria, de la resolución respectiva.

4. Se indica el día de su dictación, la foja en que rola, la fecha de su notificación y se especificarán, con toda claridad, las faltas o abusos que se imputan a los jueces o funcionarios respectivos.

O sea, hoy este escrito es formal, ya que además el patrocinio del abogado debe cumplirse con los requisitos del inc. 3º del art. 548.

El inc. 4º del art. 548 obliga a acompañar un certificado en el cual se debe dejar testimonio de determinadas circunstancias habilitantes para recurrir de queja, el cual debe otorgarlo el secretario del tribunal contra el cual se recurre, sin necesidad de decreto judicial y a petición escrita o incluso verbal del interesado. Sus requisitos específicos y copulativos son: 1) indicar el número de rol del expediente; 2) su carátula; 3) el nombre de los jueces que dictaron la resolución que motiva el recurso; 4) la fecha de su dictación y la de su notificación al recurrente y 5) el nombre del mandatario judicial y de los abogados patrocinantes de cada parte.

El auto acordado da la posibilidad de pedir plazo para acompañar posteriormente este certificado, en casos urgentes.

11.6.4 Recurso de queja y orden de no innovar.

El tribunal, a petición de parte, puede decretar orden de no innovar. Esta solicitud se puede plantear en cualquier momento: al deducir el recurso mismo o durante su tramitación. Planteada la orden de no innovar, el tribunal sortea el asunto entre sus distintas salas, y la que se pronuncia sobre ella es la sala que debe fallar el recurso. O sea, para efectos de la orden de no innovar, el sorteo de sala radica el conocimiento del asunto en la sala respectiva (548 inc. final).

11.6.5 Reglas procedimentales del recurso de queja (art. 549)

Una vez deducido, el recurso de queja va a la sala de cuenta, la cual examina si se cumplen los requisitos formales para su interposición, si se ha interpuesto en tiempo y si se ha acompañado el certificado respectivo y cumple con los requerimientos señalados. Si no se lo ha acompañado, el tribunal puede dar un plazo adicional de hasta seis días, no prorrogables (plazo fatal) para que se lo acompañe.

Si el tribunal, conociendo en cuenta en la sala respectiva sobre su admisibilidad declara inadmisibile el recurso de queja, la resolución respectiva sólo es recurrible de reposición fundada en error de hecho, la cual se debe plantear conforme a las reglas generales.

Este examen se realiza en cuenta, es decir, sin alegatos y con solo lo que exponga o explique el relator a la sala respectiva.

La resolución que declara inadmisibile un recurso de queja, en virtud de la letra "a" del art. 549, no es a su vez recurrible de queja porque la ley expresamente reconoce la procedencia del recurso de reposición.

Y ya se ha dicho que es condición sine qua non para que proceda el recurso de queja que contra la resolución de que se trata no quepan otros recursos, ordinarios o extraordinarios.

El recurso de queja, ya se ha dicho, se interpone ante el tribunal que conoce del recurso, en el cual no está el expediente ya que se encuentra en el tribunal de la instancia respectiva.

El tribunal que conoce del recurso le pide informes al -- o los -- jueces recurridos para que, al tenor del recurso, expresen lo conveniente en relación con la falta o abuso grave que se les reprocha. Tienen un plazo máximo de ocho días desde que se recepciona el oficio respectivo para evacuar el informe.

Primero la propia Corte Suprema en el auto acordado, y luego el legislador del COT, trató de poner atajo a esta circunstancia. Para ello, dijo que cuando llega el oficio del tribunal superior jerárquico pidiendo informe, el tribunal receptor debe dejar testimonio de esta circunstancia en autos. Y la resolución respectiva, donde deja este testimonio, se notifica por el estado diario. Por esta vía, la parte contraria puede tomar conocimiento de la interposición del recurso de queja. (549 "b").

De esta forma se logra la bilateralidad de la audiencia con relación al recurso de queja.

La letra "c" del art. 549 dispone que el recurso de queja, en cuanto al fondo del asunto, se ve previa vista de la causa (antes se veía en cuenta). O sea, proceden los alegatos según las reglas generales.

Para efectos de la vista, el recurso se agrega en lugar preferente de la tabla y ésta se sortea entre las distintas salas. Es importante porque no se agrega como causa agregada. Salvo que haya habido un pronunciamiento previo respecto de la orden de no innovar, caso en que se agrega a la tabla como causa radicada.

La vista de la causa no puede ser suspendida, por su gravedad, y los tribunales sólo podrán decretar medidas para mejor resolver una vez terminada la vista de la causa. O sea, no pueden ordenar estos trámites previos a la vista.

La letra "d" del art. 549 dispone que cualquiera de las partes pueda comparecer en el recurso hasta antes de la vista de la causa.

Se refiere, claro está, a cualquiera de las otras partes del recurso distintas del recurrente.

La norma del art. 550, carente hoy de importancia, dispone que los miembros del poder judicial gozan de privilegio de pobreza para su defensa en los recursos de queja o en la substanciación de medidas disciplinarias que los afecten personalmente.

Por último, el art. 551 restringe substancialmente la posibilidad de recurrir contra las resoluciones que se pronuncian respecto de un recurso de queja. Señala que, como regla general, esa resolución sólo es

susceptible de recurso de apelación, cuando efectivamente sea dictada por un tribunal respecto del cual haya un superior jerárquico que pueda conocer del recurso de apelación.

Hay que tener presente que tratándose de árbitros arbitradores está expresamente vedado el recurso de apelación contra la sentencia de la corte de Apelaciones, pero, como regla general, un recurso de queja fallado por una corte de apelaciones es apelable.

Si ha sido fallado por la Corte Suprema, obviamente no cabe recurso de apelación.

Pero lo importante de esta disposición es que, expresamente y para corregir una serie de vicios que se habían producido con anterioridad, en la tramitación antigua del recurso de queja, se señala que en ningún caso cabe a su respecto recurso de reposición.

Hubo muchos reclamos en el sentido que, antiguamente, un recurso de queja que primero era desechado en la Corte Suprema, en una nueva composición de la sala o invocando alguna otra situación más o menos mágica, se pretendía, y a veces se lograba, que ella repusiese su resolución, de manera que cuando había dicho negro en un caso determinado, dijera blanco inmediatamente después, lo que era un desprestigio muy grande para los tribunales.

Esta disposición del art. 551 solucionó el punto, al vedar expresa y específicamente la posibilidad de reposición.

11.7 El auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de queja.

Como hemos dicho, este auto acordado de la Corte Suprema, publicado en el Diario Oficial del 1º de diciembre de 1972 (en el apéndice del COT), debe entenderse subsistente en todos los aspectos no contrarios a las normas legales ya vistas sobre este recurso.

Este auto acordado, como es evidente, fue dictado con bastante anterioridad a la reforma al recurso de queja que hemos estudiado, por lo que hoy, en gran medida, estas disposiciones están tácitamente derogadas porque fueron recogidas y modificadas por las disposiciones del COT.

Mucho se ha discutido si efectivamente la Corte Suprema tiene potestad para dictar de propia iniciativa autos acordados sobre tramitación de recursos procesales. Pero es una discusión meramente doctrinaria, académica, porque la Corte Suprema se ha arrogado esta potestad, y aplica las normas que ella misma ha dictado sobre el particular.

11.7.1 Aspectos relevantes del auto acordado (se entienden vigentes)

Nº 7 Referido a la Orden de no Innovar.

El Nº 7 de este auto acordado señala que cuando la orden de no innovar se concede en términos generales, paraliza todo el procedimiento. Pero se contempla como posibilidad que ella sea limitada a determinados actos o cuadernos dentro de los respectivos autos.

Dentro de este numeral es importante una disposición que despejó dudas interpretativas: antes era dudoso si dictada la orden de no innovar, y debidamente comunicada, se entendían suspendidos los plazos fatales en curso. Este número despejó definitivamente el punto, y declaró que la orden de no innovar no suspendía el curso de los plazos fatales correspondientes.

No se refirió al curso de los demás plazos porque éstos se extinguen por la declaración de rebeldía, la que claramente queda en suspenso por la ONI. En consecuencia, la alusión está bien planteada cuando se refiere a los plazos fatales, que no se suspenden en virtud de la ONI.

Por otra parte, si bien esta norma del Nº 7 sólo se refiere al recurso de queja, debe entenderse como norma directriz en la interpretación de todas las orden de no innovar, en el sentido que cualquiera sea el recurso en el cual recaiga no tiene la virtud de suspender el curso de los plazos fatales en el respectivo procedimiento.

Nº 8 Si, concedida orden de no innovar, se paraliza el recurso durante 15 días, se declarará desistido, de oficio o a petición de parte, y se dejará sin efecto la orden de no innovar

Se refiere a una situación particular de deserción o abandono del recurso de queja, cuando concedida una ONI se paralice la tramitación del respectivo recurso por 15 días.

El recurso de queja tiene una tramitación determinada, según se ha visto: se interpone con el certificado correspondiente, declaración de admisibilidad, petición de informe y autos en relación.

Si en alguno de estos trámites antes del decreto de autos en relación y concedida la orden de no innovar, se suspende la tramitación de este recurso de queja por 15 días o más, el tribunal debe declarar desistido, o desierto, el respectivo recurso.

Es obvio que si ya se decretó autos en relación, lo que tarde el recurso en ser visto no puede computarse para los efectos de esta deserción, porque la carga del impulso ya no radica en el recurrente, sino en el tribunal, que debe arbitrar los medios para su pronto despacho.

Nº 11 Según las consecuencias o efectos jurídicos de la decisión que pueda recaer en el recurso, el tribunal decretará, si lo estima necesario, que su estado se ponga en conocimiento de las partes o interesados a quienes pudiere afectar el fallo. Si aquellos no comparecen dentro del término que se señala al efecto, podrá dictarse resolución sin más trámites.

Recordemos que en el COT se señala que cuando llega la petición de informe al tribunal de la instancia, éste deja testimonio de esta circunstancia en autos y lo notifica por el estado diario, como una manera de poner en conocimiento de las partes el hecho de haber interpuesto este recurso de queja.

Sin perjuicio de este mecanismo, y apuntando también a la posibilidad de poner la interposición de este recurso en conocimiento de las partes, se faculta al tribunal que conoce del recurso para ordenar que éste sea puesto en conocimiento de las partes, y les fije un término para comparecer, en el entendido que si no lo hacen, se podrá fallar el recurso sin más trámites.

Nº 17 En los recursos de queja apelados, en materia civil, si no comparece el apelante dentro de tercero día, con el aumento del término de emplazamiento respectivo, certificará de oficio el secretario la no comparecencia, y el tribunal declarará desierta la apelación, sin más trámite.

Se trata de una deserción respecto de los llamados "recursos de queja apelados". El auto acordado se pone en la hipótesis que el recurso de queja sea resuelto por un tribunal en primera instancia, y que de acuerdo con las reglas generales del art. 551 del COT esta resolución sea apelable.

Si el apelante no comparece dentro de tercero día, hecho que certificará de oficio o a petición de parte el secretario del tribunal, éste (tribunal) declarará desierta la apelación sin más trámite.

Es curioso, porque el auto acordado conservó en este caso el plazo antiguo que había para comparecer - tres días ---. No lo modificó conforme a la reforma legal que en general consagró en las apelaciones un plazo de cinco días para comparecer.

11.8 La queja propiamente tal en el auto acordado.

El auto acordado distinguió claramente el recurso de queja de la queja propiamente tal, y la reguló tal como lo hizo con dicho recurso.

Los numerales respectivos son: el 15, 14 y 16.

A. Nº 15: Hace aplicables a las quejas los requerimientos procedimentales que el mismo auto acordado señaló para el recurso de queja. Es decir, en la presentación en que se la interponga se deberá indicar el nombre de los miembros del tribunal o funcionarios recurridos, debiendo expresarse con la mayor precisión los hechos que se refieren a la conducta ministerial de los primeros o a la actuación funcionaria de los últimos.

Este mismo numeral señala un plazo para la queja, que es substancialmente para el recurso de queja. Recordemos que en éste es de cinco días hábiles más emplazamiento, con tope de 15 días. Pero tratándose de la queja el plazo es de 60 días corridos contados desde la respectiva inconducta. Es decir, si por ejemplo, se quiere reclamar por una escritura pública indebidamente autorizada por el notario, o indebidamente no se autorizó, o de un acta de protesto o inscripción en el Conservador, ésta es la vía y el plazo, que es de días corridos, porque no está en el CPC.

A diferencia del recurso de queja, que es conocido en sala, sin perjuicio que la aplicación de la medida disciplinaria corresponda al tribunal en pleno, la queja propiamente tal, sea conocida por la respectiva corte de apelaciones o por la Suprema, es conocida por el tribunal en pleno.

B. En el Nº 14 se ve claramente el criterio diferenciador que señaló la Suprema entre el recurso de queja y la queja propiamente tal.

En el recurso de queja la falta o abuso se pretende cometido en una resolución judicial.

En la queja propiamente tal, en cambio, la falta o abuso se pretende sometida en la actuación funcionaria que se puede traducir en ciertos actos, contra los cuales se recurre.

C. El Nº 16 dice que cuando se la acoja, el fallo respectivo contendrá los fundamentos demostrativos de la falta, abuso, incorrección o actuación indebida, aplicará sanciones disciplinarias si las estima pertinentes y determinará las medidas necesarias para remediar el mal causado.

Esta última frase establece un ancho campo de posibilidad de corregir situaciones por una vía particularmente expedita.

Por ejemplo, un conservador de bienes raíces cancela indebidamente una inscripción, a consecuencia de lo cual practicó una serie de otras inscripciones sucesivas, dando nacimiento a un gran loteo brujo.

Si alguien reclama teniendo titularidad por ser de alguna manera afectado, la Suprema o la corte de apelaciones en su caso, no tan sólo puede sancionar la inconducta, sino adoptar todas las medidas necesarias para restablecer o poner pronto remedio al mal que motivó la queja. En este caso podría restablecer la inscripción indebidamente cancelada y ordenar la cancelación de toda la cadena sucesiva, para poner atajo al desmán funcionario contra del que se reclama.

El fallo que rechaza una queja es un telegrama procesal, lo mismo que el que rechaza el recurso de queja. O sea, bastará que señale que no habiendo falta o abuso susceptible de ser enmendado, se rechaza la queja deducida a fojas uno de los autos respectivos.

Pero, a diferencia de lo que ocurre con el recurso de queja, en que por expresa disposición del art. 551, la resolución que lo falla no es susceptible de reposición, la resolución que falla la queja propiamente tal sí es susceptible de reposición.

Ello, porque el art. 551, específicamente declara inadmisibile la reposición del fallo que resolvió un recurso de queja, no una queja.

En consecuencia, el Nº 20 del auto acordado rige parcialmente, en lo referente a la reponibilidad del fallo de la queja propiamente tal, pero no en cuanto señala que es posible reposición del fallo de un recurso de queja.

Nº 20: "La (parte) afectada podrá pedir reposición de las resoluciones, que recaigan en los recursos de queja y en las quejas propiamente tales y de las que se pronuncien durante su tramitación, dentro de cinco días contados desde que se dictó la respectiva resolución".

Insistamos en que esta disposición está derogada en cuanto a la reposición del recurso de queja (eliminada por la reforma de 1995 al art. 551 del COT) pero subsiste en cuanto a la posibilidad de reposición de la queja propiamente tal.

Por último, conforme al art. 552 del COT, las resoluciones que imponen una medida disciplinaria, tan pronto queden ejecutoriadas deben ser transcritas al Ministerio de Justicia, a la Corte Suprema y a las respectivas cortes de apelaciones. La renuncia voluntaria de un funcionario judicial debe ir acompañada

de un certificado del tribunal superior respectivo que acredite que no está sometido a sumario en que se investigue su conducta.

Si el funcionario está en tal caso, el presidente de la República no cursará esta renuncia en tanto no se haya resuelto y comunicado la medida disciplinaria, en caso de ser impuesta.

Unidad 2: La Cosa Juzgada.

Los estudios sobre cosa juzgada se han referido fundamentalmente a la cosa juzgada civil, porque la cosa juzgada en materia penal tiene muy serias restricciones, y con absoluta puridad se podría decir que la cosa juzgada penal sólo deriva de la sentencia absolutoria o del sobreseimiento definitivo firmes.



El término "**cosa juzgada**" según el extinto profesor Manuel Urrutia venía de la mala traducción de un latinazgo. Los romanos nunca fueron grandes teóricos del derecho y el pretor, que jugó el principal papel de creador del derecho, entre otras expresiones como *litis contestatio*, *actio pauliana*, etc, creó el término *res iudicata*, traducido más tarde por los glosadores como "cosa juzgada", cuando en realidad *res iudicata* no era cosa juzgada, sino cosa adjudicada. Esto significaba que en determinado momento de su decisión, el magistrado romano decía "tal cosa es de fulano de tal", y esta decisión se hacía irreversible en cuanto a que no se podía desconocer que esa cosa pertenecía a quien se la había adjudicado el pretor.

O sea, el término *res iudicata* -- o cosa juzgada, mejor dicho -- tuvo en su origen un contenido esencialmente material, no conceptual.

Pero con la evolución jurídica, este contenido de carácter material se fue alejando, siendo desplazado por el alcance conceptual del término, para llegar en definitiva a acuñar un concepto de cosa juzgada en función de la fijeza, inmutabilidad e irrecurribilidad de las sentencias, definitivas o interlocutorias, cuando están firmes o ejecutoriadas.

Tema 1: Conceptos de cosa juzgada.

Uno de los autores que más ha estudiado el tema en Chile es el procesalista Hugo Pereira, quien junto con Manuel Urrutia abrieron el camino de la modernización del derecho procesal.

A. Hugo Pereira dice que cosa juzgada "***es el efecto de las sentencias definitivas o interlocutorias firmes o ejecutoriadas para que aquél en cuyo favor se haya declarado un derecho en juicio, pueda pedir el cumplimiento o ejecución de lo resuelto***".

Este concepto nos merece algunos reparos:

1) Define la cosa juzgada por su efecto, no por su esencia. O sea, no dice qué es, sino cuáles son sus consecuencias, lo que es una forma más bien modesta de acercarse al tema.

2) Se refiere fundamentalmente a la acción de cosa juzgada, pero no a la excepción de cosa juzgada. O sea, a la posibilidad de hacer cumplir la sentencia en beneficio de quien la obtuvo, pero no a un efecto muy importante, que impide abrir debate respecto de un asunto que ha sido resuelto con anterioridad (excepción de cosa juzgada).

3) Comete el error de unir necesariamente el concepto de cosa juzgada con su cumplimiento, cuando hay sentencias que se bastan a sí mismas sin necesidad de ser cumplidas, como las sentencias declarativas y también las constitutivas, que se cumplen mediante simples anotaciones de carácter administrativo.

B. El procesalista uruguayo Eduardo J. Couture dice que cosa juzgada es "**la autoridad y efecto de las sentencias, firmes o ejecutoriadas, que importan su inimpugnabilidad, inmutabilidad y eventual coercibilidad**".

Es un concepto a la vez breve y muy certero. Su gran mérito es que va a la esencia misma de la cosa juzgada, en cuanto la señala como autoridad y efecto.

La cosa juzgada es la máxima expresión del acto jurisdiccional, que una vez firme o ejecutoriado -- siempre que se trate de ciertas categorías, como se vio en Procesal I -- produce el efecto de cosa juzgada, que importa su inmutabilidad e inimpugnabilidad, características que no se dan en otros actos jurídicos, sea administrativo, legislativo o contractual, sino que son propias y típicas de la sentencia firme o ejecutoriada.

Claramente la cosa juzgada es una autoridad, que concurriendo determinados requisitos, conlleva necesariamente la inmutabilidad e inimpugnabilidad.

La tremenda importancia de la cosa juzgada radica que, en el fondo, es emanación de la soberanía popular, la cual se expresa a través de algunos órganos fundamentales del Estado. Entre ellos se cuenta el Poder Judicial, llamado a resolver de una vez y para siempre los conflictos de relevancia jurídica. La cosa juzgada es consubstancial a la necesidad de resolver estos conflictos.

Tema 2: Aplicación del concepto de Couture a nuestra legislación.

Las sentencias que producen entre nosotros la autoridad y el efecto de cosa juzgada son las sentencias firmes o ejecutoriadas. Una sentencia está firme o ejecutoriada cuando no proceden recursos en su contra, procediendo no se interpusieron, o interpuestos fueron fallados y se agotaron las posibilidades de impugnación.

En nuestra legislación la autoridad o efecto de cosa juzgada sólo cabe respecto de sentencias definitivas e interlocutorias.

Siguiendo a Couture, esta autoridad o efecto se traduce en la inmutabilidad e inimpugnabilidad de la respectiva resolución. O sea, no es susceptible de ser atacada por recursos o acciones procesales, y es en sí misma inmutable. Pero estos principios -- precisamente por ser tales y no reglas -- no son absolutos. Hay casos, si bien muy excepcionales, en que bajo determinadas circunstancias pueden ser modificadas incluso sentencias firmes.

Pero la autoridad de cosa juzgada como puridad de concepto conlleva necesariamente esta inmutabilidad e inimpugnabilidad.

Por último el concepto del procesalista uruguayo señala la eventual coercibilidad: es decir, dependiendo de la naturaleza de la respectiva resolución, ella puede ser eventualmente cumplida por la fuerza.

Esto se debe a que, como ya se dijo, hay sentencias que no necesitan ser cumplidas, se bastan a sí mismas, como la que absuelve a un deudor, que se cumple ordenando alzar el embargo; una sentencia que declara la nulidad de un contrato.

Deben ser cumplidas las sentencias de condena, cuando el deudor no se allana voluntariamente a su cumplimiento. De ahí que sea correcto hablar de "eventual coercibilidad".

Tema 3: Naturaleza jurídica de la cosa juzgada.

Algunos, pretendiendo realzarla, han dicho que es un principio de derecho natural o de razón.

Fundamentalmente concluimos que la cosa juzgada es consecuencia de una política legislativa y judicial determinada, que privilegia la solución del conflicto por sobre la posibilidad del error judicial.

Hay una eterna lucha entre la justicia más pura y exacta y la resolución del conflicto de una vez y para siempre.

En pro de la justicia más depurada, debiera contemplarse la posibilidad imprescriptible de reabrir el debate con nuevos o mejores antecedentes; pero en función de la paz social y la necesidad de la solución del conflicto, todas las legislaciones de Occidente se inclinan por la inmutabilidad e inimpugnabilidad de la respectiva resolución.

3.1 Doctrinas sobre la cosa juzgada.

Distintas doctrinas han tratado de explicar la esencia de la cosa juzgada.

1. La Escuela Histórica (Von Savigny) dice que la cosa juzgada es una "ficción de verdad". Es decir, no pretende que la cosa juzgada sea la verdad judicialmente declarada, sino que se la tiene como verdad para efectos de la paz social.

2. Pothier, jurista francés inspirador del Código Napoleónico sostiene que la cosa juzgada es "presunción de verdad". O sea, se tiene por verdad lo que se declara en una sentencia firme o ejecutoriada.

Pero más allá de esta ficción o pretensión de verdad, la cosa juzgada es un efecto jurídico-político establecido por el ordenamiento jurídico en pro de la seguridad jurídica y la paz social.

Tema 4: Valor vinculante de la cosa juzgada.

Se ha planteado si arranca de la norma legal o el conjunto jurídico que subyace bajo el conflicto y que reconoce la sentencia, o de la sentencia misma. **¿Qué es lo vinculante en definitiva: el derecho que reconoce la sentencia como preexistente o la sentencia misma?**



Lo que es realmente vinculante es la sentencia misma, que, una vez firme o ejecutoriada, zanja definitivamente la cuestión.

Tema 5: Cosa juzgada y constitución.

Otra cuestión de gran importancia es determinar si la cosa juzgada tiene o no un fundamento constitucional, o meramente legal. En otras palabras, si una ley establece que bajo ciertas circunstancias los tribunales pueden modificar la sentencia dictada con antelación,

Como la constitución política establece la inmutabilidad de las sentencias judiciales por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, prohibición recogida en el art. 76 inc. 1º, segunda parte del texto, al señalar que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden avocarse (=llamar una causa a su conocimiento) al conocimiento de causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos, debe concluirse que por mandato constitucional la inmutabilidad de las sentencias se aplica cuando quien pretenda mutarlas sea el poder Ejecutivo o los poderes colegisladores.

Pero cuando esta posibilidad de mutación se reconoce al poder Judicial, **¿es constitucional o no una ley que autorice esta modificación?**

El profesor Hugo Pereira sostiene la tesis del fundamento constitucional de la cosa juzgada, a partir de la norma del art. 76 inc 1º, primera parte de la Constitución, en virtud de la cual la facultad de juzgar las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado, pertenece únicamente a los tribunales establecidos por ley.

Sin embargo es una doctrina minoritaria, porque si bien es cierta la Constitución usa el verbo rector "juzgar" no señala las consecuencias de este juzgamiento, lo que deja a la ley.

Si se pretende que dentro de estas consecuencias esté la cosa juzgada, es la ley la que debe señalar este efecto.

Por ello se ha estimado que es posible que se establezcan parámetros o disposiciones de mero nivel legislativo, que en ciertos casos permitan la revisión de sentencias firmes o ejecutoriadas cuando sobrevienen situaciones particulares que lo ameriten.

Tema 6: Conceptos relacionados con la cosa juzgada.

1) Proceso y cosa juzgada: hay una relación de medio a fin. El medio para llegar eventualmente a la cosa juzgada es, precisamente, el proceso. O sea, la cosa juzgada es normalmente la culminación del proceso. Esto no significa que de todo proceso emane necesariamente cosa juzgada, pero sí que toda cosa juzgada tiene como necesario antecedente un proceso.

2) Cosa juzgada y jurisdicción: el acto jurisdiccional puede adquirir la fuerza y autoridad de cosa juzgada y, en consecuencia, su inmutabilidad e inimpugnabilidad. Es el único acto jurídico, en nuestro ordenamiento, que puede llegar a reunir estas características. La cosa juzgada es necesaria consecuencia del acto jurisdiccional, pero no de todo acto jurisdiccional emana cosa juzgada.

3) Cosa juzgada y preclusión: la preclusión es el mecanismo que se ha ideado para que el proceso no retroceda; o sea, se van estableciendo sucesivas etapas por las cuales va atravesando el proceso y cada una de ellas se va cerrando definitivamente, mediante el correspondiente acto o consecuencia preclusiva. El enemigo de la preclusión es la nulidad procesal, porque así como la primera prohíbe o evita el retroceso, la nulidad procesal conlleva precisamente el retroceso del proceso en cuanto anula determinados actos.

Se ha dicho que la cosa juzgada es la máxima expresión de la preclusión; o sea, este cierre definitivo de la etapa adquiere su más clara y trascendente expresión en la cosa juzgada, que consecuencialmente no sólo cierra en forma definitiva el procedimiento respectivo, sino que resuelve de una vez y para siempre el conflicto que lo motivó.

En esta perspectiva se ha dicho que la cosa juzgada es la suma preclusión, el cierre preclusivo definitivo a causa de este efecto de autoridad de cosa juzgada.

Tema 7: Inmutabilidad de la cosa juzgada.

Por mandato constitucional, el efecto de las sentencias firmes o ejecutoriadas, de las cuales puede emanar la cosa juzgada, podrá ser eventualmente modificado por una decisión en contrario del órgano jurisdiccional. Pero jamás una decisión jurisdiccional puede ser dejada sin efecto por una decisión administrativa o legislativa. Así emana con toda claridad del art. 73 de la Constitución, ya explicado. Sí es concebible una posible mutabilidad por decisión de otro órgano jurisdiccional.

Es importante también relacionar la cosa juzgada con el art. 9º inc. 2º del CCv, que como excepción muy calificada señala la retroactividad de la ley interpretativa. La regla general en el CCv es la irretroactividad de la ley. La ley interpretativa se entiende incorporada a la ley interpretada y tiene, necesariamente, una vigencia retroactiva.

Pero la retroactividad de la ley interpretativa no conlleva la modificación de las sentencias judiciales que se hubiesen dictado antes de su vigencia. Esto refuerza la idea que el acto jurisdiccional es intocable tanto para el acto legislativo como administrativo.

Tema 8: Clasificaciones de la cosa juzgada.

Hay varias clasificaciones, pero la principal es la que distingue entre cosa juzgada formal y cosa juzgada substancial o material. Se agrega también la cosa juzgada provisional.

Imagínese una sentencia firme o ejecutoriada. La regla general es que la sentencia ejecutoriada produzca cosa juzgada substancial, es decir, que ni en ese mismo proceso ni en ninguno otro será posible rever lo resuelto. O sea, la inmutabilidad e inimpugnabilidad de la respectiva resolución tiene alcance general, es absoluta.

En cambio hay cosa juzgada formal cuando la prohibición es de modificar la resolución en ese mismo procedimiento, pero queda abierta la posibilidad de que en otro procedimiento pueda ser modificada en cuanto a sus efectos. No se modificará la resolución misma, es decir, no se dirá en el otro procedimiento que se revoca, sino que sus efectos emanados del primer procedimiento se modificaron en virtud de lo resuelto en el segundo.

Surge la duda de si en Chile hay efectivamente pie para sustentar el juicio de la cosa juzgada formal y substancial, es decir, ¿hay antecedentes positivos para afirmar que la concepción doctrinaria de la cosa juzgada formal y substancial tiene base efectiva?

La respuesta es **afirmativa**: hay en nuestro ordenamiento una serie de ejemplos y situaciones en que claramente se recoge el principio de la cosa juzgada formal: la posibilidad de revisar o modificar los efectos de una resolución dictada en un juicio anterior, en virtud de lo que en definitiva se falle en un procedimiento posterior e independiente.

Por ejemplo, en el juicio ejecutivo, la renovación de la acción ejecutiva por ser acogidas algunas excepciones (litis pendencia, ineptitud del libelo, incompetencia).

Otro ejemplo, también en el juicio ejecutivo es la reserva de acciones y excepciones: queda abierta la posibilidad que en el juicio declarativo ordinario posterior se modifique lo resuelto en el juicio ejecutivo.

En el juicio de alimentos la sentencia definitiva resuelve que el alimentante debe realizar ciertas prestaciones en favor del alimentario. ¿Es posible rever lo resuelto en el mismo procedimiento? La respuesta es sí, porque claramente el juicio de alimentos es claramente una resolución en función de situaciones objetivas, concretas y específicas. Estas son esencialmente mutables, y por ejemplo., pueden aumentar las necesidades del alimentario, cambió su situación económica o la del alimentante, etc.,. En este caso, nuestra legislación contempla la posibilidad, en el mismo juicio y aun tratándose de alimentos definitivos, de que se modifique lo inicialmente resuelto.

Entonces, **¿qué cosa juzgada es la de los juicios de alimentos?**

- Cosa juzgada substancial: no es.
- Cosa juzgada formal: tampoco, porque ésta prohíbe que en el mismo procedimiento se altere lo resuelto, y en este caso la ley permite alterar lo resuelto, precisamente en el mismo juicio.

En este caso se da lo que doctrinariamente se conoce como cosa juzgada aparente, es decir, entre tanto y mientras no se produzca un cambio de los parámetros objetivos, se mantendrá lo resuelto. Pero si se produce este cambio, es posible, en el mismo procedimiento, modificar lo resuelto.

Tema 9: Cosa juzgada formal.



"Es la autoridad y efecto de las sentencias firmes o ejecutoriadas que importan su inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad dentro del mismo proceso, pero que por mandato legal expreso permite, en un nuevo juicio, la revisión de lo resuelto".

Si bien es cierto la regla general es la cosa juzgada substancial, y la vertiente normal de la cosa juzgada formal es la ley que señala esa posibilidad, podrían imaginarse situaciones en que por las circunstancias es posible una revisión posterior.

Ejemplo: una sentencia que declara la interdicción de una persona.

Sería una aberración jurídica que no pudiera ser revista en un juicio posterior porque no hay ley que así lo señale. O sea, si bien es cierto la vertiente normal de la cosa juzgada formal es la disposición legal, no es la única.

En materia de cosa juzgada se habla también de Cosa Juzgada fraudulenta, lo que es una clara antinomia, porque la cosa juzgada tiene en sí misma una respetabilidad incompatible con una visión de fraudulencia a su respecto. Pero la doctrina ha querido reconocer este principio, porque tres de las cuatro causales del recurso de revisión civil están precisamente dirigidas a poner término a situaciones fraudulentas y por esta vía, echar abajo la sentencia impugnada.

Por lo menos en doctrina existe esta cosa juzgada fraudulenta, que permite efectivamente rever lo resuelto.

Tema 10: Límites de la cosa juzgada.

La regla general es que sólo afecta a las personas que estuvieron vinculadas como partes en el respectivo procedimiento, y no a terceros. O sea, el límite vinculante esencial de la cosa juzgada es que sólo afecta a las partes en juicio.

Hay una cuestión muy debatida en doctrina: el efecto reflejo de la cosa juzgada. Consiste en que respecto de terceros, lo resuelto tiene algún efecto o consecuencia aun si no han sido partes en el respectivo juicio.

El ejemplo típico es la sentencia que declara un determinado estado civil. Desde el punto de vista vinculante sólo afecta a las partes litigantes, pero en ciertos casos se da este efecto reflejo: erga omnes produce la consecuencia de reconocerse por todos el respectivo efecto civil declarado.

Por ejemplo, si una sentencia declara la nulidad de un matrimonio, este efecto reflejo se aplica a todo quien se vea enfrentado a las consecuencias jurídicas correspondientes. Así, vg, un banco no puede exigir a la (ex) cónyuge, declarada esta nulidad, autorización de su marido para abrir una cuenta corriente o tomar un crédito hipotecario, alegando que no fue parte en el juicio de nulidad.

Los límites de la cosa juzgada se clasifican en objetivos y subjetivos.

10.1 Límites subjetivos.

Se trata de determinar a quiénes alcanza la respectiva decisión jurisdiccional. En principio, sólo afecta a quienes han sido partes en el respectivo procedimiento en que se dictó la sentencia firme o ejecutoriada. Está precisamente recogido en el art. 3º del CCv, inc. 2º: "Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren".

Ésta es una de las grandes diferencias entre los distintos ordenamientos jurídicos de Occidente: en la vertiente anglosajona, los límites subjetivos de la cosa juzgada son mucho más amplios, en cuanto a que lo resuelto por un tribunal va fijando un precedente vinculante para los tribunales sucesivos, y fija normas.

Entre nosotros, en cambio, la cosa juzgada tiene efectos limitados, sólo respecto de las partes del respectivo juicio, y su consecuencia normativa, es decir, la jurisprudencia que posteriormente se pronuncie, es meramente moral.

Respecto de los terceros, se dice que la sentencia dictada en otro juicio es *res inter alios iudicata*, lo que se vincula al concepto civil *res inter alios acta*, es decir, cosa, contratos o convenciones entre terceros.

Cuando se invoca la *res inter alios acta*, significa que los efectos vinculantes de este acto, contrato o convención no le alcanzan.

En el mismo sentido se usa el término *res inter alios iudicata*: lo resuelto en un juicio vincula a las partes, pero no al tercero quien la invoca.

Partes: en este sentido son en primer lugar las propiamente principales, es decir, demandantes y demandadas.

También lo son quienes se han hecho o se han obligado a hacerse partes como terceros, sea en forma voluntaria como terceros coadyuvantes, excluyentes o independientes, o bien en virtud del art. 21 del CPC, es decir, quienes fueron arrastrados al juicio porque también les correspondía eventualmente ejercer la acción. O sea, "partes" en este caso tiene un sentido amplio.

Se ha discutido si la cosa juzgada afecta sólo a las partes o también a quienes han comparecido en representación de ellas. O sea, quien actuó en un juicio como representante de la respectiva parte, **¿podría en otro juicio, actuando a título personal, controvertir lo resuelto?**

La opinión de mayoría es afirmativa: si yo figuro como representante de la parte, como tal no me afecta la cosa juzgada en cuanto a mis derechos personales, por lo que podré plantear en juicio posterior una postura diametralmente opuesta, en defensa de mis intereses.

Otra materia discutida es si se entiende comprendidos en el término "partes" a los sucesores a título universal (herederos). O sea, si respecto de mi padre se dictó una sentencia en determinado sentido, yo, como su hijo y sucesor a título universal **¿me veo afectado por ella, se entiende que soy parte en este juicio?**

La respuesta no es tajante: el sucesor lo es en todos los derechos y obligaciones transmisibles, es decir, excluidos los personalísimos. Debemos concluir, por tanto, que en la medida en que el juicio se refiere a derechos u obligaciones transmisibles, vincula a los sucesores a título universal. Pero si dice relación con derechos u obligaciones personalísimos, no vincula a los sucesores a título universal.

Los sucesores a título singular respecto de ciertos derechos: es un asunto mucho más complejo. Imagínese que respecto de un predio determinado hubo un conflicto entre los propietarios colindantes, y en definitiva se fijan los deslindes. Uno de estos predios se enajena. La duda es si el nuevo adquirente podría plantear en un nuevo juicio la fijación de los deslindes de una forma distinta.

Si se aplica a rajatabla el principio de la relatividad o límite subjetivo de la cosa juzgada, se concluye que sí. Pero sucede que para efectos de la cosa juzgada también se considera partes a quienes son sucesores a título singular, en lo referido específicamente al bien respecto del cual son sucesores.

Es decir, en este caso el adquirente del predio queda vinculado y obligado por la sentencia dictada con antelación, pero no respecto de otras sentencias dictadas respecto de su antecesor en el dominio y que no digan relación específica con el bien.

Otro de los límites de la cosa juzgada es la subrogación procesal, tema muy complejo. En el derecho civil se habla de subrogación real y personal, las cuales tienen en común el ser una ficción jurídica.

En la subrogación real, la ficción es que un determinado bien reemplaza a otro en la misma situación jurídica en que éste se encontraba.

Por ejemplo, si se vende un bien de la mujer casada en sociedad conyugal, puede lograrse que el bien nuevo, que se adquiere con el producto de su venta, se subrogue jurídicamente al bien propio de la mujer. En caso contrario entra al haber social absoluto.

La subrogación personal ocurre cuando jurídicamente, una persona pasa a ocupar el mismo lugar de otra.

La subrogación procesal: es la posibilidad que efectivamente una persona, hasta entonces un tercero, pase a ocupar en un juicio la misma situación jurídica que tenía la persona a quien está subrogando.

En primer lugar, respecto de la subrogación procesal hay normas expresas en el CCv, en la llamada "cesión de derechos litigiosos", que precisamente consiste en que el cedente hace entrega de sus

expectativas de triunfo en un juicio a cambio de un determinado pago, y por mandato legal el cesionario de estos derechos litigiosos pasa a ocupar en este proceso la misma situación del cedente.

En general el CCv mira con desconfianza la cesión de derechos litigiosos estableciéndole varias limitaciones. Entre ellas, sólo el demandante o el tercero coadyuvante o independiente pueden ceder estos derechos, pero no así el demandado.

Surge entonces la duda: la subrogación procesal del CPC, **¿es el único fenómeno de este tipo que se admite en nuestra legislación, o es sólo una expresión de una situación jurídica generalmente aceptada?**

No hay una respuesta única, pero en general, nuestra doctrina y jurisprudencia se han inclinado por sostener que la subrogación procesal es una institución lícita y entra en el campo de la libertad contractual. En definitiva, siempre puede pretenderse que opere esta forma de subrogación, entendiéndose substituida una parte por un tercero que hasta ese momento no figuraba como tal.

Un interesante fallo del ministro Marcos Libedinsky sobre el tema: un arrendador inició un juicio contra un arrendatario, para que se declarase terminado el contrato de arrendamiento y se le restituyera la propiedad. Se dictó sentencia favorable a su pretensión. Antes de la llegada de la fecha de la restitución, el arrendador y propietario vendió el inmueble y el tercero adquirente exigió al arrendatario la restitución. Éste, alegó que la sentencia dictada lo obligaba con el anterior propietario, su anterior arrendador, pero no con el nuevo, ya que a su respecto el fallo era una res inter arios iudicata. La jurisprudencia resolvió que en este caso se había producido una forma de subrogación procesal, y en consecuencia, el nuevo adquirente se entendía subrogado en los derechos del demandante, y le cabía invocar en su beneficio el cumplimiento del fallo.

Esta sentencia, una entre varias similares, abre el campo de aceptar como posible la subrogación procesal y constituye sí un llamado particular al tema de los límites subjetivos de la cosa juzgada.

10.2 Límites objetivos.

Apuntan a determinar cuál es el ámbito de la decisión que efectivamente es inmutable e inimpugnable; o sea, que en consecuencia es vinculante para las partes.

El tema no es fácil. A primera vista podría decirse que esto emana de la estructura misma de los fallos judiciales, cuyas tres partes básicas son la expositiva, considerativa y resolutive.



En consecuencia, se podría decir a primera vista que sólo de lo resolutive, es decir, de lo que ordena el fallo, emana su carácter vinculante.

Por lo tanto, el límite objetivo de la cosa juzgada sería la parte resolutive de la sentencia firme o ejecutoriada de que se trata.

En tal sentido, se dice que la sentencia obliga en el querer, es decir, en la parte que ordena, pero no en el razonar, por lo que hay que estar sólo a lo resolutive del fallo.

Pero es necesario hacer dos alcances: 1) la parte resolutive en cuanto a su efectivo ámbito, debe interpretarse en función de la parte considerativa. O sea, lo que se resuelve en cuanto a mandato en un fallo debe ponderarse en función de los raciocinios contenidos en la respectiva resolución. 2) más importante es señalar que la jurisprudencia ha reiterado que hay ciertos considerandos que son propiamente resolutive y no sólo deductivos o de raciocinio. Es decir, para ver la parte vinculante del fallo no sólo hay que examinar su parte resolutive, sino que es necesario ver si hay alguna consideración o raciocinio que tenga en sí mismo un contenido resolutive.

Se concluye entonces que el límite objetivo de la sentencia es tanto su parte resolutive como los considerandos propiamente decisorios o resolutive.

Tema 11: Aspecto positivo de la cosa juzgada.

En primer lugar hay que determinar de qué resoluciones puede emanar: sólo de aquellas que se encuentren firmes o ejecutoriadas, no de resoluciones que causan ejecutoria

Además debe tratarse de una sentencia definitiva o interlocutoria, según aparece con toda claridad del art. 175 del CPC: "las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o la excepción de cosa juzgada".

Las sentencias interlocutorias pueden ser tanto de primera como de segunda clase.

Es decir, producen la acción y la excepción de cosa juzgada tanto la interlocutoria que falla un incidente estableciendo derechos permanentes en favor de las partes, como la que se pronuncia sobre un trámite que debe servir de base para la dictación de una sentencia definitiva o interlocutoria.

Por ejemplo, la resolución que recibe la causa a prueba, claramente produce cosa juzgada en el mismo juicio, en el sentido que la sentencia definitiva no podría rechazar la demanda por falta de prueba si la resolución que ordenó recibir la causa a prueba no fijó ese hecho como substancial, pertinente y controvertido.

El art. 174 señala cuándo se entiende firme o ejecutoriada la respectiva sentencia.

Tema 12: Acción y excepción de cosa juzgada.

Es muy interesante esta distinción que hacen los Arts. 176 y 177 del CPC.

12.1 Acción de cosa juzgada.

Corresponde a quien a cuyo favor se ha declarado un derecho en juicio para el cumplimiento de lo resuelto o para la ejecución del fallo, en la forma prevenida en el título 19º.

O sea, la acción de cosa juzgada tiene por objeto el cumplimiento de lo resuelto, para que se haga efectiva la decisión del respectivo pronunciamiento jurisdiccional. Recordemos el principio de la coercibilidad de la cosa juzgada: no toda sentencia firme o ejecutoriada necesita de cumplimiento, sino que sólo en la medida que lo necesite se invoca la acción de cosa juzgada, para que efectivamente se lleve a cabo, tenga presencia en la vida real. Las sentencias sólo declarativas o constitutivas no requieren del ejercicio de la acción de cosa juzgada.

Más aún, las sentencias de condena tampoco requieren de la acción de cosa juzgada, cuando el condenado cumple espontáneamente con la respectiva prestación.

Esta norma nos recuerda que la acción de cosa juzgada puede hacerse valer en un juicio separado -- normalmente un juicio ejecutivo -- o en el mismo procedimiento, por vía de cumplimiento incidental del fallo según las normas de los Arts. 233 y ss.

La acción y la excepción de cosa juzgada pueden emanar también de sentencias extranjeras, en la medida en que respecto de ellas se haya concedido el respectivo exequátur. Téngase presente que nuestro CPC contempla también normas sobre el cumplimiento de estas sentencias.

El art. 182 consagra el principio de la inmutabilidad de las sentencias definitivas e interlocutorias; pero es curioso que lo establezca no en relación con la cosa juzgada, sino con el desasimiento. Hay que distinguir claramente desasimiento de cosa juzgada.

Desasimiento es la prohibición que pesa sobre el juez que dictó una sentencia definitiva o interlocutoria de modificarla a partir de su notificación a cualquiera de las partes, salvo las situaciones legales.

Pero este desasimiento no significa que la resolución sea definitivamente inmutable, ya que, precisamente, en relación a las sentencias sobre las que se ha producido el desasimiento, es posible recurrir instando por su modificación.

Es interesante destacar que la cosa juzgada es posterior al desasimiento, pero se une a éste en cuanto a que uno y otra importan cierto grado de inmutabilidad.

12.2 Excepción de cosa juzgada.

El art. 177 del CPC señala cuándo se produce. Es la norma de mayor riqueza conceptual en nuestra legislación referida a la cosa juzgada.

Señala que: "**La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya:**

- 1º Identidad legal de personas;**
- 2º Identidad de la cosa pedida; y**
- 3º Identidad de la causa de pedir.**

Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio".

La cosa juzgada mirada desde el punto de vista de la excepción implica que renovada una petición que anteriormente haya sido resuelta por sentencia firme o ejecutoriada, y de la cual emane cosa juzgada -- en general cosa juzgada substancial -- el demandado en este nuevo juicio puede impedir que nuevamente se entre al fondo de la cuestión invocando la autoridad de la sentencia anterior firme o ejecutoriada.

Hay que destacar en particular que el inc. 1º del art. 177 señala que no tan sólo el ganancioso en el juicio anterior puede invocar esta excepción de cosa juzgada, sino que también lo puede hacer todo aquél a quien aproveche el fallo respectivo.

Como regla general la cosa juzgada sólo tiene efectos relativos, es decir, en cuanto a quienes han sido litigantes. Pero puede también tenerlos más allá de este círculo, cuando se trata de herederos a título universal o sucesores en un determinado derecho, respecto del cual se haya producido el conflicto anteriormente resuelto.

Pero lo esencial para poder invocar la excepción de cosa juzgada es que concurra la tantas veces señalada "triple identidad".

Esta triple identidad también está en la excepción de litis pendencia, en la cual frente a un nuevo juicio que reitera acciones de uno anterior, es también invocable para evitar que se siga tramitando el nuevo juicio, que quedará paralizado a la espera de lo que se resuelva en el que se está llevando a cabo.

a) Identidad legal de persona: que es perfectamente distinta de la identidad física. Hay identidad legal de persona cuando en el nuevo juicio que se pretende iniciar hay coincidencia jurídica en cuanto a la posición de las respectivas partes, demandante y demandado. Por ejemplo., en un juicio se demanda a Pedro Pérez y en uno posterior sobre el mismo conflicto se demanda a su hijo que aceptó la herencia sin restricción alguna, éste cabe dentro de la identidad legal de persona: desde el punto de vista jurídico está ocupando la misma situación que su causante en el juicio anterior.

Esta observación cabe cada vez que las personas envueltas en el nuevo conflicto sean alcanzadas por las consecuencias vinculantes de la primera resolución.

b) Identidad de la cosa pedida: el legislador no ha definido qué es "cosa pedida", pero la jurisprudencia y doctrina han ido elaborando el concepto, concluyendo que la cosa pedida no es el bien material reclamado, sino que el beneficio jurídico que se pretende. Esto alude no tan sólo el beneficio jurídico mismo sino además todas sus consecuencias.

Veamos dos ejemplos: en el primero hay coincidencia en el objeto material pedido no hay identidad de cosa pedida. Y en el segundo, pese a que no hay identidad material de la cosa pedida, sí hay identidad legal en cuanto al beneficio.

Imaginemos que respecto del potrero "El Sauce" yo intento una acción reivindicatoria, pretendiendo que en definitiva el poseedor reconozca mi dominio y me sea devuelto.

Supóngase que se rechaza la demanda y posteriormente yo reclamo la entrega del mismo potrero invocando mi calidad de arrendatario del mismo.

Entre ambos juicios no hay identidad legal de cosa pedida, porque si bien es cierto el objeto material reclamado es el mismo, el beneficio jurídico que se pretende es diferente. En el primer caso lo que pretendo es que se me reconozca la calidad de dueño o propietario del citado predio y consecuentemente su devolución, mientras que en el segundo invoco la calidad de arrendatario y consecuentemente su entrega.

Veamos el caso inverso: el beneficio material es distinto pero el beneficio jurídico es el mismo, y es un caso de la vida real.

Una persona que prestaba servicios a una institución dijo ser empleado de ésta, e invocando esta calidad solicitó el pago de las imposiciones previsionales correspondientes. El fallo señaló que no había un contrato de trabajo, sino de prestación de servicios, y en consecuencia no cabía este pago de las prestaciones previsionales.

Posteriormente, esta misma persona invocando nuevamente la calidad de empleado de la firma, alegó que se le debían compensar las vacaciones de las cuales no había gozado.

En ambos casos las prestaciones difieren totalmente: en el primer caso, entero de cotizaciones previsionales; en el segundo, entero o compensación en dinero por no uso de vacaciones.

Sin embargo, en ambos casos el beneficio jurídico perseguido es el mismo: ambas presentaciones pretendían que se le reconociese la calidad de empleado, y en consecuencia el vínculo laboral.

Las prestaciones concretas eran mera consecuencia de aquella calidad.

Vemos claramente que la cosa pedida es el beneficio o estatus jurídico reclamado y no las consecuencias de éste.

c) Identidad de la causa de pedir: en este caso el legislador sí da el concepto: el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.

El legislador exige inmediatez del fundamento, porque en definitiva el fundamento mediato de toda prestación que se reclama es el ordenamiento jurídico en general. El fundamento inmediato se refiere a

la situación jurídica que se pretende y que el reclamante estima que ha sido privado, sea de ella o de sus consecuencias.

La jurisprudencia reiterada ha dicho que el fundamento inmediato del derecho reclamado no es ni está constituido por las disposiciones jurídicas que invoca el demandante o reconviniente, sino que por la situación jurídica que él alega que existe y sirve de fundamento a su pretensión.

Es decir, el demandante puede equivocarse citas legales, puede señalar indebidamente un determinado contexto de leyes cuando fundamenta su pretensión, pero lo determinante para establecer la causa de pedir es la situación jurídica que él invoca en apoyo a su respectiva pretensión.

Concurriendo esta triple identidad legal, y siempre que en la sentencia respectiva se produzca el efecto de cosa juzgada, se puede invocar con éxito la excepción de cosa juzgada.

El art. 182 de alguna manera, pero refiriéndose más bien al desasimiento que a la cosa juzgada, señala esta consecuencia de la inmutabilidad de las resoluciones. Pero, como ya se dijo, desasimiento y cosa juzgada son dos fenómenos perfectamente distintos y así, la sentencia respecto de la cual se produce el desasimiento no necesariamente adquiere de inmediato el efecto de la cosa juzgada, sino que será susceptible de eventuales recursos procesales que de alguna manera la puedan modificar.

Tema 13 El efecto de cosa juzgada de las sentencias criminales en materia civil.

Materia tratada en los Arts. 178 a 180 del CPC y denominada de esta forma porque justamente el art. 179 señala específicamente que en ciertos casos la sentencia en materia criminal produce cosa juzgada en el respectivo juicio civil.

El encabezado de esta norma es: "Las sentencias que absuelvan de la acusación o que ordenen el sobreseimiento definitivo, sólo producirán cosa juzgada en materia civil, cuando se funden en alguna de las circunstancias siguientes".

Sin embargo, adviértase que se trata de una falta de sistema de nuestra legislación civil, porque entre una sentencia penal propiamente tal y una civil nunca concurre la triple identidad, porque en ningún caso la cosa pedida o la causa de pedir en el conflicto penal coinciden con la cosa pedida o la causa de pedir en el conflicto civil, sino que por el contrario, difieren substancialmente. Podrá haber o no coincidencia de partes, es decir, del elemento persona.

En consecuencia, esta norma hay que interpretarla en el sentido que la sentencia penal nunca produce propiamente cosa juzgada en materia civil, sino que tiene un efecto probatorio en materia civil, de suerte que los hechos que esa sentencia establezca son vinculantes para el juez civil en ciertos casos, y en consecuencia él no puede decidir en contra de lo que la sentencia penal señaló como "hechos de la causa".

De esta forma, la sentencia penal no produce cosa juzgada respecto de la causa civil, sino que pura y simplemente tiene un efecto probatorio cuando efectivamente concurren ciertos requisitos.

La razón por la cual el legislador da preeminencia en algunas situaciones a la sentencia penal por sobre la civil y obliga al juez civil a sentirse vinculado a aquélla es, una vez más, la verdad material que se persigue en materia penal, tras una actividad indagatoria oficiosa del mismo tribunal.

En consecuencia, las conclusiones fácticas de esa decisión son largamente menos erráticas que las posibles conclusiones fácticas de la sentencia civil. Por eso el legislador civil da esta supremacía a la sentencia penal en cuanto a los hechos que de ella emanan.

Pero no toda sentencia penal produce este efecto vinculante, sino sólo, como regla general, las sentencias condenatorias, al tenor del art. 178: "En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado".

O sea, si hay condena penal, los hechos que se dan por establecidos en esa sentencia condenatoria firme, no pueden ser posteriormente discutidos en un juicio civil.

Pero además el art. 179 señala en qué caso la sentencia penal produce efectos en el juicio civil, en cuanto a dar por establecidos los hechos, cuando la sentencia es absolutoria.

La sentencia absolutoria en materia penal debe cumplir ciertos requisitos para producir este efecto probatorio en el juicio civil. Es decir, no toda sentencia absolutoria penal lo produce.

El art. 179 del CPC, ya mencionado, señala que el efecto demostrativo o probatorio a que nos referimos puede emanar, tanto de la sentencia absolutoria como del sobreseimiento definitivo, que como sabemos, of course, equivale a sentencia absolutoria y es muy distinto al mero efecto paralizante o suspensivo del sobreseimiento temporal.

13.1 Casuística del art. 179

1º La no existencia del delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso. No se entenderán comprendidos en este número los casos en que la absolución o sobreseimiento provengan de la existencia de circunstancias que eximan de responsabilidad criminal.

Si la sentencia absolutoria o el sobreseimiento definitivo declaran que no existió el delito, esta declaración es vinculante para el juez civil.

En este numerando no se identifica claramente las causales de sobreseimiento definitivo a las cuales se refiere.

Pero por vía interpretativa puede señalarse que en este N° 1 del art. 179 están comprendidas dos situaciones:

- 1) La declaración que el hecho no haya existido.
- 2) La declaración que el hecho no es típico.

Cualquiera de estas dos circunstancias declaradas en la sentencia absolutoria o el sobreseimiento se traduce en que los hechos establecidos en dicha resolución tienen este poderoso efecto reflejo.

Pero el legislador advierte que claramente esta causal no concurre cuando se ha absuelto o sobreseído definitivamente por concurrir respecto del acusado una causal de extinción de responsabilidad penal que lo exime de ella.

2º No existir relación alguna entre el hecho que se persigue y la persona acusada, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda afectarle por actos de terceros, o por daños que resulten de accidentes, en conformidad a lo establecido en el título 35 del libro 4º del C. Civil.

También produce este efecto reflejo la sentencia penal absolutoria o el sobreseimiento que declara no haber relación alguna entre el acusado y el hecho que se persigue. El hecho pudo haber existido, pero la sentencia o el sobreseimiento declara que entre él y la pretendida autoría o responsabilidad del acusado no existió relación alguna.

Pero advierte este numerando que lo expresado es sin perjuicio de la responsabilidad civil que por actos de terceros pueda afectar a este acusado, conforme a las normas del código civil.

Si se persigue la responsabilidad extracontractual del tercero civilmente responsable, éste puede no tener vínculo alguno con los hechos; pero esta circunstancia no lo exime necesariamente de responsabilidad, porque responde en definitiva aunque no tenga vínculos con los hechos, porque muchas veces responde del hecho ajeno.

3º No existir en autos indicio alguno en contra del acusado, no pudiendo en tal caso alegarse la cosa juzgada sino respecto de las personas que hayan intervenido en el proceso criminal como partes directas o coadyuvantes.

Cuando en autos no existe indicio alguno contra el acusado, el legislador agrega un requisito especial para que se produzca este efecto reflejo: sólo puede aplicarse respecto de las personas que hayan intervenido en el proceso criminal como partes directas o coadyuvantes.

Es decir, la falta de indicios en cuanto a los hechos en que se fundamente produce efecto reflejo sólo si en el juicio civil posterior coinciden estas mismas partes con aquellas que lo fueron en el respectivo proceso penal.

Esta coincidencia que se requiere no es completa o absoluta, pero sí se puede invocar sólo respecto de quienes tuvieron aquella calidad en el proceso penal respectivo.

Pero el inc. final de este art. 179 contiene una gran contraexcepción a todo lo señalado anteriormente: "Las sentencias absolutorias o de sobreseimiento en materia criminal relativas a los tutores, curadores, albaceas, síndicos, depositarios, tesoreros y demás personas que hayan recibido valores u objetos muebles por un título de que nazca obligación de devolverlos, no producirán en ningún caso cosa juzgada en materia civil".

El legislador una vez más señala que el que está a título de administrador de bienes de terceros, como síndico, curador, depositario, mandatario, en fin, cualquiera sea el título que lo obliga a devolver, la sentencia absolutoria penal nunca produce efecto reflejo a su respecto.

Es algo enteramente razonable: puede que en la sentencia penal se declare que no hay delito porque no hay dolo. Pero quien es síndico, tutor, apoderado, etc., responde también de la culpa. Es decir, el fallo absolutorio significa que no es responsable penalmente, pero sí puede serlo en materia civil: en consecuencia no cabe el efecto reflejo.

El art. 180, en tanto, señala que cuando la sentencia criminal produzca estos efectos reflejos que el legislador del CPC denomina "cosa juzgada", no es lícito en la sentencia civil tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento.

s decir, todo lo que esté en contradicción con lo resuelto en la sentencia penal o con los hechos que le sirven de necesario fundamento no son alegaciones que puedan ser oídas en el posterior juicio civil.